BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

NGUYỄN HỒNG QUÂN

PHÁP LUẬT VỀ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG – THỰC TRẠNG ÁP DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI, CHI NHÁNH CẦN THƠ

LUẬN VĂN THẠC SĨ
NGÀNH LUẬT KINH TẾ
MÃ SỐ 8380107

NĂM 2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

NGUYỄN HỒNG QUÂN
MÃ SỐ HV: M3422044

PHÁP LUẬT VỀ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG – THỰC TRẠNG ÁP DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI, CHI NHÁNH CẦN THƠ

LUẬN VĂN THẠC SĨ
CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ
NGÀNH: LUẬT KINH TẾ
MÃ SỐ: 8380107

NGƯỜI HƯỚNG DẪN
PGS.TS. ĐOÀN THỊ PHƯƠNG DIỆP
TS. NGUYỄN THỊ MỸ LINH

NĂM 2024

CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG

Luận văn này, với đề tựa là "Pháp luật về bảo lãnh ngân hàng - thực trạng áp dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội, chi nhánh Cần Thơ", do học viên Nguyễn Hồng Quân thực hiện theo sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh và PGS.TS. Đoàn Thị Phương Diệp. Luận văn đã báo cáo và được Hội đồng chấm luận văn thông qua ngày: 21/8/2024. Luận văn đã được chỉnh sửa theo góp ý và được Hội đồng chấm luận văn xem lại.

Thư ký	**Ủy viên**
TS. DƯƠNG VĂN HỌC	**TS. NGUYỄN PHAN KHÔI**
Phản biện 2	**Phản biện 1**
TS. LÊ THỊ NGUYỆT CHÂU	**PGS.TS. NGUYỄN NGỌC ĐIỆN**
Người hướng dẫn 1	**Người hướng dẫn 2**
TS. NGUYỄN THỊ MỸ LINH	**PGS.TS. ĐOÀN THỊ PHƯƠNG DIỆP**

Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS. PHAN TRUNG HIỀN

LỜI CẢM ƠN

Trong nền kinh tế thị trường hoạt động của các ngân hàng thương mại là hết sức quan trọng, góp phần hỗ trợ và thúc đẩy kinh tế của một quốc gia phát triển.

Hoạt động của các NHTM đa dạng và phong phú với nhiều chức năng khác nhau, cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ khác nhau để hỗ trợ cho các tổ chức kinh tế, cá nhân hoạt động có hiệu quả. Bảo lãnh ngân hàng là một loại hình dịch vụ trong các nghiệp vụ tại ngân hàng. Bên cạnh những lợi ích mà loại hình dịch vụ này đem lại thì cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, chanh trấp khi phát sinh.

Đề tài "Pháp luật về bảo lãnh Ngân hàng – Thực trạng áp dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội, Chi nhánh Cần Thơ" là sự thể hiện nhận thức, tiếp thu và đánh giá từ hoạt động thực tiễn trong hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần quân đội, Chi nhánh Cần Thơ nói riêng và ngành ngân hàng nói chung tại thành phố Cần Thơ và kiến thức của bản thân được các thầy cô hướng dẫn và giảng dạy.

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới cô PGS.TS. Đoàn Thị Phương Diệp và cô TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh đã tận tình hỗ trợ, chỉ dẫn và tạo mọi điều kiện để tôi hoàn thành công việc nghiên cứu khoa học của mình.

Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo khoa Sau Đại học, khoa Luật – Trường Đại học Cần Thơ và các thầy cô giáo trong khoa đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành khóa học.

Học viên

Nguyễn Hồng Quân

TÓM TẮT

Tên đề tài: Pháp luật về bảo lãnh Ngân hàng – Thực trạng áp dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội, Chi nhánh Cần Thơ.

Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 8380107 Ngành: Luật.

Người hướng dẫn:

- PGS. TS. Đoàn Thị Phương Diệp, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM.

- TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh, Trường Đại học Cần Thơ.

Tác giả: Nguyễn Hồng Quân Khóa học: 29 Niên khoá: 2022-2024.

Giới thiệu: Pháp luật về bảo lãnh Ngân hàng – Thực trạng áp dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội, Chi nhánh Cần Thơ có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy các hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho các chủ thể nói chung, tạo ra sự tin tưởng cho các bên giao kết hợp đồng. Tuy nhiên, hoạt động bảo lãnh của các ngân hàng thương mại nói chung và Ngân hàng TMCP Quân Đội, Chi nhánh Cần Thơ nói riêng vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, bất cập, chưa phát huy được hiệu quả tối đa trong thực tiễn áp dụng. Vì vậy, cần phải nghiên cứu để đưa ra giải pháp hoàn thiện chế định bảo lãnh ngân hàng.

Mục tiêu: Nghiên cứu, phân tích những vấn đề lý luận, quy định của pháp luật về bảo lãnh ngân hàng, thực trạng áp dụng pháp luật về bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội, Chi nhánh Cần Thơ, từ đó thấy được những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế để có định hướng, giải pháp phù hợp cho việc hoàn thiện pháp luật về bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội, Chi nhánh Cần Thơ nói riêng và các Ngân hàng thương mại nói chung.

Phương pháp: Để làm rõ các cơ sở lý luận, tác giả sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu để luận giải vấn đề như: phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu dựa trên cơ sở các bài viết, công trình nghiên cứu, pháp luật nhà nước. Đồng thời, tiến hành phân tích, đánh giá dữ liệu để chứng minh những vấn đề hợp lý và chưa hợp lý giữa những quy định của pháp luật hiện hành và thực tiễn của vấn đề đặt ra.,…để làm rõ những bất cập và đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật.

Kết luận: Thông qua kết quả nghiên cứu đề tài cho thấy những quy định pháp luật còn nhiều bất cập, không đáp ứng được nhu cầu điều chỉnh các loại giao dịch mới xuất hiện như bảo lãnh điện tử, gây trở ngại trong thực tiễn áp dụng; ... Vì vậy, người viết đưa ra những giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về bảo lãnh tại ngân hàng thương mại nói chung và Chi nhánh Cần Thơ nói riêng.

Từ khóa: Pháp luật, Bảo lãnh ngân hàng, Chi nhánh Cần Thơ.

ABSTRACT

Project title: Law on bank guarantees - Current situation of application at Military Commercial Joint Stock Bank, Can Tho Branch.

Major: Economic Law Code: 8380107 Industry: Law.

Instructor: - Associate Professor. Dr. Doan Thi Phuong Diep, University of Economics and Law, Ho Chi Minh City National University. - Dr. Nguyen Thi My Linh, Can Tho University.

Author: Nguyen Hong Quan Course: 29 School year: 2022-2024.

Introduction: Law on Bank Guarantees - Current situation of application at Military Commercial Joint Stock Bank, Can Tho Branch is important in promoting goods purchase and sale activities and providing services to owners. In general, creating trust for contracting parties. However, the guarantee activities of commercial banks in general and Military Commercial Joint Stock Bank, Can Tho Branch in particular still have many difficulties and inadequacies, and have not been maximally effective in practice. apply. Therefore, it is necessary to research to come up with solutions to perfect the bank guarantee regime.

Objective: Research and analyze theoretical issues and legal regulations on bank guarantees, the current situation of applying the law on guarantees at Military Commercial Joint Stock Bank, Can Tho Branch, from which to see achieved results, limitations and causes of limitations to have appropriate directions and solutions for perfecting the law on guarantees at Military Commercial Joint Stock Bank, Can Tho Branch in particular and commercial banks. commerce in general.

Method: To clarify the theoretical basis, the author uses a combination of many research methods to explain the problem such as: analysis, synthesis, comparison, and contrast based on the articles. , research works, state laws. At the same time, conduct analysis and evaluation of data to demonstrate reasonable and unreasonable issues between current legal regulations and the reality of the problem raised... to clarify inadequacies. and propose solutions that contribute to improving the law.

Conclusion: Through the research results of the topic, it is shown that the legal regulations still have many shortcomings, do not meet the need to regulate newly emerging types of transactions such as electronic guarantees, causing obstacles in practice. apply; ... Therefore, the writer offers solutions that contribute to perfecting the law on guarantees at commercial banks in general and Can Tho Branch in particular.

Keywords: Law, Bank guarantee, Can Tho Branch.

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đề tài luận văn "Pháp luật về bảo lãnh Ngân hàng – Thực trạng áp dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội, Chi nhánh Cần Thơ" là do bản thân tôi thực hiện, không do người khác làm thay, các tài liệu tham khảo được tôi xem xét, chọn lọc kỹ lưỡng, trích dẫn và liệt kê tài liệu tham khảo đầy đủ, đảm bảo tính chính xác và trung thực. Kết quả nêu ra trong luận văn và được hoàn thành dựa trên các kết quả nghiên cứu của tôi và các kết quả nghiên cứu này chưa được dùng cho bất cứ luận văn cùng cấp, cùng phạm vi MBCT nào khác.

Tôi xin lấy danh dự và uy tín của bản thân để đảm bảo cho lời cam đoan này.

Cần Thơ, ngày 30 tháng 7 năm 2024

Người hướng dẫn	Học viên
TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh	Nguyễn Hồng Quân
PGS.TS. Đoàn Thị Phương Diệp	

MỤC LỤC

CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG i
LỜI CẢM ƠN ii
TÓM TẮT iii
ABSTRACT iv
LỜI CAM ĐOAN v
MỤC LỤC vi
DANH SÁCH BẢNG, HÌNH, SƠ ĐỒ viii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN, PHÁP LUẬT VÀ THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI, CHI NHÁNH CẦN THƠ 8
1.1. Khái quát chung về bảo lãnh của ngân hàng 8
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại về bảo lãnh của ngân hàng 8
1.1.2. Các rủi ro trong hoạt động bảo lãnh của ngân hàng thương mại 19
1.2. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của pháp luật về bảo lãnh ngân hàng 21
1.2.1. Khái niệm pháp luật về bảo lãnh ngân hàng 21
1.2.2. Đặc điểm của pháp luật về bảo lãnh ngân hàng 22
1.2.3. Vai trò của pháp luật về bảo lãnh ngân hàng 26
1.3. Pháp luật và thực trạng áp dụng pháp luật về bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân Đội, Chi nhánh Cần Thơ 28
1.3.1. Khái quát một số đặc điểm của Ngân hàng TMCP Quân Đội, Chi nhánh Cần Thơ 28
1.3.2. Pháp luật và thực trạng áp dụng pháp luật về bảo lãnh, giải quyết tranh chấp của ngân hàng thương mại và cơ sở pháp lý thực hiện hoạt động bảo lãnh tại MBCT 31
Kết luận chương 1 42
CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN ÁP DỤNG, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG TỪ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI, CHI NHÁNH CẦN THƠ 43
2.1. Những kết quả đạt được và một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo lãnh của ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội, Chi nhánh Cần Thơ 44
2.1.1. Những kết quả đạt được 44
2.1.2. Một số vướng mắc phát sinh trong thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo lãnh của ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội, Chi nhánh Cần Thơ 45

2.2. Định hướng hoàn thiện pháp luật về bảo lãnh của ngân hàng từ thực tiễn Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội, Chi nhánh Cần Thơ.....53
2.3. Các giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật và thực thi pháp luật về bảo lãnh của ngân hàng từ thực tiễn Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội, Chi nhánh Cần Thơ 54
2.3.1. Các giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về bảo lãnh của ngân hàng từ thực tiễn Ngân hàng TMCP Quân Đội, Chi nhánh Cần Thơ.....54
2.3.2. Các giải pháp bảo đảm thực thi pháp luật về bảo lãnh của ngân hàng từ thực tiễn Ngân hàng TMCP Quân Đội, Chi nhánh Cần Thơ.....61
Kết luận chương 2 65
KẾT LUẬN 66

DANH SÁCH BẢNG, HÌNH, SƠ ĐỒ

Số hiệu	Tên bảng	Trang
Bảng 1.1	Báo cáo số dư bảo lãnh từ năm 2020 - 2023	30
Biểu đồ 1.2	Tình hình số dư bảo lãnh từ năm 2020 - 2023	30
Sơ đồ 1.3	Quy trình bảo lãnh theo quy định chung của NHNN	36

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

BLDS	Bộ luật Dân sự
BLNH	Bảo lãnh ngân hàng
MB	Ngân hàng TMCP Quân đội
MBCT	Ngân hàng TMCP Quân đội, Chi nhánh Cần Thơ
NHNN	Ngân hàng Nhà nước
NHTM	Ngân hàng thương mại
QPPL	Quy phạm pháp luật
TCTD	Tổ chức tín dụng
ICC	Phòng thương mại quốc tế

LỜI NÓI ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Bảo lãnh ngân hàng (BLNH) là một trong các dạng hoạt động của ngân hàng, mang tính phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới và ngày càng phát triển mạnh mẽ. Trên thực tế hoạt động BLNH góp phần đáng kể trong việc thúc đẩy các hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho các chủ thể nói chung và giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế do nó tạo ra sự tin tưởng cho các bên giao kết hợp đồng, qua đó mang lại nhiều lợi ích cho các chủ thể tham gia và cho nền kinh tế nói chung.

Tại Việt Nam, hoạt động BLNH chính thức được quy định trong Quyết định số 192/NH-QĐ ngày 17/09/1992 của Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam về bảo lãnh, tái bảo lãnh vay vốn nước ngoài. Từ đó đến nay, hệ thống pháp luật về ngân hàng nói chung và pháp luật về hoạt động BLNH nói riêng luôn có sự kế thừa và phát triển. Hiện nay, hoạt động BLNH được quy định trong Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2023). Đạo luật này cùng với các văn bản pháp luật có liên quan đã tạo thành khung pháp luật điều chỉnh hoạt động BLNH, từng bước đưa hoạt động BLNH thực hiện đúng quy định của pháp luật, tạo niềm tin cho các chủ thể đối với các ngân hàng nói chung và các đối tác giao kết hợp đồng nói riêng và chế định bảo lãnh ngân hàng ngày càng được hoàn thiện.

Hoạt động của các ngân hàng thương mại không chỉ dừng lại ở việc huy động vốn và cho vay mà còn thực hiện hàng loạt các hoạt động khác như cho thuê tài chính, cung cấp dịch vụ, trong đó hoạt động bảo lãnh ngân hàng được xem là một trong những hoạt động hiệu quả mang lại lợi nhuận cao cho các ngân hàng thương mại cũng như đối với sự phát triển của cả nền kinh tế.

Cùng với quá trình hội nhập, đặc biệt là sau khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO), vai trò của các ngân hàng thương mại về việc thực hiện bảo lãnh đã góp phần không nhỏ trong quá trình thúc đẩy các giao dịch dân sự, kinh doanh thương mại trong và ngoài nước được thực hiện một cách nhanh chóng, hiệu quả. Điều đó thể hiện rõ nhất thông qua hoạt động bảo lãnh, giúp cho các tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện tham gia hàng loạt các giao dịch dân sự, kinh doanh thương mại, theo yêu cầu của bên đối tác. Từ những vấn đề nêu trên cho thấy, bảo lãnh của ngân hàng thương mại là một trong những hoạt động có vai trò to lớn đối với sự phát triển của nền kinh tế nói chung, đối với sự tồn tại và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp và cá nhân nói riêng. Nó được các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tin tưởng và sử dụng ngày càng rộng rãi, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giao dịch dân sự, thương mại được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, hoạt động bảo lãnh của các ngân hàng thương mại vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, bất cập, chưa phát huy được hiệu quả tối đa trong thực tiễn áp dụng. Nguyên nhân của bất cập được lí giải từ nhiều góc độ. Cụ thể, những quy định pháp luật còn chứa đựng nhiều bất cập, chồng chéo, mâu thuẫn; pháp luật về bảo lãnh không đáp ứng được nhu cầu điều chỉnh các loại giao dịch mới xuất hiện; trở ngại trong thực tiễn áp dụng; … hay từ chính biện pháp triển khai thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh của các ngân hàng thương mại nói chung và Ngân hàng TMCP Quân Đội, Chi nhánh Cần Thơ nói riêng.

Để luận giải cho vấn đề này và đưa ra những giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về bảo lãnh của ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt Nam, tháo gỡ những khó khăn trong thực tiễn áp dụng, đảm bảo cho hoạt động bảo lãnh phát huy hiệu quả trong đời sống, tác giả mạnh dạn lựa chọn đề tài: "Pháp luật về bảo lãnh Ngân hàng – Thực trạng áp dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội, Chi nhánh Cần Thơ", làm đề tài luận văn thạc sĩ luật học, chuyên ngành luật kinh tế của mình. Đề tài có tính cấp thiết, có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Thông qua đề tài, tác giả mong muốn làm sáng tỏ những vấn đề lý luận chung về bảo lãnh của ngân hàng thương mại với tư cách là một hình thức bảo đảm nghĩa vụ mà chủ thể bảo lãnh phải là các ngân hàng thương mại, từ đó rút ra bản chất pháp lý của bảo lãnh ngân hàng thương mại. Đồng thời, trên cơ sở kiến thức lý luận, tác giả đi vào phân tích những quy định của pháp luật liên quan và thực trạng áp dụng pháp luật về bảo lãnh của ngân hàng thương mại từ thực tiễn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội, Chi nhánh Cần Thơ. Qua đó, đưa ra những giải pháp và cơ chế thực hiện giải pháp, góp phần hoàn thiện biện pháp bảo lãnh của các Ngân hàng TMCP Quân đội, Chi nhánh Cần Thơ nói riêng và Ngân hàng TMCP Quân đội nói chung.

3. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài

Bảo lãnh của ngân hàng thương mại là một hình thức đảm bảo thực hiện nghĩa vụ, xuất hiện, tồn tại và phát triển song song với hoạt động cho vay tại các ngân hàng thương mại trong một khoảng thời gian khá dài. Vì vậy, trong thực tiễn nó không còn là một vấn đề xa lạ, mới mẻ.

Do đó, bảo lãnh ngân hàng là một trong những đề tài được nhiều tác giả lựa chọn nghiên cứu ở nhiều cấp độ khác nhau, trong đó có thể kể đến các công trình nghiên cứu như: - Đoàn Thị Phương Diệp, So sánh chế định bảo lãnh trong Bộ luật Dân sự năm 2015 và Pháp luật dân sự Pháp, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 7 (359), 2018 (Đồng tác giả). Công trình này đi sâu nghiên cứu phân tích, so sánh pháp luật Việt Nam với pháp luật Pháp về biện pháp "Bảo lãnh", trong đó có phần pháp luật về "Bảo lãnh ngân hàng"; Đoàn Thị Phương Diệp, Pháp luật hợp đồng Việt Nam nhìn ở góc độ so sánh với luật Cộng hòa Pháp Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 11 (387), 2019. Công trình này đi

sâu nghiên cứu phân tích, so sánh pháp luật Việt Nam với pháp luật Pháp – một hệ thống pháp luật khá tiên tiến và nhiều tương đồng, trong đó có phần pháp luật về hợp đồng; Đoàn Thị Phương Diệp, Giáo trình pháp luật về bảo đảm nghĩa vụ, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM, 2020 (Đồng tác giả). Công trình này nghiên cứu phân tích các quy định pháp luật Việt Nam về các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ, trong đó có biện pháp "Bảo lãnh"; Nguyễn Thị Mỹ Linh, Giáo trình Bảo đảm nghĩa vụ, NXB Trường Đại học Cần Thơ, 2018 (Đồng tác giả). Công trình này nghiên cứu về các quy định pháp lý về các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ trong luật Việt Nam, trong đó có phần phân tích bản chất các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ chủ yếu là bảo lãnh; Nguyễn Thị Mỹ Linh, The Development of Matrimonial Property Law in Vietnam in the Mirror of the Foreign Impacts, Volume 4, Publishing house University of Pecs, Hungary, 2023, 61-120. Công trình này đã nghiên cứu lý thuyết về tài sản trong hôn nhân, trong đó trang 61-72 của sách chuyên khảo phân tích khái quát về tài sản làm nên tảng khoa học cho các nghiên cứu về tài sản không chỉ trong lĩnh vực dân sự mà bao hàm các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực kinh tế. Cụ thể, tác giả còn chỉ ra những tranh chấp phát sinh từ thực tiễn đối với các giao dịch bảo đảm do vợ, chồng xác lập đối với tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân với bên thứ ba liên quan, từ đó đưa ra các giải pháp xử lý nhằm đảm bảo cho quyền lợi ích hợp pháp của các bên trong giao dịch bảo đảm. Ngoài ra, tác giả còn đề cập đến những vấn đề pháp lý về hợp đồng nhằm chỉ ra vai trò của hợp đồng trong các quan hệ xã hội phát sinh từ đời sống bao gồm cả sự xuất hiện của hợp đồng hôn nhân tại Việt Nam và các nước trên thế giới tại trang 110-120 của sách chuyên khảo; Nguyễn Thị Mỹ Linh, Hoàn thiện pháp luật về giao kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam: Cơ chế minh bạch thông tin đối với khách hàng, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số 154 (215), 2024 (kì 2), (Đồng tác giả). Công trình này nghiên cứu về các quy định pháp lý về hợp đồng bảo hiểm, giao kết hợp đồng bảo hiểm, thực tiễn giao kết hợp đồng bảo hiểm và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về giao kết hợp đồng bảo hiểm hướng đến cơ chế minh bạch thông tin cho khách hàng. Trong đó, có phân tích phần bản chất pháp lý của hợp đồng.

Các công trình nghiên cứu nêu trên đều có các phần liên quan đến đề tài. Đây là các cơ sở lý thuyết nhằm định hướng chuyên môn cho đề tài: "Pháp luật về bảo lãnh Ngân hàng – Thực trạng áp dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội, Chi nhánh Cần Thơ".

- Nguyễn Hồng Nhung (2022), "Một số vấn đề pháp lý về bảo lãnh ngân hàng trong mua, bán nhà ở hình thành trong tương lai và giải pháp hoàn thiện", Tạp chí Điện tử Luật sư Việt Nam. Bài viết phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật về mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, nêu ra một số vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật về mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, trong đó có hoạt động bảo lãnh của ngân hàng, từ đó đưa ra một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về mua bán nhà ở hình thành trong tương lai.

- Nguyễn Thành Nam (2015), "Hoàn thiện pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng ở Việt Nam", Luận án tiến sĩ luật học, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Luận án tập trung xây dựng các khái niệm về bảo lãnh ngân hàng, hoạt động bảo lãnh ngân hàng phù hợp với bản chất pháp lý của hoạt động bảo lãnh ngân hàng, xác định cụ thể các nội dung của hoạt động bảo lãnh ngân hàng, chỉ ra các rủi ro phát sinh đối với từng chủ thể tham gia hoạt động bảo lãnh ngân hàng. Luận án cũng xác định các nguyên tắc cơ bản của hoạt động bảo lãnh ngân hàng, xác định nội dung pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng và chỉ ra các yếu tố chi phối đến pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng. Phân tích những bất cập của quy định pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng, chủ thể thực hiện hoạt động bảo lãnh ngân hàng, hợp đồng cấp bảo lãnh ngân hàng, hợp đồng bảo lãnh ngân hàng và giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động bảo lãnh ngân hàng. Đề ra một số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng ở Việt Nam.

- Đặng Thùy Linh (2017), "Hoàn thiện pháp luật bảo lãnh ngân hàng ở Việt Nam từ thực tiễn áp dụng pháp luật tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn" , Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội. Luận văn đã nghiên cứu những vấn đề lý luận và pháp luật về bảo lãnh ngân hàng. Luận văn tập trung phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật về bảo lãnh ngân hàng đối với các tổ chức tính dụng, trong đó tập trung vào các quy định của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25/6/2015 Quy định về bảo lãnh ngân hàng, đồng thời nghiên cứu thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo lãnh ngân hàng tại ngân hàng SHB. Trên cơ sở đánh giá những hạn chế còn tồn tại trong các quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật tại ngân hàng SHB, từ đó đưa ra một số đề xuất và giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi các quy định về bảo lãnh ngân hàng.

- Đặng Thị Ngọc Ánh (2017), "Nghiên cứu tình trạng pháp lý của ngân hàng bảo lãnh trong giao dịch bảo lãnh ngân hàng theo pháp luật Việt Nam", Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội. Luận văn phân tích, luận giải làm rõ các vấn đề lý luận về tình trạng pháp lý của ngân hàng bảo lãnh trong quan hệ bảo lãnh ngân hàng, cụ thể là về các quyền và nghĩa vụ của ngân hàng bảo lãnh trong mối quan hệ pháp lý với các chủ thể khác trong giao dịch bảo lãnh ngân hàng, những bất cập trong các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của ngân hàng bảo lãnh, từ đó đưa ra một số giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về bảo lãnh ngân hàng nói chung và quy định về tình trạng pháp lý của ngân hàng bảo lãnh nói riêng.

- Võ Hoàng Quân (2018), "Bảo lãnh của ngân hàng thương mại đối với trách nhiệm của nhà thầu trong đấu thầu xây lắp theo pháp luật Việt Nam", Luận án tiến sĩ luật học, Học viện Khoa học xã hội. Luận án làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của pháp luật về bảo lãnh của ngân hàng thương mại đối với trách nhiệm của nhà thầu trong đấu thầu xây lắp, đánh giá thực trạng pháp luật và thực hiện pháp luật về bảo lãnh của ngân hàng thương mại đối với trách nhiệm của nhà thầu trong đấu thầu xây lắp ở Việt Nam

trong thời gian qua, chỉ ra những nhược điểm và nguyên nhân cả về nhận thức và quá trình thực hiện pháp luật đồng thời đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về bảo lãnh của ngân hàng thương mại đối với trách nhiệm của nhà thầu trong đấu thầu xây lắp ở Việt Nam, phù hợp với đặc điểm bảo lãnh của ngân hàng thương mại đối với trách nhiệm của nhà thầu trong đấu thầu xây lắp, thúc đẩy chính sách phát triển các quan hệ tín dụng ngân hàng, đầu tư xây dựng cơ bản trong nền kinh tế ngày càng phát triển.

- Đường Văn Cảnh (2022), "Pháp luật về biện pháp bảo lãnh trong thực hiện hợp đồng vay, qua thực tiễn của Ngân hàng thương mại Việt Nam", Luận văn thạc sĩ luật học, Trường đại học Huế. Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu biện pháp bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện hợp đồng vay theo BLDS 2015 và các văn bản liên quan, đề xuất các định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về biện pháp bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện hợp đồng vay tại các NHTM.

Ngoài ra, còn có thể kể đến một số đề tài của các tác giả khác như: Bùi Thị Quỳnh Hoa (2017), "Phát triển dịch vụ bảo lãnh tại ngân hàng TMCP Quân đội", Luận văn thạc sĩ, Trường đại học Kinh tế Quốc dân; Trần Thị Hồng Linh (2019), "Hoàn thiện nghiệp vụ bão lãnh tại ngân hàng TMCP Quân đội", Luận văn thạc sĩ, Trường đại học Ngoại thương,… Chỉ tập trung nghiên cứu, phân tích các biện pháp bảo lãnh ngân hàng dưới góc độ chuyên ngành kinh tế, đồng thời đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện nghiệp vụ ngân hàng.

Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu như liệt kê ở trên cơ bản đã cũ, nhiều văn bản, tài liệu nghiên cứu trong các công trình tính đến thời điểm hiện tại (năm 2023) đã hết hiệu lực hoàn toàn hoặc bị sửa đổi, bổ sung thay thế, không còn phù hợp với tình hình hoạt động bảo lãnh của các ngân hàng thương mại nói chung và của ngân hàng TMCP Quân đội nói riêng ở thời điểm hiện tại, nhất là từ khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 11/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2023 Quy định về bảo lãnh ngân hàng, thì có nhiều vấn đề mới phát sinh. Do đó, việc nghiên cứu một cách toàn diện và hệ thống pháp luật về bảo lãnh ngân hàng theo các quy định của pháp luật mới hiện nay xuất phát chính từ thực tế áp dụng tại một ngân hàng như Ngân hàng TMCP Quân Đội, Chi nhánh Cần Thơ là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Hiện tại, chưa có công trình nghiên cứu nào chuyên sâu ở cấp độ thạc sỹ chuyên ngành Luật kinh tế với đề tài: "Pháp luật về bảo lãnh Ngân hàng – Thực trạng áp dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội, Chi nhánh Cần Thơ". Đề tài nghiên cứu thực trạng cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật về hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội, Chi nhánh Cần Thơ liên quan đến một số loại bảo lãnh thường gặp đi từ thực tiễn Ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh tại Cần Thơ, mà không xem xét đến hoạt động bảo lãnh thông thường trong lĩnh vực dân sự, từ đó đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về hoạt động bảo lãnh của ngân hàng TMCP Quân đội, Chi nhánh Cần

Thơ nói riêng và của Ngân hàng TMCP Quân đội nói chung.

4. Câu hỏi nghiên cứu

Để luận văn đảm bảo được các yêu cầu và mục tiêu nghiên cứu đặt ra, thì luận văn cần phải làm rõ những nội dung theo những câu hỏi sau:

- Khái niệm, đặc điểm và vai trò của pháp luật về bảo lãnh của ngân hàng được quy định như thế nào? Các rủi ro trong hoạt động bảo lãnh của ngân hàng thường gặp là những loại rủi ro nào?

- Quy định của pháp luật cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật trong quá trình xác lập, thực hiện và giải quyết tranh chấp phát sinh từ bảo lãnh của ngân hàng thương mại như thế nào?

- Thực trạng hoạt động bảo lãnh ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội, Chi nhánh Cần Thơ?

- Giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển hệ thống pháp luật về bảo lãnh ngân hàng nói chung và hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân Đội, Chi nhánh Cần Thơ nói riêng là gì?

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

5.1. Đối tượng nghiên cứu

- Pháp luật hiện hành liên quan đến các hoạt động bảo lãnh của ngân hàng thương mại.

- Thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật trong quá trình xác lập, thực hiện và giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan đến hoạt động bảo lãnh của ngân hàng thương mại từ thực tiễn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Cần Thơ.

5.2. Phạm vi nghiên cứu

Bảo lãnh ngân hàng là một vấn đề rộng và phức tạp. Trong phạm vi luận văn này, tác giải không thể đề cập hoặc phân tích tất cả các loại bảo lãnh của ngân hàng và cũng không xem xét đến hoạt động bảo lãnh thông thường trong lĩnh vực dân sự mà chỉ tập trung phân tích một số vấn đề lý luận cơ bản và bảo lãnh ngân hàng, xem xét các nội dung của pháp luật về bảo lãnh ngân hàng đối với Ngân hàng TMCP Quân đội, Chi nhánh Cần Thơ, trong đó tập trung vào các quy định của Luật Tổ chức tín dụng 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung các năm 2017, 2023) và

Thông tư số 11/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2023 Quy định về bảo lãnh ngân hàng, đồng thời nghiên cứu thực trạng cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật về hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội, Chi

nhánh Cần Thơ liên quan đến một số loại bảo lãnh thường gặp. Trên cơ sở đánh giá những hạn chế còn tồn tại và thực tiễn áp dụng tại TMCP Quân đội, Chi nhánh Cần Thơ, từ đó đề xuất những giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo lãnh của Ngân hàng TMCP Quân đội, Chi nhánh Cần Thơ nói riêng và của Ngân hàng TMCP Quân đội nói chung.

6. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài, tác giả sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu để luận giải vấn đề như: phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu dựa trên cơ sở các bài viết, công trình nghiên cứu, pháp luật nhà nước. Đồng thời, tiến hành phân tích, đánh giá dữ liệu để chứng minh những vấn đề hợp lý và chưa hợp lý giữa những quy định của pháp luật hiện hành và thực tiễn của vấn đề đặt ra.

- Phương pháp phân tích, tổng hợp: Được sử dụng trong toàn bộ nội dung Luận văn, từ nghiên cứu, phân tích, đánh giá quy định của pháp luật và các văn bản có liên quan đến hoạt động bảo lãnh ngân hàng, thực trạng áp dụng pháp luật về bảo lãnh ngân hàng từ thực tiễn Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Cần Thơ, từ đó tìm ra các điểm bất cập và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động bảo lãnh của ngân hàng.

- Phương pháp so sánh: Được sử dụng nhằm so sánh, đánh giá bản chất pháp lý trong các quy định có liên quan đến đề tài nghiên cứu. Phương pháp này được sử dụng chủ yếu ở Chương 1 và Chương 2 nhằm đối chiếu, so sánh các quy định của pháp luật, trên cơ sở các bài viết, công trình nghiên cứu liên quan đến bảo lãnh ngân hàng.

- Phương pháp phân tích dữ liệu thứ cấp: Tiến hành thu thập, thống kê, phân loại số liệu báo cáo về kết quả áp dụng biện pháp bảo lãnh trong thực hiện hợp đồng vay tại các ngân hàng thương mại. Phương pháp này được sử dụng ở Chương 2.

Trên cơ sở các phương pháp nghiên cứu nêu trên, trong quá trình thực hiện và hoàn thiện Luận văn, tác giả có thể vận dụng linh hoạt từng phương pháp nghiên cứu sao cho đề tài đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao nhất.

CHƯƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN, PHÁP LUẬT VÀ THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI, CHI NHÁNH CẦN THƠ

Một trong những hoạt động mang lại nguồn doanh thu lớn cho các ngân hàng thương mại nói chung và Ngân hàng TMCP Quân đội nói riêng, chính là hoạt động bảo lãnh. Hiện nay, có sự đa dạng trong các công trình nghiên cứu liên quan đến hoạt động bảo lãnh của ngân hàng. Tuy vậy, phần lớn các công trình này tập trung vào khía cạnh về nghiệp vụ bảo lãnh. Những nội dung lý luận về hoạt động bảo lãnh tại các công trình này mang lại giá trị tham khảo quý giá cho việc nghiên cứu về pháp luật và thực trạng của hoạt động bảo lãnh.

Trong chương 1 này, khái niệm về BLNH sẽ được trình bày một cách tổng quan, các quy định pháp lý liên quan sẽ được đề cập và tình hình thực tế về việc áp dụng pháp luật về bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội, Chi nhánh Cần Thơ sẽ được phân tích kỹ lưỡng và đánh giá. Các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện pháp luật về bảo lãnh tại MBCT sẽ được xem xét để từ đó có thể đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật về BLNH trong chương 2 tiếp theo.

1.1. Khái quát chung về bảo lãnh của ngân hàng

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại về bảo lãnh của ngân hàng

1.1.1.1 Khái niệm bảo lãnh ngân hàng

Trong cuộc sống hàng ngày, khi nói đến việc bảo lãnh, thường được cho rằng bảo lãnh (guarantee) là việc một người nào đó được bảo đảm trước một người khác về việc thực hiện nghĩa vụ thay cho người đó. Dưới cái nhìn này, bảo lãnh được coi là hành vi mà một người cam kết trước một người khác về việc thực hiện nghĩa vụ thay cho một bên khác nếu bên đó không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình[1]. Theo pháp luật, khái niệm về bảo lãnh cũng đã được ghi nhận ở nhiều quốc gia trên toàn cầu như:

Trong pháp luật Nhật Bản: "Người bảo lãnh có nghĩa vụ phải thực hiện trái vụ trong trường hợp người thụ trái chính vỡ nợ"[2].

Pháp luật Pháp quy định: "Người nhận bảo lãnh một nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ đó đối với người có quyền nếu chính người có nghĩa vụ không thi hành"[3].

---

[1] Jakimovski, Z. (2020, December). Bank guarantee as a mean of security in freight forwarding. In *Proceedings of the International Scientific Conference" Social Changes in the Global World"* (Vol. 1, No. 3, pp. 69-81).
[2] Điều 446, Bộ luật Dân sự Nhật Bản.
[3] Nhà pháp luật Việt – Pháp, Bộ luật Dân sự Cộng hòa Pháp. (1998). NXB Chính trị quốc gia. Điều 2011

Hiểu một cách chung nhất, bảo lãnh là việc người thứ ba (sau đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (sau đây gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (sau đây gọi là bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ[4]. Các bên cũng có thể thoả thuận về việc bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ khi bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình (Điều 361 BLDS năm 2005). Theo pháp luật dân sự hiện hành quy định: *"Bảo lãnh là việc người thứ ba (sau đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (sau đây gọi là bên được bảo lãnh) nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ"*[5].

Như vậy, các quy định hiện hành của nước ta về bảo lãnh là kế thừa các quy định của Pháp lệnh hợp đồng dân sự kết hợp với Bộ luật Dân sự. Sự kết hợp này cũng xuất phát từ việc quy định tính chất tự nguyện, thỏa thuận là nguyên tắc cơ bản trong các quan hệ pháp luật dân sự ở nước ta.

Trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng, bảo lãnh cũng là biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo đó các ngân hàng (hoặc các TCTD) đứng ra bảo đảm (cam kết) trước người có quyền rằng người có nghĩa vụ (con nợ) sẽ thực hiện nghĩa vụ (trả nợ). Nếu người có nghĩa vụ không thực hiện thì ngân hàng sẽ trả thay. Tuy thừa nhận BLNH là loại hành vi bảo đảm do các ngân hàng thực hiện, nhưng tùy theo cách tiếp cận và điều kiện cụ thể của mỗi nước, mỗi tác giả, đến nay còn tồn tại nhiều quan điểm khác nhau về BLNH. Các quan điểm khác nhau này đều tồn tại ở cả Việt Nam và nước ngoài[6].

Từ cuối những năm 70 của thế kỷ trước, ở các nước, bảo lãnh do các ngân hàng nói chung, NHTM nói riêng thực hiện đã tương đối phát triển[7]. Điều 5 Bộ luật Thương mại Mỹ quy định nghĩa vụ của người phát hành tín dụng thư hoặc bảo lãnh độc lập là sẽ thanh toán chứng từ xuất trình theo đúng tiêu chuẩn thực hành. Điều này còn thể hiện ở Bản quy tắc số 325 về bảo lãnh hợp đồng (ban hành năm 1978), Bản quy tắc số 458 về bảo lãnh theo yêu cầu (ban hành năm 1992) do Phòng thương mại Quốc tế Pari ban hành. Trong các quy tắc thống nhất về bảo lãnh theo yêu cầu (URDG-ICC458) của Phòng thương mại Quốc tế ICC quy định: *Bảo lãnh độc lập là bất cứ bảo lãnh cam kết hay cam kết thanh toán, dù được gọi hay miêu tả như thế nào, của ngân hàng, công ty bảo hiểm hay pháp nhân hoặc thể nhân bằng văn bản thanh toán một số tiền khi được xuất trình theo đúng quy định cam kết, bản đòi tiền và các chứng từ khác"*.

---

[4] Bộ Tư pháp & Viện Khoa học pháp lý. (2006). *Từ điển Luật học*, NXB. Tư pháp, tr.52

[5] Bộ luật Dân sự. (2015), Điều 365

[6] Jakimovski, Z. (2020). Legal Regulation of the Bank Guarantee as a Mean of Security under the Macedonian and Comparative Law. *Iustinianus Primus L. Rev.*, *11*, 1.

[7] Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng - BCBS (1986)

Khi nghiên cứu các tập quán quốc tế về bảo lãnh, chúng ta còn biết đến thuật ngữ " bảo lãnh trả tiền ngay" (hay "bảo lãnh theo yêu cầu"- demand guarantee). Bảo lãnh trả tiền ngay hay bảo lãnh dù được gọi tên hoặc mô tả thế nào, có nghĩa là một cam kết được phát hành làm cơ sở cho việc thanh toán theo một yêu cầu đòi tiền phù hợp"[8]. URDG 758 cũng mô tả một yêu cầu đòi tiền được coi là phù hợp khi nó được xuất trình phù hợp với: "(i) các điều khoản của bảo lãnh, (ii) các quy tắc trong URDG với điều kiện các quy tắc này nhất quán với các điều khoản của bảo lãnh, và (iii) nếu trong bảo lãnh hoặc URDG không có quy định thì phải phù hợp với thông lệ bảo lãnh trả tiền ngay theo chuẩn mực quốc tế. So với URDG 458, URDG 758 đã bổ sung thêm các trường hợp thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh khi nội dung của cam kết bảo lãnh không tính đến nhưng vẫn phù hợp với các điều khoản tại URDG và thực hiện thông lệ quốc tế".Việc bổ sung này là nhằm bảo vệ cho quyền lợi của người thụ hưởng tránh việc bên bảo lãnh viện cớ nội dung cam kết bảo lãnh không quy định cụ thể để từ chối thanh toán[9].

Ở nước ta, bảo lãnh của ngân hàng nói chung đã được đề cập trong các văn bản pháp luật. Trước đây, bảo lãnh ngân hàng thực chất chỉ do Ngân hàng nhà nước thực hiện và được sử dụng như công cụ hỗ trợ cho doanh nghiệp nhà nước vay vốn nước ngoài để sản xuất, kinh doanh. Bảo lãnh của NHTM chỉ xuất hiện khi các NHTM ra đời giai đoạn sau này.

Nhằm luật hóa khái niệm về BLNH, Luật Các TCTD quy định: *"Bảo lãnh ngân hàng là hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc tổ chức tín dụng sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng khi khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết; khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho tổ chức tín dụng theo thỏa thuận"*[10]. Ngoài ra, Điều 3 khoản 1 của Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25/6/2015 (được sửa đổi bởi Thông tư số 13/2017/TT-NHNN ngày 29/9/2017) của Ngân hàng nhà nước quy định về bảo lãnh ngân hàng cũng ghi nhận: *"Bảo lãnh ngân hàng là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên bảo lãnh cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh khi bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh; bên được bảo lãnh phải nhận nợ và hoàn trả cho bên bảo lãnh"*. Đến Thông tư số 11 (thay thế cho Thông tư số: 07/2015/TT-NHNN ngày 25/6/2015) của Ngân hàng nhà nước quy định về bảo lãnh ngân hàng đưa ra khái niệm chi tiết, rõ ràng hơn: *"Bảo lãnh ngân hàng là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên bảo lãnh là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh khi bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh; bên được bảo lãnh phải nhận nợ và hoàn trả cho bên bảo lãnh*

[8] ICC. (2010). *Uniform Rules for Demand Guarantees No.758 (URDG 758), ICC Publication*, Paris, Điều 2
[9] Jus, M. (1989). Bank Guarantees: Their Legal Nature, Effects and Insurance Value. *Pravnik, 44*, 283.
[10] Luật Các Tổ chức tín dụng. (2010), Điều 4

theo thỏa thuận đã ký"[11]. Mới đây nhất là Luật Các TCTD năm 2024, được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 18/01/2024 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 quy định: *Bảo lãnh ngân hàng là hình thức cấp tín dụng cho khách hàng thông qua việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên có nghĩa vụ khi bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết; khách hàng phải nhận nợ bắt buộc và hoàn trả cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo thỏa thuận"*[12]. So sánh với các quy định trước đây thì Luật Các TCTD năm 2024 đưa ra khái niệm BLNH chi tiết, rõ ràng hơn về bên nhận bảo lãnh là khách hàng và bổ sung thêm chủ thể bảo lãnh đó là chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Xuất phát từ khái niệm BLNH nêu trên, đã nhấn mạnh đến hai đặc trưng cơ bản của BLNH. Đó là:

Thứ nhất, BLNH là một hành vi. Đó là hành vi cam kết của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính cho khách hàng nếu nghĩa vụ đó bị vi phạm.

Thứ hai, BLNH là một hợp đồng. Đó là hợp đồng cấp bảo lãnh giữa TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với khách hàng, trong đó nhấn mạnh yếu tố thỏa thuận giữa TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách hàng về việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh và hoàn trả theo thỏa thuận.

So sánh hai khái niệm: Bảo lãnh và BLNH theo quy định của pháp luật Việt Nam, chúng ta thấy nếu như bảo lãnh nói chung được xác định là một biện pháp (giao dịch) bảo đảm thì BLNH vừa được xác định là biện pháp bảo đảm nhưng cũng vừa được xác định là một hình thức cấp tín dụng.

Như vậy, ở Viêt Nam, BLNH được coi là một dạng đặc biệt của bảo lãnh, nó do các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện và mang tính độc lập so với hợp đồng cơ sở (hợp đồng được giao kết giữa bên được bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh).

Rõ ràng, khi thực hiện cam kết về cấp bảo lãnh, các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải chịu một mức độ rủi ro nhất định. Đó là khi khách hàng vi phạm nghĩa vụ với bên có quyền thì TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bảo lãnh phải thực hiện thay, ngân hàng bảo lãnh phải xuất quỹ của mình và khoản trả thay này trở thành một khoản nợ. Việc khách hàng phải nhận nợ và thanh toán cho TCTD bao gồm cả khoản nợ TCTD đã trả thay và khoản nợ lãi hoặc số tiền nhất định theo thỏa thuận. Điều này cho thấy sự phù hợp với thực tế hơn so với khái niệm trước đây quy định khách hàng chỉ hoàn trả lại cho TCTD số tiền đã được trả thay. Cho nên, có thể nói bảo lãnh NHTM vừa là biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ, vừa là một hình thức cấp tín dụng.

1.1.1.2 Đặc điểm bảo lãnh ngân hàng

[11] Ngân hàng Nhà nước. (2022). *Thông tư số 11/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 của Ngân hàng Nhà nước quy định về bảo lãnh Ngân hàng*. Hà Nội, khoản 1 Điều 3

[12] Luật Các Tổ chức tín dụng. (2024), khoản 2 Điều 4

Thứ nhất, về cơ bản thì BLNH giống với hoạt động bảo lãnh thông thường hay các biện pháp bảo đảm hợp đồng tín dụng ở chỗ cùng có 3 bên tham gia quan hệ bảo lãnh, đó là bên bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh và bên được bảo lãnh. Tuy nhiên, nếu bên bảo lãnh trong hoạt động bảo lãnh thông thường có thể là cá nhân hay tổ chức cam kết thực hiện bảo lãnh thì bên bảo lãnh trong quan hệ BLNH chỉ có một loại chủ thể duy nhất là các tổ chức tín dụng (trong đó NHTM là cơ bản) hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện các hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật. Quy định này nhằm mục đích đảm bảo sự an toàn về quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia quan hệ bảo lãnh nói chung của bên nhận bảo lãnh (chủ nợ) nói riêng[13].

Theo tác giả Lê Nguyên, *c*ó hai quan điểm khác nhau về vấn đề này:

Quan điểm thứ nhất cho rằng: bảo lãnh là cam kết một bên, hiệu lực ràng buộc của cam kết này bắt đầu từ khi ngân hàng phát hành thông báo cam kết thanh toán cho người nhận bảo lãnh. Thông báo này là nội dung của bảo lãnh và kèm theo những điều kiện của bảo lãnh. Do vậy, sự chấp thuận của người nhận bảo lãnh là không cần thiết.

Quan điểm thứ hai cho rằng: Bảo lãnh chỉ bắt đầu có hiệu lực khi có được sự đồng ý của cả hai bên: ngân hàng phát hành bảo lãnh và người nhận bảo lãnh. Quan điểm này cũng thừa nhận việc chấp nhận "ngầm hiểu". Việc người nhận bảo lãnh không phản đối những điều khoản của bảo lãnh hay việc người nhận bảo lãnh yêu cầu thanh toán bảo lãnh là hoạt động chấp nhận (ngầm hiểu) bảo lãnh của người nhận bảo lãnh. Nhưng đứng về khía cạnh của ngân hàng phát hành bảo lãnh thì trách nhiệm bảo lãnh của nó bắt đầu từ lúc nó phát hành bảo lãnh[14]

Trong thực tiễn pháp lý, quan điểm coi bảo lãnh là một quan hệ hợp đồng là tư tưởng pháp lý phổ biến. Tác giả, Võ Đình Toàn cho rằng: "BLDS xác định các bên có thể thỏa thuận về việc người bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ khi người được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình. Với nội dung như vậy, BLDS đã thể hiện rõ là quan hệ bảo lãnh phát sinh trên cơ sở cam kết bảo lãnh mà bên bão lãnh đưa ra thì không nên xem đó chỉ là cam kết đơn phương mà về bản chất pháp lý đó là văn bản dự thảo hợp đồng, nếu không được bên phát sinh trên cơ sở thỏa thuận từ việc đưa ra cam kết của người bảo lãnh. Sự ghi nhận yếu tố thỏa thuận này chứng tỏ quan hệ bảo lãnh không phát sinh mang tính đơn phương bằng cam kết của riêng bên bảo lãnh". Trên cơ sở đó, tác giả Võ Đình Toàn đã kết luận rằng: "Sự thỏa thuận giữa bên bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh là điều kiện bắt buộc để thiết lập quan hệ bảo lãnh. Đối với cam kết bảo lãnh mà bên bảo lãnh đưa ra thì không nên xem đó chỉ là cam kết đơn phương

[13] Kyomugisha, K. (2015). *The enforcement of bank guarantee as a form of security: an examination of the law and practice in Uganda* (Doctoral dissertation, Kampala International University, School of Law).
[14] Lê Nguyên. (2017). *Bảo lãnh ngân hàng và tín dụng dự phòng.* Nxb.Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh, tr 44-45.

mà về bản chất pháp lý đó là văn bản hợp đồng, nếu không được bên nhận bảo lãnh chấp nhận thì quan hệ bảo lãnh không được thiết lập"[15].

Thứ hai, bảo lãnh NHTM là nghiệp vụ được xác lập và thực hiện trên cơ sở chứng từ. Đặc điểm này thể hiện ở chỗ, trong quá trình tham gia quan hệ bảo lãnh, NHTM đồng thời thiết lập hợp đồng dịch vụ cấp bảo lãnh (với khách hàng đề nghị bảo lãnh) và hợp đồng bảo lãnh (với bên nhận bảo lãnh). Cả hai loại hợp đồng này đều bắt buộc thiết lập bằng văn bản, ghi nhận các điều khoản, nội dung thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ bảo lãnh.

Tính chứng từ còn thể hiện ở cam kết bảo lãnh. Cam kết bảo lãnh phải được lập thành văn bản: Văn bản bảo lãnh có thể là thư, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng bảo lãnh điện tử như Email, ứng dụng ngân hàng điện tử, SWIFT... nội dung văn bản bảo lãnh phải thể hiện được sự cam kết của ngân hàng đối với bên nhận bảo lãnh[16].

Mặt khác, tính chứng từ còn thể hiện ở chỗ, bên bảo lãnh chỉ thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh khi bên nhận bảo lãnh xuất trình được các chứng từ hợp lệ, trùng khớp với nội dung được ghi nhận trên cam kết bảo lãnh. Do đó, tính chứng từ không chỉ được xem là cơ sở pháp lý của quan hệ bảo lãnh, mà còn là cơ sở để NHTM xem xét thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh và thực hiện quyền truy đòi đối với bên được bảo lãnh sau khi đã thực hiện xong nghĩa vụ bảo lãnh.

Thứ ba, BLNH mang tính độc lập. Trong một nghiệp vụ, BLNH thường có sự kết hợp giữa 3 hợp đồng độc lập: Hợp đồng giữa bên được bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh (đây được xem như là hợp đồng cơ sở, hợp đồng chính), hợp đồng giữa bên được bảo lãnh và bên bảo lãnh, hợp đồng giữa bên nhận bảo lãnh và bên bảo lãnh (nếu có)[17].

Bảo lãnh ngân hàng có tính độc lập so với hợp đồng: Nghiệp vụ bảo lãnh độc lập tương đối với hợp đồng chính. Mục đích của BLNH là bồi hoàn cho bên nhận bảo lãnh những thiệt hại từ việc không thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng của người được bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh nhưng nó vẫn có một sự độc lập tương đối với hợp đồng chính. Việc thanh toán bảo lãnh chỉ hoàn toàn căn cứ vào các điều khoản và điều kiện ghi trong cam kết bảo lãnh của ngân hàng mà không căn cứ vào những quyền kháng nghị phát sinh trong hợp đồng chính.

Tính độc lập còn thể hiện ở trách nhiệm thanh toán của bên bảo lãnh. Trách nhiệm thanh toán của bên bảo lãnh hoàn toàn độc lập với quan hệ giữa bên bảo lãnh với bên được bảo lãnh. Bên bảo lãnh không thể đưa ra những lý do thuộc về quan hệ giữa họ với người được bảo lãnh để từ chối hoặc trì hoãn việc thanh toán nếu như chứng từ thanh

---

[15] Võ Đình Toàn. (2017). *Một số vấn đề về quan hệ bảo lãnh ngân hàng ở nước ta hiện nay.* Tạp chí luật học, Số 3/2017, tr.42.

[16] Lipartia, N. (2017). Analysis of Legal Nature of Bank Guarantees in the Light of the Principles of Autonomy and Strict Compliance. *J. Law*, 28.

[17] Mirkovic, P., & Minic, S. (2017). Legal Characteristics of Bank Guarantee and Certain Distinctions in Regard to Contract of Assurance. *Kultura Polisa, 14*, 531.

toán do bên nhận bảo lãnh xuất trình hoàn toàn phù hợp với điều khoản và điều kiện quy định tại cam kết bảo lãnh[18]. Ví dụ: "ngân hàng bảo lãnh không thể đưa ra các lý do như nội dung hợp đồng cấp bảo lãnh không chặt chẽ, hay người được bảo lãnh không thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết với ngân hàng bảo lãnh…"để từ chối thanh thoán bảo lãnh.

Thứ tư, BLNH là giao dịch không thể đơn phương hủy ngang. Tính chất không thể hủy ngang của BLNH thể hiện ở chỗ sau khi cam kết bảo lãnh đã được phát hành hợp lệ thì người bảo lãnh không có quyền tuyên bố đơn phương hủy bỏ cam kết bảo lãnh trừ khi nó được sự đồng ý của người nhận bảo lãnh. Đặc điểm này của BLNH được các học giả thừa nhận rộng rãi và được quy định tại URDG 758: "*Bảo lãnh không thể hủy bỏ sau khi phát hành thậm chí nếu nó không tuyên bố như vậy. Người thụ hưởng có thể xuất trình yêu cầu từ khi bảo lãnh được phát hành hoặc ngay khi nhận được bảo lãnh*"[19].

Có thể nói, BLNH là một hợp đồng mang tính độc lập và không thể đơn phương hủy ngang, được giao kết giữa người bảo lãnh là các ngân hàng, TCTD với người nhận bảo lãnh để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của người được bảo lãnh (là khách hàng của ngân hàng, TCTD) đối với người nhận bảo lãnh, theo đó người bảo lãnh cam kết thanh toán một khoản tiền xác định theo thỏa thuận khi người nhận bảo lãnh xuất trình các chứng từ phù hợp với điều khoản và trong thời hạn có hiệu lực của cam kết bảo lãnh[20].

Tuy nhiên, đặc điểm này chưa được phản ánh trong pháp luật thực định Việt Nam quy định về bảo lãnh nói chung và quan hệ BLNH nói riêng. Do đó, "chế định BLNH trong pháp luật Việt Nam thiếu sự tương đồng với pháp luật các nước, cũng như pháp luật quốc tế, tập quán và thông lệ quốc tế về bảo lãnh".

Thứ năm, về biện pháp thiết lập quan hệ bảo lãnh NHTM. Trong quy định của pháp luật dân sự, bảo lãnh tồn tại dưới hai dạng là bảo lãnh đối vật và bảo lãnh đối nhân. Trong thực tiễn áp dụng, quan hệ bảo lãnh thường được thiết lập bằng biện pháp bảo lãnh đối vật, chứ ít khi tồn tại biện pháp bảo lãnh đối nhân, bởi bảo lãnh mà không có tài sản để đảm bảo thì không có gì làm chắc chắn, thậm chí còn không được bên nhận bảo lãnh chấp nhận[21].

Tuy nhiên, đến BLDS năm 2005, BLDS năm 2015, pháp luật ghi nhận bảo lãnh là biện pháp đối nhân chứ không thừa nhận biện pháp bảo lãnh đối vật. Trường hợp bên bảo lãnh dùng tài sản thuộc sở hữu của mình đảm bảo thực hiện nghĩa vụ cho bên được bảo lãnh, được xem là một biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thông qua hình thức cầm cố, hoặc thế chấp, hoặc ký quỹ,…

---

[18] Nemeş, V. (2012). Bank Guarantees. *LESIJ-Lex ET Scientia International Journal*, *19*(2), 128-136.
[19] ICC. (2010). *Uniform Rules for Demand Guarantees No.758 (URDG 758), ICC Publication*. Paris, Điều 4
[20] Nielsen, J., & Nielsen, N. (2013). The German Bank Guarantee: Lesson to Be Drawn for China. *Geo. Mason J. Int'l Com. L.*, *5*, 171.
[21] Lê Vũ Nam. (2020). *Pháp luật về bảo đảm nghĩa vụ*. Nxb. ĐHQG-HCM, tr.105

Vì tính chuyên nghiệp và uy tín nên các NHTM có thể thực hiện bảo lãnh bằng hình thức bảo lãnh đối nhân, mà không cần phải dùng bất cứ tài sản nào để bảm bảo cho nghĩa vụ được bảo lãnh đối với bên nhận bảo lãnh. Điều này đã góp phần tạo điều kiện cho các quan hệ bảo lãnh được thiết lập và thực hiện một cách nhanh chóng, hạn chế về mặt thủ tục bàn giao tài sản đảm bảo. Sự khác biệt này thể hiện ở chỗ "đối với bên nhận bảo lãnh, chủ nợ (bên nhận bảo lãnh) bên cạnh người mắc nợ chính (bên được bảo lãnh) còn có một người mắc nợ thứ hai (NHTM bảo lãnh) không có tài sản đảm bảo. Đối với tài sản của NHTM, bên nhận bảo lãnh chỉ thực hiện quyền của một chủ nợ không có đảm bảo, việc bên nhận bảo lãnh yêu cầu bên được bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ không chú trọng đến biện pháp xử lý tài sản thuộc sở hữu của bên bảo lãnh. Ngược lại, đối với hoạt động bảo lãnh trong dân sự, việc bảo lãnh thường gắn liền với việc bên bảo lãnh chuyển giao cho bên nhận bảo lãnh một hoặc nhiều tài sản thuộc sở hữu để đảm bảo cho nghĩa vụ được bảo lãnh. Việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo lãnh chỉ giới hạn trong phạm vi giá trị tài sản đảm bảo cho bảo lãnh trong trường hợp bên bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ bảo lãnh.

Trong BLNH không phải mọi trường hợp quan hệ bảo lãnh chỉ tồn tại gồm 3 bên: NHTM bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh và khách hàng được bảo lãnh, trong một số trường hợp còn xuất hiện bên bảo lãnh của khách hàng được NHTM bảo lãnh, gọi là bên bảo lãnh đối ứng. Bên bảo lãnh đối ứng cam kết sẽ thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho bên được bảo lãnh đối với NHTM bảo lãnh (bên xác nhận bảo lãnh) chứ không phải đối với bên nhận bảo lãnh (chủ nợ của bên được bảo lãnh). Cho nên "việc thiết lập quan hệ bảo lãnh giữa Bên bảo lãnh đối ứng với NHTM bảo lãnh không có liên quan gì đến bên nhận bảo lãnh. Do đó, chỉ có NHTM bảo lãnh mới có quyền yêu cầu bên bảo lãnh đối ứng thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh không có quyền yêu cầu bên bảo lãnh đối ứng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.[22]

Như vậy "dù BLNH được thiết lập dưới hình thức bảo lãnh đơn giản hay có sự tham gia của bên bảo lãnh đối ứng thì quan hệ BLNH vẫn là hình thức bảo đảm đối nhân. Ở đây chỉ xem xét trong mối quan hệ giữa NHTM bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh, hoặc giữa NHTM bảo lãnh với bên bảo lãnh đối ứng" chứ không xem xét mối quan hệ giữa bên được bảo lãnh với NHTM bảo lãnh hoặc bên bảo lãnh đối ứng[23].

1.1.1.3 Phân loại bảo lãnh ngân hàng

Việc phân loại bảo lãnh của Ngân hàng thương mại tùy thuộc tùy thuộc vào các tiêu chí phân loại, cụ thể:

a. Theo đối tượng bảo lãnh

---

[22] Ngô Quốc Kỳ. (2015). *Hoàn thiện pháp luật hoạt động của Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam*. Nxb Tư pháp, Hà Nội

[23] Putriyanti, E. D. (2017). Legal Status of Credit Bank Guarantee in Indonesia's Legal Guarantee. *Sriwijaya Law Review, 1*(2), 128-141.

Gồm hai loại là "bảo lãnh ngân hàng trong nước (Bảo lãnh đối nội) và bảo lãnh ngân hàng ngoài nước (Bảo lãnh đối ngoại).

Bảo lãnh trong nước là loại bảo lãnh mà người yêu cầu bảo lãnh, người được bảo lãnh và ngân hàng bảo lãnh ở trong phạm vi một quốc gia. Các hình thức phổ biến là : bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tiền ứng trước..." được thực hiện qua việc ngân hàng phát hành thư bảo lãnh.

Bảo lãnh ngoài nước là loại hình bảo lãnh có liên quan đến yếu tố nước ngoài và thường sử dụng dưới một số trong các hình thức sau: "Mở thư tín dụng mua hàng trả chậm, ký bảo lãnh trên các hối phiếu nhận nợ với nước ngoài" phát hành thư bảo lãnh, lập giấy chứng nhận kỳ hạn nợ …[24].

b. Theo hình thức sử dụng

Bảo lãnh vô điều kiện: "Còn được gọi là bảo lãnh theo yêu cầu (Demand Guarantee). Đây là loại bảo lãnh trong đó việc thanh toán sẽ được thực hiện ngay sau khi ngân hàng nhận được yêu cầu đầu tiên của người nhận bảo lãnh và xem đó là một lệnh thanh toán không đòi hỏi phải có chứng từ kèm theo. Loại bảo lãnh này có tính độc lập cao nhất với các giao dịch khác kể cả hợp đồng cơ sở mà theo đó nó được phát hành. Người bảo lãnh không được viện dẫn bất cứ lý do gì để từ chối thanh toán. Loại bảo lãnh này được sử dụng rất phổ biến vì sự thuận tiện và lợi thế cho phía người hưởng và phù hợp với tập quán, thông lệ giao dịch của ngân hàng thương mại trên thế giới. Tuy nhiên mặt trái của nó là việc đòi bồi thường mang tính chủ quan, nên có thể xảy ra gian lận thậm chí lừa đảo nếu người nhận bảo lãnh là đối tác không trung thực[25].

Bảo lãnh có điều kiện: Đây là loại bảo lãnh mà người nhận bảo lãnh, nếu muốn được trả tiền phải xuất trình chứng từ do mình cung cấp, của phía thứ ba hoặc của Toà án để chứng minh sự vi phạm nghĩa vụ hợp đồng của đối tác. Loại bảo lãnh này gây ra sự chậm chễ trong thanh toán trả bồi thường cho người nhận bảo lãnh. Các ngân hàng cũng ngần ngại trong việc phát hành những bảo lãnh này vì họ có thể liên quan vào những tranh chấp phát sinh giữa các bên trong quan hệ hợp đồng. Với các điều kiện chứng từ như trên, về bản chất bảo lãnh có điều kiện rất tương đồng với nghiệp vụ bảo hiểm. Do kém linh hoạt và không hợp với thông lệ giao dịch ngân hàng nên bảo lãnh có điều kiện ít được sử dụng trong nghiệp vụ ngân hàng thương mại. Vì vậy với nhiều nước bảo lãnh này do các công ty bảo hiểm phát hành như ở Mỹ và Canada, hiện nay bảo lãnh có điều kiện chỉ được sử dụng nhiều ở khu Trung Đông" Bắc Phi mà ít được sử dụng ở châu Âu. Một số các nước khác chấp nhận dạng bảo lãnh pha trộn của hai dạng trên miễn là các bên yêu cầu và ngân hàng đồng ý phát hành[26].

c. Theo điều kiện bảo lãnh

---

[24] Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. (2015). *Giáo trình Luật Ngân hàng*. Nxb. Hồng Đức, tr.72

[25] Efimova, L. G. (2018). Legal Nature of an Independent (Bank) Guarantee. *Legal Concept= Pravovaya Paradigma*, *17*(4).

[26] Crmnext. (2022). *Axis Bank cùng đối tác CRMNEXT giành giải thưởng triển khai CRM tốt nhất từ Asian Banker Cision*, truy cập ngày 18/3/2024, tại.https://vn.prnasia.com/story/79482-11.shtml.

Bảo lãnh không hủy ngang: Là hình thức bảo lãnh mà theo đó bên bảo lãnh trong mọi trường hợp kể cả bất khả kháng cũng không được hủy ngang. Hay có thể nói đối với bảo lãnh không hủy ngang trong trường hợp có thay đổi về mặt thể chế chính trị, chiến tranh luật pháp ….. của nước có nơi bảo lãnh thì thư bảo lãnh vẫn có hiệu lực và bên nhận bảo lãnh vẫn có quyền truy đòi trong mọi trường hợp

Bảo lãnh hủy ngang: Khác với bảo lãnh không hủy ngang, bảo lãnh hủy ngang là trong trưởng hợp có sự thay đổi về mặt luật pháp, chiến tranh hoặc thể chế chính trị hoặc trong trường hợp bên được bảo lãnh vi phạm các điều kiện trong thỏa thuận cấp bảo lãnh hoặc bên nhận bảo lãnh không đáp ứng một số điều kiện của bên bảo lãnh thì thư bảo lãnh đó bị hủy ngang và hết hiệu lực

d. Theo phương thức phát hành bảo lãnh

Bảo lãnh trực tiếp: Là loại hình bảo lãnh đơn giản nhất, được thực hiện dựa trên mối quan hệ giữa 3 bên trong quan hệ bảo lãnh. Trong đó ngân hàng bảo lãnh cam kết thanh toán trực tiếp với người hưởng thụ, không cần phải qua một ngân hàng trung gian nào. Sau khi ngân hàng đã bồi thường cho người thụ hưởng bảo lãnh, ngân hàng có thể trực tiếp truy đòi bồi hoàn từ người được bảo lãnh. Ưu điểm của loại bảo lãnh này là người được bảo lãnh không phải mất thêm phí hoa hồng cho ngân hàng đại lý nước ngoài.

Bảo lãnh gián tiếp: Là loại bảo lãnh mà ngân hàng uỷ nhiệm cho một ngân hàng thứ hai ở nước người nhận bảo lãnh hoặc một ngân hàng trung gian khác mở tiếp bảo lãnh. Bảo lãnh này có lợi cho người nhận bảo lãnh do họ được thuận tiện hơn trong giao dịch hoặc đòi tiền sau này. Trong quan hệ này ngân hàng thứ nhất là ngân hàng chỉ dẫn, ngân hàng thứ hai là ngân hàng phát hành.

Cần lưu ý rằng chỉ ngân hàng thứ hai phát hành thư bảo lãnh trong khi ngân hàng thứ nhất chỉ hành động như ngân hàng chỉ dẫn và ngân hàng này không có bất cứ một quan hệ hợp đồng nào với người nhận bảo lãnh. Người nhận bảo lãnh không đòi tiền từ ngân hàng thứ nhất. Mối quan hệ giữa ngân hàng thứ nhất với ngân hàng thứ hai gần giống mối quan hệ giữa người được bảo lãnh và ngân hàng phát hành trong trường hợp bảo lãnh trực tiếp. Nghĩa vụ đền bù cho ngân hàng phát hành thường được quy định trong thư bảo lãnh đối ứng mà ngân hàng thứ nhất phát hành cho ngân hàng thứ hai được thụ hưởng. Theo đó, nếu ngân hàng phát hành phải trả tiền cho người nhận bảo lãnh theo đúng các điều khoản của thư bảo lãnh. Ngân hàng phát hành sẽ được ngân hàng chỉ dẫn bồi hoàn và ngân hàng chỉ dẫn sẽ đòi người được bảo lãnh[27].

Đối với hai loại hình bảo lãnh trên thì bảo lãnh trực tiếp được áp dụng phổ biến hơn ở Việt Nam, còn loại hình bảo lãnh gián tiếp ít được áp dụng tại Việt Nam.

đ. Theo mục đích của bảo lãnh

[27] Kocaman, A. B. (1989). On the Legal Nature of Bank Guarantee Letters. *Banka Huk. Dergisi, 15*, 49.

Đây là cách phân loại thông dụng nhất và cách này cho biết mục đích sử dụng của từng loại bảo lãnh. Các loại hình bảo lãnh theo cách phân loại này bao gồm:

Bảo lãnh dự thầu: Là cam kết của ngân hàng với chủ đầu tư sẽ trả tiền thay trong phạm vi thời hạn và số tiền bảo lãnh nếu bên dự thầu vi phạm quy chế dự thầu mà không nộp hoặc nộp không đủ số tiền phạt cho bên chủ đầu tư.

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng: Bảo lãnh thực hiện hợp đồng là cam kết của ngân hàng bảo lãnh về việc thực hiện hợp đồng của bên được bảo lãnh. Trong trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện hợp đồng mà không nộp hoặc không nộp đủ tiền phạt cho bên yêu cầu bảo lãnh thì ngân hàng bảo lãnh trả thay trong phạm vi số tiền và thời hạn bảo lãnh. Đây là loại bảo lãnh được dùng phổ biến nhất và có thể không phải yêu cầu một loại bảo lãnh nào khác ngoài nó trong quá trình mua bán hàng hoá hoặc dự thầu xây dựng.

Bảo lãnh đảm bảo hoàn trả tiền ứng trước: Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước là cam kết của bên bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh để bảo đảm nghĩa vụ hoàn trả tiền ứng trước của bên được bảo lãnh theo hợp đồng đã ký kết với bên nhận bảo lãnh. Trường hợp bên được bảo lãnh phải hoàn trả tiền ứng trước mà không hoàn trả hoặc hoàn trả không đầy đủ thì bên bảo lãnh sẽ thực hiện thay.

Bảo lãnh bảo hành hay bảo lãnh đảm bảo chất lượng sản phẩm theo hợp đồng: Là loại bảo lãnh ngân hàng cam kết với chủ thầu/ Nhà nhập khẩu trong trường hợp nhà thầu/ nhà xuất khẩu vi phạm hợp đồng về chất lượng sản phẩm mà không bồi thường hoặc không bồi thường đủ, ngân hàng sẽ trả thay trong phạm vi số tiền và thời hạn bảo lãnh. Bảo lãnh này phát hành nhằm bảo đảm nhà thầu/ Nhà xuất khẩu sẽ sửa chữa những hỏng hóc phát sinh sau khi giao hàng, bàn giao công trình hoặc bồi thường do hàng hoá thiếu hụt, phẩm chất kém. Loại bảo lãnh này có hiệu lực trong thời gian bảo hành sản phẩm. Số tiền bảo lãnh thấp hơn nhiều so với bảo lãnh thực hiện hợp đồng thường từ 2% -5% giá trị hợp đồng.

Bảo lãnh thanh toán: Đây là cam kết của ngân hàng với bên thụ hưởng về việc thanh toán tiền đúng theo hợp đồng cơ sở của người được bảo lãnh.

Trong trường hợp người được bảo lãnh không hoặc không thanh toán đủ số tiền theo hợp đồng thì ngân hàng bảo lãnh sẽ chịu trách nhiệm trả thay cho người được bảo lãnh. Đây là loai bảo lãnh được dùng khá phổ biến trong hoạt động mua bán nhằm mục đích tránh tổn thất cho người nhận bảo lãnh trong trường hợp người được bảo lãnh không thanh toán hoặc không thanh toán đủ số tiền theo đúng hợp đồng.

Bảo lãnh hoàn trả vốn vay: Bảo lãnh hoàn trả vốn vay của ngân hàng là cam kết của ngân hàng sẽ trả thay nợ vay (Gốc và lãi) nếu bên đi vay không trả đủ hoặc đúng hạn nợ vay. Việc bảo lãnh này nói chung khá phức tạp, số tiền bảo lãnh thường lớn do vậy rủi ro của ngân hàng bảo lãnh là rất cao. Ngân hàng phải xem xét tính khả thi của dự án, tài sản thế chấp và tư cách người vay để quyết định bảo lãnh bởi chính ngân hàng

là người có trách nhiệm trả tiền khi người vay không có khả năng hoàn trả các khoản nợ đến hạn.

Ngoài những loại bảo lãnh thông thường nêu trên được áp dụng rộng rãi trong giao dịch thương mại thì còn một số loại bảo lãnh khác cũng được xem như một hình thức cam kết như bảo lãnh: Thư tín dụng dự phòng (Stand-by L/C), bảo lãnh vận đơn, bảo lãnh thuế quan, bảo lãnh thuế, bảo lãnh sai sót trong chứng từ nhờ thu, bảo lãnh hối phiếu, bảo lãnh chứng khoán, …[28].

Trong thực tế có trường hợp không chỉ có một ngân hàng đứng ra bảo lãnh. Do yêu cầu phân chia rủi ro mà nhiều ngân hàng cùng tham gia bảo lãnh. Căn cứ vào số ngân hàng tham gia bảo lãnh có thể chia ra hai mô hình bảo lãnh: Một ngân hàng bảo lãnh và nhiều ngân hàng bảo lãnh. Trong mô hình nhiều ngân hàng bảo lãnh lại bao gồm: mô hình đồng bảo lãnh và mô hình tái bảo lãnh[29].

e. Theo tính chất chia sẻ rủi ro

Đồng bảo lãnh: là hình thức mà khi ngân hàng bảo lãnh thấy mức độ rủi ro lớn của món bảo lãnh hoặc do giới hạn của luật định mà muốn khách hàng (Bên nhận bảo lãnh) được bảo lãnh nhiều hơn có thể ngân hàng, TCTD sẽ mời thêm các ngân hàng khác cùng tham gia bảo lãnh. Đây là trường hợp nhiều ngân hàng cùng bảo lãnh cho một khách hàng với quyền hạn trách nhiệm như nhau hoặc phân theo một tỷ lệ nhất định.

Các loại bảo lãnh khác: Ngoài ra, dịch vụ bảo lãnh ngân hàng còn sở hữu một số loại bảo lãnh khác như là:

Thư tín dụng dự phòng (L/C).

Bảo lãnh thuế quan.

Bảo lãnh hối phiếu.

Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

1.1.2. Các rủi ro trong hoạt động bảo lãnh của ngân hàng thương mại

Các rủi ro trong hoạt động BLNH thường rất đa dạng, phong phú đặc biệt khi xem xét dưới góc độ khác nhau, như xem xét dưới góc độ bên nhận bảo lãnh, bên được bảo lãnh, hoặc ngân hàng phát hành bảo lãnh.

Thứ nhất, đối với bên nhận bảo lãnh

BLNH chính là một biện pháp bảo đảm và hạn chế rủi ro cho bên nhận bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng cơ sở. Tuy nhiên, BLNH không phải là "một liều thuốc thần" loại trừ được những rủi ro về thanh toán và rủi ro về nghiệp vụ. Trong hoạt động BLNH, bên nhận bảo lãnh gặp rủi

[28] Trường Đại học Luật Đại học Huế. (2015). *Pháp luật về giao dịch bảo đảm trong hoạt động cấp tín dụng ở Việt Nam.* Nxb. Chính trị Quốc gia, tr.32

[29] Bertrams, R. F. (2013). *Bank guarantees in international trade: the law and practice of independent (first demand) guarantees and standby letters of credit in civil law and common law jurisdictions*. Kluwer Law International BV.

ro nếu ngân hàng phát hành bảo lãnh vì một lý do nào đó có thể không thực hiện cam kết bảo lãnh, có thể chia nhỏ loại rủi ro này thành các rủi ro như sau:

Một là, rủi ro do ngân hàng phát hành từ chối hoặc không có khả năng thực hiện cam kết bảo lãnh: "Rủi ro này được cả người nhận bảo lãnh và người được bảo lãnh quan tâm bởi lẽ người được bảo lãnh muốn người nhận bảo lãnh chấp nhận cam kết bảo lãnh do ngân hàng của mình phát hành. Còn người nhận bảo lãnh thì quan tâm đến uy tín, khả năng tài chính, trình độ nghiệp vụ, mạng lưới của ngân hàng bảo lãnh…" Nếu ngân hàng bảo lãnh không có khả năng hoặc không thực hiện đúng cam kết bảo lãnh sẽ gây thiệt hại cho bên nhận bảo lãnh.

Hai là, rủi ro do ngân hàng phát hành gặp trường hợp bất khả kháng: "Rủi ro do trường hợp bất khả kháng được hiểu là rủi ro gây ra bởi biến cố mà không thể nào dự đoán hay kiểm soát được. Đây là những rủi ro xuất phát từ các nguyên nhân như thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh…" ảnh hưởng đến khả năng thực hiện cam kết bảo lãnh. Về nguyên tắc, ngân hàng bảo lãnh không được dựa vào sự kiện bất khả kháng để từ chối thanh toán hoặc đơn phương chấm dứt cam kết bảo lãnh, nhưng rõ ràng về mặt thời gian cam kết bảo lãnh đã không được thực hiện đúng và đây là rủi ro cho bên nhận bảo lãnh.

Ba là, rủi ro do thay đổi pháp luật tại quốc gia của ngân hàng phát hành:"Những thay đôi của pháp luật (chẳng hạn như quy định về xuất nhập khẩu hàng hóa, quản lý ngoại hối, …)" tại quốc gia của ngân hàng phát hành bảo lãnh cũng là một trong các rủi ro đối với người nhận bảo lãnh trong trường hợp những thay đổi pháp lý này làm cho ngân hàng bảo lãnh không thể thực hiện cam kết bảo lãnh đối với người nhận bảo lãnh.

Thứ hai, đối với bên được bảo lãnh

Một trong các rủi ro mà bên được bảo lãnh hay gặp phải trong hoạt động BLNH đó là rủi ro bị lừa đảo khi bên nhận bảo lãnh xuất trình bộ chứng từ giả để nhận thanh toán từ phía ngân hàng phát hành."Sau khi ngân hàng phát hành đã thực hiện cam kết bảo lãnh đối với người được bảo lãnh sẽ truy đòi thanh toán của người được bảo lãnh; trường hợp người được bảo lãnh từ chối hoàn trả thì ngân hàng phát hành sẽ tiến hành xử lý tài sản bảo đảm như tiền ký quỹ, tài sản thế chấp…"[30].

Điều 11 URDG 458 quy định: "Những người bảo lãnh và các bên ra chỉ thị phát hành không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm về hình thức, sự hoàn bị, tính chính xác, tính chân thực, sự giả mạo hoặc thiếu hiệu lực pháp lý của bất kỳ các chứng từ nào xuất trình cho họ, không có và không chịu trách nhiệm về các tuyên bố chung" hoặc riêng quy định trong các chứng từ cũng như sự thiện chí hoặc các hành vi hoặc sự thiếu sót của bất cứ người nào khác.

Như vậy, theo URDG 458, trừ trường hợp ngân hàng phát hành BLNH đã thiếu trân trọng hoặc thiếu thiện chí trong công việc thực hiện nghiệp vụ BLNH, còn không

[30] Võ Đình Toàn. (2017). *Một số vấn đề về quan hệ bảo lãnh ngân hàng ở nước ta hiện nay.* Tạp chí luật học, Số 3/2017.

sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với các hành vi giả mạo chứng từ thanh toán. Điều này cũng có nghĩa là bên được bảo lãnh sẽ phải gánh chịu rủi ro này.

Thứ ba, đối với bên bảo lãnh

Hoạt động BLNH là một trong các hoạt động đem lại nguồn thu quan trọng cho các ngân hàng bảo lãnh tuy nhiên hoạt động này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro ảnh hưởng xấu đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Do đó, các ngân hàng phải nhận dạng, đo lường, đánh giá rủi ro thường xuyên để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và có biện pháp quản lý rủi ro thích hợp. Một số rủi ro mà ngân hàng gặp phải trong hoạt động BLNH như sau:

Một là, rủi ro trong việc thực hiện hoạt động BLNH (rủi ro hoạt động): Rủi ro hoạt động nói chung được hiểu là " tổn thất, ảnh hưởng bất lợi gây ra do lỗi của con người, hệ thống, quy trình kiểm soát nội bộ và các tác động từ bên ngoài. Với vai trò là một nghiệp vụ ngân hàng, hoạt động BLNH khó tránh khỏi rủi ro hoạt động. Hay nói cách khác, đây là một loại rủi ro phổ biến trong hoạt động BLNH.

Nguyên nhân dẫn đến rủi ro hoạt động bao gồm cả guyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan. Trong đó, một số nguyên nhân chủ yếu bao gồm: (i) sai sót nghiệp vụ hoặc đạo đức, trình độ cán bộ hạn chế; (ii) hệ thống tổ chức chưa phù hợp dễ tạo sơ hở, sai sót; (iii) quy chế, quy trình nội bộ về hoạt động BLNH chưa hoàn thiện…

Như vậy, khái niệm về rủi ro hoạt động rất rộng và có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến rủi ro này.

Hai là, rủi ro do không thu hồi được số tiền bảo lãnh (rủi ro tín dụng): "Rủi ro tín dụng là tình trạng người đi vay không có khả năng hoàn trả được hoặc lãi hoặc gốc hay cả hai". Như đã nêu trên, hoạt động BLNH là một hoạt động cấp tín dụng mang tính đặc thù, phức tạp. Sau khi ngân hàng thực hiện thanh toán cho bên nhận bảo lãnh theo cam kết bảo lãnh, khi đó sẽ xuất hiện nghĩa vụ hoàn trả của khách hàng đối với ngân hàng. Hay nói cách khác đã xuất hiện một quan hệ tín dụng thực sự giữa ngân hàng (lúc này là bên cho vay) và khách hàng (lúc này được hiểu là bên vay – bên nhận nợ bắt buộc). Như vậy, nếu bất kỳ lý do gì khiến bên được bảo lãnh không hoàn trả gốc hoặc lãi cho ngân hàng thì đều được coi là rủi ro tín dụng đối với ngân hàng[31].

Ngoài hai loại rủi ro chính nêu trên, ngân hàng bảo lãnh còn gặp phải một số rủi ro khác trong hoạt động BLNH như rủi ro lãi suất, rủi ro bất khả kháng, rủi ro chứng từ...

1.2. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của pháp luật về bảo lãnh ngân hàng

1.2.1. Khái niệm pháp luật về bảo lãnh ngân hàng

Dưới góc độ pháp lý, hoạt động BLNH nhằm cung cấp một sự bảo đảm chắc chắn cho nghĩa vụ của bên được bảo lãnh đối với bên nhận bảo lãnh. Mặt khác, hoạt

[31] Knezević, M., & Lukić, A. (2012). Bank Guarantees and their Representation in Bank Business Activities (Parallel Legal Presentation). *Economic Insights-Trends & Challenges, 64*(1).

động này đồng thời là hoạt động cấp tín dụng, góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, hoạt động BLNH cần có sự điều chỉnh của pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan, đảm bảo sự an toàn của hệ thống ngân hàng và phát triển hoạt động BLNH theo định hướng của nhà nước.

Hoạt động BLNH tác động tích cực đến đời sống kinh tế - xã hội thông qua việc thúc đẩy các giao dịch trong nền kinh tế. Trong hoạt động ngoại thương BLNH chịu sự chi phối của các tập quán quốc tế. Do tính phức tạp và tầm quan trọng của hoạt động này đối với nền kinh tế và đời sống xã hội nên nhà nước không thể để nó phát triển tự phát mà nhà nước sử dụng pháp luật làm công cụ để quản lý và định hướng sự phát triển của hoạt động này theo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của nhà nước.

Sự cần thiết điều chỉnh bằng pháp luật đối với hoạt động BLNH còn xuất phát từ vị trí pháp lý của các ngân hàng (chủ thể cấp dịch vụ bảo lãnh). Như đã phân tích bảo lãnh là một hình thức cấp tín dụng của ngân hàng do vậy cũng sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không có sự kiểm soát tốt. Do đó nhà nước phải sử dụng pháp luật làm công cụ kích thích những tác động tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực trong hoạt động BLNH.

Hoạt động BLNH nhằm mục đích bảo đảm quyền và lợi ích của người nhận bảo lãnh trước các rủi ro của việc không thực hiện đúng hợp đồng của người được bảo lãnh. Mục đích của BLNH là hạn chế rủi ro cho người nhận bảo lãnh trước sự vi phạm hợp đồng của người được bảo lãnh. Do đó, để bảo vệ quyền lợi của người nhận bảo lãnh, pháp luật về hoạt động BLNH phải bảo đảm tính độc lập của BLNH. Mặt khác việc đảm bảo tính độc lập của BLNH cũng là yếu tố để pháp luật về hoạt động BLNH phù hợp với thông lệ quốc tế. Có thể nói pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng là hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động bảo lãnh ngân hàng.

1.2.2. Đặc điểm của pháp luật về bảo lãnh ngân hàng

1.2.2.1 Đặc điểm về đối tượng và phương pháp điều chỉnh

Pháp luật hoạt động BLNH có đối tượng điều chỉnh và phƣơng pháp điều chỉnh như sau: Đối tượng điều chỉnh của pháp luật về BLNH là các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình các ngân hàng, các TCTD thực hiện hoạt động BLNH. Đó là: các quan hệ phát sinh từ hợp đồng cấp bảo lãnh giữa ngân hàng, TCTD với khách hàng; các quan hệ phát sinh từ hợp đồng bảo lãnh giữa ngân hàng, TCTD với bên nhận bảo lãnh (bên thụ hƣởng); quan hệ phát sinh từ việc thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi bên liên quan đến hoạt động BLNH; các quan hệ phát sinh từ tranh chấp và giải quyết tranh chấp về hoạt động BLNH.... Do các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động BLNH được thiết lập trên cơ sở quyền tự do kinh doanh cho nên phương pháp điều chỉnh của pháp luật về hoạt động BLNH là phương pháp bình đẳng trước pháp luật.

1.2.2.2 Đặc điểm về nguyên tắc điều chỉnh của pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng

- Nguyên tắc bảo đảm quyền tự do kinh doanh

Trước đây, ở các nước xã hội chủ nghĩa, trong điều kiện nền kinh tế vận hành theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung, nhà nước xã hội chủ nghĩa thực hiện nguyên tắc độc quyền nhà nước về ngân hàng. Theo nguyên tắc này, kinh doanh ngân hàng là lĩnh vực độc quyền của nhà nước. Do đó các ngân hàng không được quyền tự chủ kinh doanh mà hoàn toàn tuân theo các mệnh lệnh của nhà nước. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay cũng như các nước khác theo thể chế kinh tế thị trường, các doanh nghiệp (trong đó có TCTD) về cơ bản được ghi nhận quyền tự do kinh doanh. Mức độ quyền tự do kinh doanh có thể khác nhau tùy thuộc vào thể chế kinh tế thị trường ở mỗi quốc gia nhưng nhìn chung đều dựa trên nguyên lý doanh nghiệp có quyền tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của mình. Tự do kinh doanh là một phạm trù rộng và có nhiều cách định nghĩa khác nhau. Ở nghĩa rộng, tự do kinh doanh có thể được hiểu là khả năng mà các tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn, tự quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, trong đó có quyền thành lập cơ sở kinh doanh, lựa chọn loại hình doanh nghiệp, lựa chọn ngành nghề, quy mô kinh doanh và địa bàn kinh doanh; được tự do lựa chọn đối tác, bạn hàng, được tự chủ kinh doanh, tự quyết định các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh... Tuy nhiên, quyền tự do kinh doanh bị giới hạn bởi quyền tự do kinh doanh của chủ thể khác, lợi ích chính đáng của chủ thể khác và lợi ích công cộng. Theo cách tiếp cận nêu trên, để bảo đảm quyền tự do kinh doanh trong hoạt động BLNH, pháp luật về hoạt động BLNH được hình thành theo những nội dung sau:

Một là, pháp luật bảo đảm sự bình đẳng giữa các chủ thể cung ứng dịch vụ bảo lãnh, theo đó, bất kỳ TCTD nào có thể thực hiện hoạt động bảo lãnh một cách chuyên nghiệp, có khả năng tài chính và tự chịu trách nhiệm đối với các cam kết bảo lãnh của mình thì đều được quyền cung ứng dịch vụ bảo lãnh, không được có một sự ưu đãi hoặc hạn chế thiếu căn cứ của chủ thể này so với chủ thể khác.

Hai là, pháp luật bảo đảm quyền tự do thỏa thuận và tự định đoạt của các chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng bảo lãnh. Nguyên tắc này xuất phát từ bản chất của quan hệ hợp đồng là đề cao tính tự nguyện, tự thỏa thuận và tự chịu trách nhiệm của các chủ thể trong quá trình xác lập, thực hiện, thay đổi, chấm dứt hợp đồng. Trong quan hệ hợp đồng bảo lãnh, các bên có quyền tự do thỏa thuận các điều kiện, điều khoản hợp đồng. Tuy nhiên, việc áp dụng nguyên tắc này vẫn phải

đảm bảo nguyên tắc chung của pháp luật, đó là việc tự do thỏa thuận và tự định đoạt trong quan hệ bảo lãnh không được trái quy định của pháp luật, đạo đức xã hội.

Ba là, pháp luật bảo đảm quyền bình đẳng giữa các chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng cấp bảo lãnh. Trong đời sống dân sự, các chủ thể độc lập và bình đẳng khi tham gia quan hệ pháp luật. Trong quan hệ hợp đồng cấp bảo lãnh cũng vậy, các chủ thể đƣợc quyền bình đẳng khi xác lập thực hiện hợp đồng cấp bảo lãnh. Trong quá trình thực hiện hoạt động BLNH, ngân hàng có quyền và nghĩa vụ thẩm định hồ sơ, quyết định cấp bảo lãnh cho khách hàng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là khách hàng ở vị trí yếu thế hơn so với ngân hàng. Khách hàng hoàn toàn có quyền lựa chọn ngân hàng phát hành bảo lãnh, có quyền đàm phán các điều khoản của hợp đồng cấp bảo lãnh. Tuy nhiên, cũng tương tự như quan hệ hợp đồng bảo lãnh, việc tự do thỏa thuận và tự định đoạt trong quan hệ hợp đồng cấp bảo lãnh không đƣợc trái quy định của pháp luật, đạo đức xã hội.

Bốn là, để bảo đảm cho quyền tự do kinh doanh được thực hiện, pháp luật cũng có những chế tài đối với hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động BLNH. Theo đó, các chủ thể tham gia hoạt động BLNH cũng bình đẳng với nhau trong việc gánh chịu hậu quả pháp lý do thực hiện hành vi trái pháp luật trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận hay theo quy định của pháp luật.

- Nguyên tắc bảo đảm tính độc lập của bảo lãnh ngân hàng

Mục đích đầu tiên của BLNH là hạn chế rủi ro cho người thụ hưởng trước sự vi phạm hợp đồng cơ sở của người được bảo lãnh. Do đó, để bảo vệ quyền lợi của người thụ hưởng, pháp luật về hoạt động BLNH phải bảo đảm tính độc lập của BLNH. Mặt khác việc đảm bảo tính độc lập của BLNH cũng là yếu tố để pháp luật về hoạt động BLNH phù hợp với thông lệ quốc tế. Xét ở góc độ chung, nguyên tắc bảo đảm tính độc lập của BLNH thể hiện ở các nội dung sau:

Một là, người nhận bảo lãnh có quyền được thanh toán khi xuất trình yêu cầu đòi tiền phù hợp mà không cần có sự chấp thuận của người được bảo lãnh. Nguyên tắc này được ghi nhận ở các tập quán quốc tế như: URDG 758, ISP98, UCP 600... Đây là mấu chốt của nguyên tắc bảo đảm tính độc lập của BLNH. Như vậy, về mặt pháp lý, một khi các điều khoản và điều kiện của bảo lãnh được đáp ứng thì người nhận bảo lãnh có quyền yêu cầu ngân hàng thanh toán tiền trên cơ sở lập chứng từ theo như điều khoản tại cam kết bảo lãnh mà không cần có sự đồng ý của người được bảo lãnh.

Hai là, nguyên tắc bảo đảm tính độc lập của BLNH được thể hiện ở trách nhiệm thanh toán của người bảo lãnh. Trách nhiệm thanh toán của người bảo lãnh hoàn toàn độc lập với hợp đồng cấp bảo lãnh giữa người bảo lãnh với người được bảo lãnh. Theo thông lệ quốc tế, tính độc lập của BLNH luôn được đề cao. Việc thiếu tính chất này trong Quy tắc thống nhất về bảo lãnh hợp đồng (URCG 325) đã khiến nó không được chấp nhận trên thị trường, chỉ khi ICC ban hành Bộ quy tắc thống nhất về bảo lãnh theo yêu cầu (URDG 458 và sau đó là URDG 758) với việc đề cao tính độc lập của BLNH đã khiến chúng được thừa nhận rộng rãi. Sở dĩ nguyên tắc bảo đảm tính độc lập của BLNH luôn được đề cao vì những lý do cơ bản sau đây:

(i) Xuất phát từ mục đích của hoạt động BLNH là nhằm bảo vệ quyền lợi của người nhận bảo lãnh. Nhờ có BLNH, người nhận bảo lãnh nhận được một sự bảo đảm chắc chắn để bồi thường những thiệt hại từ việc không thực hiện đúng hợp đồng cơ sở của người được bảo lãnh. Nếu mục đích này không đạt được thì hoạt động BLNH không còn ý nghĩa.

(ii) Vì bản chất của BLNH chính là một hợp đồng được giao kết giữa người bảo lãnh với người nhận bảo lãnh. Do đó, việc sửa đổi, chấm dứt hợp đồng này phải được sự chấp thuận của người nhận bảo lãnh chứ không phải một bên thứ nào khác, kể cả người được bảo lãnh. Mặt khác, trong mối quan hệ hợp đồng này thì vị thế của người bảo lãnh thuận lợi hơn, nội dung văn bản bảo lãnh được soạn thảo và ban hành bởi người bảo lãnh. Trong hầu hết các trường hợp, người nhận bảo lãnh chỉ chấp nhận (ngầm hiểu) văn bản bảo lãnh mà không tham gia vào quá trình soạn thảo nội dung văn bản bảo lãnh. Trên thực tế, người bảo lãnh có thể lợi dụng vị thế được soạn thảo, ban hành cam kết bảo lãnh để đưa ra những điều kiện hoặc lý do để không thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đã cam kết. Vì vậy, pháp luật đề cao tính độc lập của BLNH để cân bằng vị thế giữa các bên trong hợp đồng BLNH.

(iii) Xuất phát từ mục đích ổn định trật tự xã hội và phát triển kinh tế. Rõ ràng, một khi các cam kết BLNH không được thực hiện sẽ để lại hậu quả xấu về kinh tế - xã hội. Chẳng hạn nhƣ: các dự án, giao dịch đang được thực hiện dở dang mà bị đình trệ không có nguồn bù đắp; doanh nghiệp, ngƣời dân không còn niềm tin vào các cam kết bảo lãnh của ngân hàng... Vì vậy, pháp luật ghi nhận nguyên tắc bảo đảm tính độc lập của BLNH để hoạt động này phát triển ổn định, vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Vì các lý do nêu trên, pháp luật các quốc gia thường thiết lập cơ chế bảo đảm tính độc lập của BLNH như: quy định trách nhiệm của bên bảo lãnh về việc thanh toán đầy đủ số tiền bảo lãnh ngay khi bên nhận bảo lãnh xuất trình chứng từ phù hợp; quy định về thời hạn tối đa mà bên

bảo lãnh phải thực hiện cam kết bảo lãnh; quy định về việc kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động BLNH và xử lý các vi phạm của bên bảo lãnh trong hoạt động BLNH.

1.2.3. Vai trò của pháp luật về bảo lãnh ngân hàng

Xung quanh chế định bảo lãnh hiện nay, những vấn đề pháp lý như khái niệm, đặc điểm của biện pháp này và một số vướng mắc khi áp dụng trên thực tiễn được các nhà nghiên cứu và áp dụng pháp luật rất quan tâm. Trong hoạt động ngân hàng, biện pháp bảo lãnh, hay nghiệp vụ bảo lãnh được coi là một trong những công cụ được sử dụng khá thường xuyên, được các ngân hàng áp dụng như một dịch vụ kinh doanh hiệu quả bằng các nghiệp vụ bảo lãnh như "bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh đối ứng, bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai,…". Bên cạnh đó, biện pháp bảo lãnh còn được áp dụng khá phổ biến trong hợp đồng tín dụng giữa tổ chức tín dụng với tổ chức, cá nhân.

Để bảo đảm tính pháp lý bắt buộc hình thức bảo lãnh phải được lập thành văn bản (có thể lập thành văn bản riêng hoặc ghi trong hợp đồng chính). Trong trường hợp pháp luật có quy định thì văn bản bảo lãnh phải được công chứng hoặc chứng thực.

Hiện nay, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách hàng được phép lựa chọn thực hiện hoạt động bảo lãnh ngân hàng qua việc sử dụng các phương tiện điện tử[32]. Trước đây, tại Thông tư 07/2015/TT-NHNN không quy định về phương thức phát hành bảo lãnh điện tử, mà chỉ có trường hợp giao dịch thông qua mạng thông tin liên lạc quốc tế giữa các tổ chức tín dụng.

Việc bổ sung phương thức thực hiện hoạt động bảo lãnh tại Thông Tư 11/2022 nhằm đảm bảo tương thích và phù hợp với Luật Giao dịch điện tử 2023, Bộ Luật dân sự 2015, Điều 97 Luật các Tổ chức tín dụng 2010, Điều 105 Luật các Tổ chức tín dụng 2024, Khoản 3 Điều 3 Nghị định 35/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007 về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng, Nghị định 130/2018/NĐ-CP ngày 27/09/2018 quy định chi tiết Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Đồng thời, tạo sự đa dạng, linh động cho các tổ chức tín dụng áp dụng trên thực tế, phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ hiện nay.

Tuy đã có quy định về bảo lãnh ngân hàng điện tử theo Thông tư số 11/2022/TT-NHNN (có hiệu lực triển khai từ ngày 01/4/2023), nhưng việc áp dụng phương thức này vào thực tế còn hạn chế do những vướng mắc, bất cập như: chưa quy định thực sự rõ ràng về cách xác định hoạt động bảo lãnh điện tử, giới hạn mức đối với hình thức bảo lãnh điện tử…

[32] Ngân hàng Nhà nước. (2022). *Thông tư số 11/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 của Ngân hàng Nhà nước quy định về bảo lãnh Ngân hàng*, Hà Nội, Điều 9.

Một trong những vướng mắc của quan hệ bảo lãnh nữa đó là sự phức tạp và đôi khi chưa phân định rõ ranh giới trách nhiệm của bên bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh và bên được bảo lãnh trong các quy định pháp luật.

Trong vụ án của Ngân hàng TMCP VA có phát hành chứng thư bảo lãnh cho Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Cần Thơ (sau đây gọi tắt là MBCT) nhằm đảm bảo cho nghĩa vụ tài chính của Công ty CP Thương mại dịch vụ xây dựng T (sau đây gọi là Công ty T) tại MBCT theo Hợp đồng số 122 giữa Công ty T và Tổng công ty VTQĐ - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Trong chứng thư có nêu Ngân hàng TMCP VA "cam kết chi trả vô điều kiện " cho MBCT ngay khi nhận được văn bản yêu cầu thanh toán nếu Công ty T không thực hiện nghĩa vụ tài chính phát sinh tại MBCT theo Hợp đồng số 122. Tuy nhiên, Ngân hàng TMCP VA nghi ngờ Công ty T không phát sinh nghĩa vụ trên thực tế đối với MBCT. Trong trường hợp này, Ngân hàng TMCP VA phải thực hiện nghĩa vụ tài chính ngay khi MBCT yêu cầu hay ngược lại Ngân hàng TMCP VA có quyền yêu cầu MBCT phải xuất trình được các chứng từ chứng minh nghĩa vụ của Công ty T đã phát sinh và chỉ thực hiện nghĩa vụ tài chính sau khi MBCT xuất trình các chứng từ này[33].

Ví dụ nêu trên cho thấy, một trong các nguyên nhân chính dẫn đến tranh chấp là do các bên trong quan hệ bảo lãnh đã có cách hiểu khác nhau về nội hàm của cụm từ "cam kết chi trả vô điều kiện". Nếu thỏa thuận như vậy thì Ngân hàng TMCP VA có được quyền yêu cầu MBCT xuất trình các tài liệu chứng minh không? Việc yêu cầu xuất trình các tài liệu chứng minh trước khi thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh có vi phạm thỏa thuận không? Như vậy, vấn đề nêu trên nếu không được quy định cụ thể, rõ ràng thì sẽ tiếp tục dẫn đến cách hiểu và áp dụng pháp luật thiếu thống nhất giữa các bên trong quan hệ bảo lãnh.

Để đảm bảo nghĩa vụ được thực hiện một cách chắc chắn thì quan hệ bảo lãnh có liên quan đến việc cầm cố, thế chấp tài sản, nếu pháp luật có quy định phải đăng ký giao dịch bảo đảm, công chứng hay chứng thực, thì vấn đề đặt ra ở đây là có phải làm các thủ tục với cả thỏa thuận bảo lãnh hay chỉ phải làm các thủ tục với thỏa thuận cầm cố, thế chấp tài sản của bên thứ ba? Bởi trên thực tế, có một số trường hợp thỏa thuận bảo lãnh có kèm theo các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ bảo lãnh, nhưng cũng có trường hợp hai văn bản này được lập riêng. Theo Nghị định số 99 thì bảo lãnh không thuộc trường hợp phải đăng ký giao dịch bảo đảm và hiện nay thì gần như tất cả các TCTD đều không đăng ký giao dịch bảo đảm đối với nghiệp vụ này. Điều này cũng không quy định trường hợp bảo lãnh có kèm theo biện pháp cầm cố thế chấp để bảo đảm nghĩa vụ bảo lãnh thì phải đăng ký[34]. Nhưng trên thực tế, nhiều giao dịch bảo lãnh có kèm theo tài sản thế chấp nghĩa vụ bảo lãnh đã bị tòa án tuyên vô hiệu do không đăng ký giao dịch bảo đảm.

---

[33] Ngân hàng TMCP Quân đội, chi nhánh Cần Thơ. (2023), *Bản báo cáo tóm tắt nội dung các tranh chấp*.

[34] Chính phủ. (2022). *Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm*, Hà Nội, Điều 4

Để đảm bảo sự thống nhất trong cách hiểu và áp dụng luật, pháp luật nên có hướng dẫn cụ thể hơn về trường hợp thế chấp, cầm cố tài sản của bên bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh theo hướng yêu cầu các bên phải đăng ký giao dịch bảo đảm (hoặc công chứng, chứng thực) cả thỏa thuận bảo lãnh và biện pháp cầm cố, thế chấp đảm bảo nghĩa vụ bảo lãnh nếu pháp luật yêu cầu tài sản đó phải tuân thủ các thủ tục này. Để đảm bảo tính pháp lý của biện pháp bảo đảm cho các cam kết bảo lãnh, pháp luật cần thống nhất cách hiểu về biện pháp bảo đảm cho cam kết bảo lãnh để tránh tình trạng giao dịch bị vô hiệu sẽ dẫn đến rủi ro cho bên bảo lãnh khi không được Tòa án công nhận.

Các quan hệ phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh đều bình đẳng trước pháp luật. Dó đó hoạt động BLNH cũng dựa trên nguyên tắc bình đẳng và tự do kinh doanh nhưng không trái với quy định của pháp luật. Các đối tượng tham gia hoạt động BLNH đều chịu sự điều chỉnh của pháp luật về bảo lãnh ngân hàng. Quyền bình đẳng còn thể hiện ở việc áp dụng chế tài đối với hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động BLNH. Theo đó, các chủ thể tham gia hoạt động BLNH cũng bình đẳng với nhau trong việc gánh chịu hậu quả pháp lý do thực hiện hành vi trái pháp luật.

Theo đó pháp luật bảo đảm sự bình đẳng giữa các chủ thể trong hoạt động cung cấp dịch vụ bảo lãnh. Không phân biệt giữa đơn vị nhà nước và đơn vị tư nhân. Pháp luật còn bảo đảm quyền tự do thỏa thuận và tự định đoạt của các chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng bảo lãnh. Đề cao tính tự nguyện, tự thỏa thuận và tự chịu trách nhiệm của các chủ thể trong quá trình xác lập, thực hiện, thay đổi hay chấm dứt hợp đồng.

Tóm lại, pháp luật là công cụ thể hiện ý chí của Nhà nước, do đó những chủ trương định hướng của Nhà nước đều được thể hiện trong các quy định pháp luật được ban hành và thực hiện. Những chủ trương chưa phù hợp sẽ kìm hãm sự phát triển của hoạt động bảo lãnh và ngược lại những chủ trương phù hợp với quy luật phát triển, phù hợp với thực tiễn sẽ thúc đẩy hoạt động bảo lãnh của ngân hàng phát triển.

1.3. Pháp luật và thực trạng áp dụng pháp luật về bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân Đội, Chi nhánh Cần Thơ

1.3.1. Khái quát một số đặc điểm của Ngân hàng TMCP Quân Đội, Chi nhánh Cần Thơ

1.3.1.1 Quá trình thành lập

Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Cần Thơ, được thành lập vào năm 1996. Trong 28 năm hoạt động tại địa bàn Cần Thơ, Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Cần Thơ được đánh giá là một trong những ngân hàng TMCP có tốc độ phát triển nhanh nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Hiện nay Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Cần Thơ có 3 chi nhánh và 3 phòng giao dịch trực thuộc:

- Quận Ninh Kiều có 2 chi nhánh: một chi nhánh ở Tầng 1, tầng 2 và tầng 7 tòa nhà Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Cần Thơ, số 77, 77B Võ Văn Tần, phường

Tân An, quận Ninh Kiều, Cần Thơ; một chi nhánh ở Số 42, 44 Nguyễn An Ninh, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ.

- Quận Bình Thủy có 1 chi nhánh: ở Số 43, Đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Thới, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ.

Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Cần Thơ có 3 phòng giao dịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Qua quá trình hoạt động và phát triển, Ngân hàng TMCP Cổ phần quân đội - Chi nhánh Cần Thơ đang ngày càng trở nên lớn mạnh có sức ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế cả nước nói chung và Cần Thơ nói riêng.

Các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng ngày càng đa dạng, ngoài các sản phẩm truyền thống như: huy động vốn, cho vay, bảo lãnh… ngân hàng đã phát triển các dịch vụ mới hiện đại như Internet Banking, dịch vụ thẻ, dịch vụ ngân quỹ …

Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Cần Thơ luôn chú trọng đến chất lượng nhân sự của mình. Đến nay, ngân hàng đã có gần 150 nhân viên, trong đó cán bộ có trình độ Đại học và trên Đại học chiếm tỷ lệ hơn 80%, đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm, nhân viên có tuổi đời trẻ tạo tác phong làm việc năng động.

Cùng với việc phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Cần Thơ đã đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế chung của khu vực. Tiêu biểu phải kể đến đó là triển khai tốt việc cho vay hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp cổ phần hóa, cho vay hỗ trợ lãi suất, làm tốt công tác tài chính – cho vay trong các lĩnh vực xây lắp, dịch vụ đầu tư hạ tầng viễn thông, thương mại, sản xuất …

Bên cạnh đó, Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Cần Thơ còn tham gia tích cực các hoạt động xã hội, công tác từ thiện tại địa phương như: ủng hộ cứu trợ nhân dân bị bão lũ, dịch bệnh, tặng quà cho các đối tượng chính sách, tài trợ cho các sự kiện văn hóa…

1.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh

- Huy động vốn bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ với nhiều hình thức như tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi hưởng lãi bậc thang, tiết kiệm dự thưởng, tiền gửi thanh toán, phát hành kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi.

- Đầu tư vốn tín dụng bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ: Cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, và chiết khấu các loại giấy tờ, chứng từ có giá, cho vay tài trợ theo dự án, cho vay đồng tài trợ với các Ngân hàng thương mại khác, cho vay tài trợ xuất nhập khẩu, cho vay dài hạn các dự án lớn, cho vay khép kín chu kỳ sản xuất – lưu thông, cho vay các chương trình chỉ định, ủy thác của Chính phủ.

- Thanh toán quốc tế bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ: Thanh toán chuyển tiền điện tử trong cả nước, thanh toán quốc tế qua mạng SWIFT, Telex.

- Bảo lãnh bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ: Bảo lãnh, bảo lãnh đấu thầu, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai,…

- Kinh doanh tiền tệ tín dụng và dịch vụ ngân hàng đối ngoại: Tiếp nhận và triển khai các dự án ủy thác vốn, dự án tài trợ kỹ thuật, dự án làm dịch vụ giải ngân - Phát triển nguồn nhân lực và đào tạo nhân viên, quản lý tốt nhân sự, nâng cao uy tín phục vụ của Ngân hàng TMCP Quân Đội.

1.1.3.3. Tình hình hoạt động cung cấp dịch vụ bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân Đội, Chi nhánh Cần Thơ

Từ khi thành lập đến nay, nghiệp vụ bảo lãnh đã được quan tâm chú trọng phát triển và trở thành một trong những nghiệp vụ kinh doanh thu dịch vụ chính của ngân hàng thương mại nói chung và Ngân hàng TMCP Quân Đội nói riêng. Doanh số bảo lãnh không ngừng tăng với chất lượng được nâng cao, đối tượng khách hàng có nhu cầu bảo lãnh cũng tăng nhanh chóng. Bên cạnh việc thúc đẩy cung cấp dịch vụ bảo lãnh cho khách hàng, Ngân hàng TMCP Quân Đội còn có thể sử dụng khoản vốn phát sinh từ các tài khoản ký quỹ của khách hàng để tạo điệu kiện tăng hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng.

Hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Cần Thơ có sự tăng trưởng qua các năm và năm sau tăng hơn năm trước. Tại thời điểm cuối năm 2020, số dư bảo lãnh 678.890 triệu đồng và tiếp tục tăng trưởng qua các năm 2021, 2022 và năm 2023 là 998.760 triệu đồng. Qua đó cho thấy hoạt động bảo lãnh liên tục có sự gia tăng qua các năm.

Về cơ cấu bảo lãnh, hiện nay tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Cần Thơ bảo lãnh trong nước vẫn chiếm tỷ trọng cao, từ 90% - 95% tổng số dư bảo lãnh, phần còn lại là bảo lãnh nước ngoài. Nguyên nhân bảo lãnh nước ngoài chiếm tỷ lệ thấp tại chi nhánh vì các hoạt động đối với khách hàng nước ngoài tại chi nhánh vẫn chưa cao.

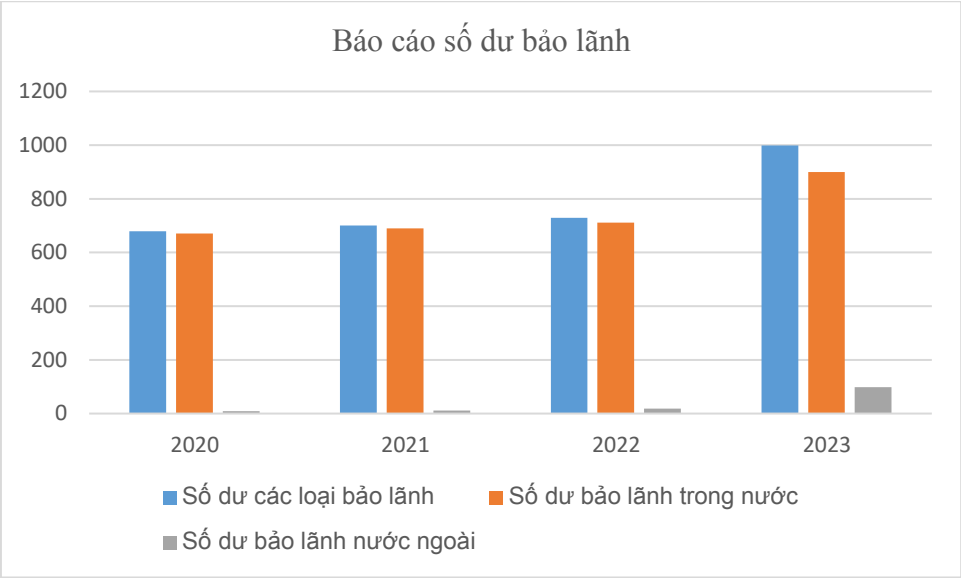
Bảng 1.1 Báo cáo số dư bảo lãnh từ năm 2020 - 2023

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	2020	2021	2022	2023
Số dư các loại bảo lãnh	678.890	700.231	729.078	998.760
Số dư bảo lãnh trong nước	670.555	689.339	711.000	900.081
Số dư bảo lãnh nước ngoài	8.335	10.892	18.078	98.679

(Nguồn: Báo cáo tài chính của MBCT năm 2020, 2021, 2022 và 2023)

Biểu đồ 1.2. Tình hình số dư bảo lãnh từ năm 2020 - 2023
Đơn vị tính: triệu đồng



(Nguồn: Báo cáo tài chính của MBCT năm 2020, 2021, 2022 và 2023)

Cũng như các ngân hàng thương mại khác trên địa bàn, Ngân hàng TMCP Quân Đội, Chi nhánh Cần Thơ hoạt động với chức năng là kinh doanh tiền tệ. Thực hiện phương châm của toàn hệ thống "tăng trưởng hợp lý – tái cơ cấu – hiệu quả" mục tiêu của chi nhánh là tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm - dịch vụ nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, an toàn và có lãi.

Kết quả kinh doanh của ngân hàng được coi là chỉ tiêu chính xác và toàn diện nhất để đánh giá hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Trong thời gian qua Ngân hàng TMCP Quân Đội, Chi nhánh Cần Thơ đã không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, củng cố và bổ sung nguồn nhân lực, quảng bá thương hiệu và hình ảnh ngân hàng qua một số hoạt động xã hội, thu hút khách hàng đến với ngân hàng ngày càng nhiều. Chính vì vậy mà trong thời gian qua Ngân hàng TMCP Quân Đội, Chi nhánh Cần Thơ đã đạt được kết quả kinh doanh tốt, luôn nằm trong nhóm 6 TCTD đứng đầu tại địa bàn Cần Thơ mặc dù đối mặt với tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid vừa qua.

1.3.2. Pháp luật và thực trạng áp dụng pháp luật về bảo lãnh, giải quyết tranh chấp của ngân hàng thương mại và cơ sở pháp lý thực hiện hoạt động bảo lãnh tại MBCT

Chế định bảo lãnh NHTM bao gồm các quy phạm pháp luật quy định về phạm vi, đối tượng, điều kiện bảo lãnh; Quy phạm giải thích các thuật ngữ, khái niệm; Quy định về áp dụng pháp luật và lựa chọn giải quyết tranh chấp; Quy định về các trường hợp không được bảo lãnh, hạn chế bảo lãnh và thực hiện giới hạn cấp tín dụng; Quy định về bảo lãnh đối với một số nhóm khách hàng đặc thù và một số loại kinh doanh, dịch vụ;

Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục bảo lãnh; Quy định về thời hạn hiệu lực của cam kết bảo lãnh, thỏa thuận cấp bảo lãnh; Quy định về thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, miễn nghĩa vụ bảo lãnh; Quy định về quan hệ giữa cam kết bảo lãnh và hợp đồng có nghĩa vụ được bảo lãnh; chấm dứt quan hệ bảo lãnh; Quy định về đồng bảo lãnh và các hình thức bảo lãnh khác; Quy định về quyền và nghĩa vụ của các chủ thể quan hệ bảo lãnh; Quy định về các vấn đề khác có liên quan. Có thể nói các quy định hiện hành về hoạt động bảo lãnh của NHTM được định nghĩa và ban hành trong nhiều các văn bản pháp luật. Có thể tóm lược các nội dung của pháp luật về bảo lãnh ngân hàng trên một số nội dung chính như sau:

1.3.2.1 Quy định về chủ thể, phạm vi thực hiện hoạt động bảo lãnh của ngân hàng

a. Chủ thể thực hiện hoạt động BLNH

Trong quan hệ bảo lãnh ngân hàng thường phát sinh hai loại quan hệ: Quan hệ giữa ngân hàng với bên nhận bảo lãnh và quan hệ dịch vụ bảo lãnh giữa ngân hàng với khách hàng (bên được bảo lãnh). Như vậy thông thường sẽ tồn tại ba chủ thể tham gia vào quan hệ bảo lãnh ngân hàng (ngân hàng bảo lãnh, bên được bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh). Pháp luật Việt nam quy định tương đối cụ thể về các chủ thể này khi tham gia quan hệ bảo lãnh.

- Bên bảo lãnh

Hoạt động BLNH được thực hiện bởi một trong các chủ thể sau: Ngân hàng, Ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, công ty tài chính tổng hợp, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Tổ chức tín dụng phi ngân hàng, Tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân, cá nhân và tổ chức có liên quan đến nghiệp vụ bảo lãnh bao gồm cá nhân và tổ chức là người cư trú và không cư trú[35].

Tuy nhiên, trong hoạt động BLNH, ngoài việc được cấp giấy phép hoạt động và đăng ký kinh doanh hoạt động BLNH, khi thực hiện các giao dịch bảo lãnh cụ thể, bên bảo lãnh còn phải tuân thủ các điều kiện do pháp luật quy định đối với khách hàng là người không cư trú, các quy định về quản lý ngoại hối trong hoạt động BLNH, các trường hợp không được bảo lãnh, hạn chế bảo lãnh và thực hiện giới hạn cấp tín dụng.

- Bên nhận bảo lãnh

Bên nhận bảo lãnh trong BLNH có thể được hiểu là bên có quyền hưởng lợi một khoản nợ do bên được bảo lãnh hoặc bên bảo lãnh thanh toán từ một nghĩa vụ trong các hợp đồng (như hợp đồng mua bán, hợp đồng tín dụng, …), hay các nghĩa vụ thanh toán ngoài hợp đồng (như nghĩa vụ nộp thuế, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, …).

[35] Luật Các Tổ chức tín dụng. (2024), Điều 107, 115 & Ngân hàng Nhà nước. (2022). *Thông tư số 11/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 của Ngân hàng Nhà nước quy định về bảo lãnh Ngân hàng*, Hà Nội, Điều 2

Thực tế cho thấy, các quy định hiện hành về BLNH chỉ đề cập đến hai bên tham gia quan hệ bảo lãnh là bên bảo lãnh và bên được bảo lãnh chứ không quy định cụ thể loại chủ thể tham gia quan hệ bảo lãnh với tư cách là bên nhận bảo lãnh.

Việc pháp luật không quy định cụ thể loại chủ thể nhận bảo lãnh trong quan hệ BLNH có thể xuất phát từ lý do bên nhận bảo lãnh hầu như không bị ràng buộc việc thực hiện nghĩa vụ đối với các bên còn lại nên luật không quan tâm nhiều đến việc vi phạm nghĩa vụ của bên nhận bảo lãnh đối với các bên còn lại. Vì vậy, pháp luật chỉ quy định các điều kiện ràng buộc đối với các chủ thể tham gia quan hệ bảo lãnh với tư cách là bên bảo lãnh và bên được bảo lãnh, nhằm giảm rủi ro cho bên nhận bảo lãnh trong quá trình các bên thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

Do đó, dù pháp luật không trực tiếp quy định các loại chủ thể cụ thể là bên nhận bảo lãnh, nhưng căn cứ vào các loại hình bảo lãnh mà các TCTD được phép thực hiện, thì có thể xác định bên nhận bảo lãnh là tổ chức, cá nhân có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi tham gia các loại hợp đồng như hợp đồng tín dụng, các loại hợp đồng cung ứng dịch vụ, sản phẩm phát sinh quan hệ thanh toán, các loại hợp đồng phát sinh trách nhiệm vật chất khi vi phạm hợp đồng.

- Bên được bảo lãnh

Về cơ bản, các văn bản về chế định bảo lãnh hiện hành quy định về việc sửa đổi, bổ sung đối với chủ thể được bảo lãnh theo hướng rộng hơn, thoáng hơn so với quy định cũ; đó là bên được bảo lãnh không chỉ dừng lại ở một số tổ chức nhất định mà tất cả các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài đều có thể được TCTD bảo lãnh nếu đáp ứng được các điều kiện về bảo lãnh theo luật định.

Tuy nhiên, nhằm hạn chế rủi ro trong việc cấp tín dụng pháp luật quy định cụ thể đối với một số trường hợp không được cấp tín dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 126 Luật các TCTD năm 2010 quy định những trường hợp không được cấp tín dụng và được bổ sung bằng thông tư 22/2019/TT-NHNN, Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Quy định này càng được thắt chặt hơn bằng việc mở rộng thêm các trường hợp không được cấp tín dụng theo quy định tại Điều 134 luật các TCTD năm 2024 nhằm hạn chế tối đa rủi ro, đảm bảo an toàn cho các TCTD.

b. Phạm vi thực hiện hoạt động BLNH

Theo quy định của pháp luật về phạm vi thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. Việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Theo đó nghĩa vụ thanh toán trong giao dịch BLNH có thể phát sinh những trường hợp về nghĩa vụ tối đa hoặc không giới hạn nếu không có cam kết cụ thể. Với những trường hợp nghĩa vụ bảo lãnh không phải là số tiền cụ thể, TCTD phát hành cam kết bảo lãnh phải dự tính số tiền bồi thường thiệt hại tối đa là bao nhiêu để cân nhắc và xác định giới hạn bảo lãnh phù hợp với khả năng của tổ chức mình và quy định của pháp luật.

Bên bảo lãnh có thể cam kết bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ tài chính mà bên được bảo lãnh có nghĩa vụ thực hiện với bên nhận bảo lãnh[36].

Nghĩa vụ thanh toán cho bên nhận bảo lãnh bao gồm nhiều loại khác nhau: (i) Nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi vay và các chi phí khác có liên quan đến khoản vay; (ii) Nghĩa vụ thanh toán tiền mua vật tư, hàng hóa, máy móc, thiết bị và các khoản chi phí thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư, sản xuất, kinh doanh, hoặc dịch vụ đời sống; …..

Cần lưu ý khi xác định giới hạn bảo lãnh, TCTD nên ghi số tiền tối đa được bảo lãnh, dựa trên tính chất của giao dịch và giá trị của hợp đồng gốc, nhằm cố định số tiền mà bên bảo lãnh phải trả cho bên nhận bảo lãnh khi nghĩa vụ được bảo lãnh bị vi phạm. Cần lưu ý các TCTD không nên ghi bảo lãnh theo tỷ lệ phần trăm (%) so với giá trị hợp đồng được bảo lãnh, tránh trường hợp khi giá trị hợp đồng gốc tăng thêm khiến cho giá trị bảo lãnh cũng tăng theo, sau khi bảo lãnh đã được phát hành.

Pháp luật hiện hành mở rộng theo hướng được bảo lãnh là các cá nhân, tổ chức kinh tế nếu đủ điều kiện theo luật định thì có thể được xem xét cấp bảo lãnh. Tuy nhiên nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động tín dụng tránh tình trạng các TCTD cấp vượt quá quy định về tỷ lệ an toàn vốn.

Luật các TCTD quy định:

- Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng không được vượt quá 15% vốn tự có của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô; tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng và người có liên quan không được vượt quá 25% vốn tự có của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô[37].

- Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng không được vượt quá 25% vốn tự có của tổ chức tín dụng phi ngân hàng; tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng và người có liên quan không được vượt quá 50% vốn tự có của tổ chức tín dụng phi ngân hàng[38].

- Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng, một khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó của ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô không được vượt quá tỷ lệ sau đây:

+ Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2026: 14% vốn tự có đối với một khách hàng; 23% vốn tự có đối với một khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó;

---

[36] Ngân hàng Nhà nước. (2022). *Thông tư số 11/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 của Ngân hàng Nhà nước quy định về bảo lãnh Ngân hàng*, Hà Nội, Điều 10

[37] Luật các Tổ chức tín dụng. (2010), khoản 1 Điều 128

[38] Luật các Tổ chức tín dụng. (2010), khoản 2 Điều 128

+ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2027: 13% vốn tự có đối với một khách hàng; 21% vốn tự có đối với một khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó;

+ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2027 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2028: 12% vốn tự có đối với một khách hàng; 19% vốn tự có đối với một khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó;

+ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2028 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2029: 11% vốn tự có đối với một khách hàng; 17% vốn tự có đối với một khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó;

+ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2029: 10% vốn tự có đối với một khách hàng; 15% vốn tự có đối với một khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó[39].

- Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng không được vượt quá 15% vốn tự có của tổ chức tín dụng phi ngân hàng; tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó không được vượt quá 25% vốn tự có của tổ chức tín dụng phi ngân hàng[40].

Từ quy định của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 đến Luật các tổ chức tín dụng năm 2024 ta thấy quy định giới hạn cấp tín dụng ngày càng bị thu hẹp đối với các chủ thể được cấp tín dụng nhằm đảm bảo an toàn vốn tránh tình trạng các TCTD cấp vốn cho một khách hàng hoặc một nhóm khách hàng quá số vốn cần thiết như vậy sẽ dẫn đến rủi ro cho các TCTD trong trường hợp không trả được nợ.

Do đó bên được bảo lãnh mặc dù pháp luật mở rộng cho phép các đối tượng được cấp bảo lãnh theo hướng rộng hơn. Tuy nhiên vẫn có những ràng buộc một số đối tượng không được cấp bảo lãnh hoặc cấp bảo lãnh nhưng không được vượt quá tỷ lệ theo quy định của pháp luật đối với từng chủ thể. Ngoài ra để đảm bảo hoạt động an toàn pháp luật còn quy định những đối tượng không được cấp bảo lãnh hoặc giới hạn giá trị bảo lãnh cho một số đối tượng cụ thể theo luật định.

1.3.2.2 Về trình tự thủ tục, điều kiện và phương thức thực hiện hoạt động bảo lãnh của ngân hàng

a. Trình tự thủ tục thực hiện hoạt động bảo lãnh

Xuất phát từ nguyên tắc bảo đảm quyền tự do kinh doanh, pháp luật các nước cũng như pháp luật Việt Nam chỉ quy định về nội dung thực hiện hoạt động BLNH mà không quy định trình tự, thủ tục thực hiện. Pháp luật cho phép các TCTD căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để tự quy định trình tự, thủ tục thực hiện hoạt động bảo lãnh ngân hàng phù hợp với tổ chức tín dụng của mình nhằm bảo đảm quyền lợi của các chủ thể khi tham gia hoạt động BLNH.

[39] Luật các Tổ chức tín dụng. (2024), khoản 1 Điều 136
[40] Luật các Tổ chức tín dụng. (2024), khoản 2 Điều 136

Trước đây, tại khoản 4 Điều 15 Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25/6/2015 quy định về bảo lãnh ngân hàng có quy định trình tự, thủ tục thực hiện BLNH, nhưng chỉ là một số trình tự, thủ tục cần thiết nhằm đảm bảo cho hoạt động BLNH được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả đến Thông tư số 11/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 quy định về bảo lãnh ngân hàng (thay thế Thông tư số 07/2015/TT-NHNN) không còn quy định về trình tự, thủ tục nữa mà cho phép "các TCTD tự ban hành quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thẩm định cấp bảo lãnh cho khách hàng, phù hợp với đặc điểm của từng TCTD và từng loại bảo lãnh". Cũng như các hình thức cấp tín dụng khác, TCTD chỉ thực hiện bảo lãnh khi khách hàng đề nghị bảo lãnh đáp ứng được các yêu cầu theo quy định của pháp luật và các quy định khác của TCTD đó. Để thực hiện hoàn tất một quy trình bảo lãnh, TCTD bảo lãnh, khách hàng đề nghị bảo lãnh và các bên có liên quan thường phải thực hiện theo trình tự từng bước được quy định tại Điều 14 Thông tư số 11/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022.

Thủ tục và trình tự là những yêu cầu ban đầu để ngân hàng, TCTD xem xét những điều kiện cơ bản nhất khi tiến hành cấp bảo lãnh.

Sơ đồ 1.3. Quy trình bảo lãnh theo quy định chung của NHNN

(Nguồn: Điều 14 Thông tư số 11/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022)

b. Điều kiện bảo lãnh

Ngoài những quy định về mặt thủ tục thì để phát hành Cam kết bảo lãnh, TCTD còn phải xem xét đến một số điều kiện như sau:

- Đối với khách hàng

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xem xét, quyết định cấp bảo lãnh, bảo lãnh đối ứng, xác nhận bảo lãnh cho khách hàng khi khách hàng đáp ứng các yêu cầu sau đây:

(i) Có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

(ii) Nghĩa vụ được bảo lãnh là nghĩa vụ tài chính hợp pháp;

(iii) Được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp bảo lãnh đánh giá có khả năng hoàn trả lại số tiền mà tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải trả thay khi thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

Tổ chức tín dụng, chi nhán ngân hàng nước ngoài không được bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán trái phiếu của các doanh nghiệp phát hành với mục đích: cơ cấu lại các khoản nợ của chính doanh nghiệp phát hành; góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp khác và tăng quy mô vốn hoạt động[41].

- *Đối với khách hàng là người không cư trú*

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được bảo lãnh cho khách hàng tổ chức là người không cư trú và phải đáp ứng một trong những yêu cầu sau (khách hàng là tổ chức tín dụng ở nước ngoài không phải đáp ứng yêu cầu này):

(i) Khách hàng là doanh nghiệp thành lập và hoạt động tại nước ngoài có vốn góp của doanh nghiệp Việt Nam dưới hình thức đầu tư quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 52 Luật Đầu tư hoặc dưới hình thức đầu tư khác quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 52 Luật Đầu tư;

(ii) Khách hàng ký quỹ đủ 100% giá trị bảo lãnh hoặc có bảo đảm đủ 100% giá trị bảo lãnh bằng tài sản của khách hàng gồm số dư tiền gửi tại chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bảo lãnh và chứng chỉ tiền gửi của chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bảo lãnh;

(ii) Bên nhận bảo lãnh là người cư trú.

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được bảo lãnh bằng ngoại tệ đối với khách hàng tổ chức là người không cư trú, trừ trường hợp bảo lãnh trên cơ sở bảo lãnh đối ứng của tổ chức tín dụng ở nước ngoài hoặc xác nhận bảo lãnh cho nghĩa vụ bảo lãnh của tổ chức tín dụng ở nước ngoài mà bên nhận bảo lãnh là người cư trú.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi thực hiện bảo lãnh bằng ngoại tệ cho khách hàng là người không cư trú phải:

(i) Tuân thủ quy định pháp luật về hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay ra nước ngoài và thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú;

(ii) Có quy trình đánh giá, quản lý rủi ro tín dụng, trong đó có rủi ro trong bảo lãnh đối với người không cư trú.

Ngoài các quy định tại Điều này, các nội dung khác về việc bảo lãnh đối với khách hàng là người không cư trú phải thực hiện theo quy định tương ứng tại Thông tư

[41] Ngân hàng Nhà nước. (2022). *Thông tư số 11/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 của Ngân hàng Nhà nước quy định về bảo lãnh Ngân hàng*, Hà Nội. Điều 11

số 11/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 của Ngân hàng Nhà nước quy định về bảo lãnh Ngân hàng[42].

- *Về năng lực tài chính*: Như đã nói ở trên, BLNH cũng là một hình thức cấp tín dụng của các TCTD. Khi xem xét và quyết định cấp tín dụng, TCTD luôn tính đến khả năng và phương án thu hồi nợ khi nghĩa vụ đến hạn. Khả năng trả nợ của khách hàng là yếu tố tiên quyết để TCTD quyết định xem xét có nên hay không việc cung cấp tín dụng cho khách hàng đó. Do đó, yêu cầu đặt ra đối với khách hàng đề nghị bảo lãnh là phải có năng lực tài chính và có tín nhiệm trong quan hệ tín dụng, thanh toán với ngân hàng.

Năng lực tài chính của khách hàng thể hiện ở nguồn trả nợ ; kết quả kinh doanh và lợi nhuận đạt được;…tùy từng trường hợp khách hàng là cá nhân hay tổ chức, TCTD đưa ra những yêu cầu về việc chứng minh năng lực tài chính cũng khác nhau.

Các chủ đầu tư muốn được ngân hàng bảo lãnh thì phải ký quỹ bằng tiền mặt hoặc phải có tài sản bảo đảm có giá trị tương đương 100% giá trị được bảo lãnh. Với nhiều doanh nghiệp, đây là điều kiện khó, thậm chí là bất khả thi. Hơn nữa, nếu ký quỹ thì số tiền này sẽ bị để trong ngân hàng, khi đó chủ đầu tư không có dòng tiền lưu động nên rất khó đảm bảo tiến độ dự án.

Đối với các tổ chức kinh tế mới thành lập việc chứng minh năng lực tài chính là khá khó khăn do chưa hoạt động nhiều nên chưa phát sinh nhiều về các hoạt động tài chính. Chưa chứng minh được khả năng tài chính của mình trong hoạt động kinh doanh. Đây cũng là một trong những điểm bất lợi cho các tổ chức mới thành lập.

Theo quy định tại Điều 13 Thông tư 11/2022/TT-NHNN có quy định về bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai như sau:

Về năng lực thực hiện bảo lãnh: Ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai khi:

- Trong giấy phép thành lập và hoạt động hoặc tại văn bản sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng thương mại có quy định nội dung hoạt động bảo lãnh ngân hàng;

- Không bị cấm, hạn chế, đình chỉ, tạm đình chỉ thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai.

Ngân hàng Nhà nước công bố công khai danh sách ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai trong từng thời kỳ trên Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước.

Chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực có cam kết thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn

[42] Ngân hàng Nhà nước. (2022). *Thông tư số 11/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 của Ngân hàng Nhà nước quy định về bảo lãnh Ngân hàng*, Hà Nội. Điều 12

giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng. Số tiền bảo lãnh cho một dự án nhà ở hình thành trong tương lai tối đa bằng tổng số tiền chủ đầu tư được phép nhận ứng trước của bên mua[43] và các khoản tiền khác (nếu có) theo hợp đồng mua, thuê mua nhà ở.

Như vậy, Thông tư 11/2022/TT-NHNN yêu cầu bắt buộc dự án phải có bảo lãnh từ ngân hàng trước khi bán cùng với những yêu cầu khắc khe đối sẽ khiến doanh nghiệp gặp khó khăn hơn: khó vay thêm vốn tín dụng từ ngân hàng, năng lực tài chính không đủ điều kiện thực hiện vay tín chấp và tổng chi phí bảo lãnh một dự án là rất lớn (1-2%/giá trị căn hộ, nếu cả dự án có 1.000 căn thì chi phí bảo lãnh rất lớn).

c. Phương thức thực hiện hoạt động bảo lãnh

Ở nước ta, quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng đang bước vào giai đoạn bùng nổ khi các ngân hàng liên tục cải tiến công nghệ, kĩ thuật theo hướng hiện đại hóa. Ngày 30/9/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 11/2022/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng trong đó, tại Điều 9 có điểm mới nổi bật là hoạt động bảo lãnh điện tử. Theo Thông tư số 11/2022/TT-NHNN, NHNN cho phép tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách hàng được lựa chọn thực hiện hoạt động bảo lãnh ngân hàng qua việc sử dụng các phương tiện điện tử. Trước đây, tại Thông tư 07/2015/TT-NHNN không quy định về phương thức phát hành bảo lãnh điện tử, mà chỉ có trường hợp giao dịch thông qua mạng thông tin liên lạc quốc tế giữa các tổ chức tín dụng (bao gồm: bảo lãnh trực tiếp, bảo lãnh gián tiếp,…).

Đối với hoạt động bảo lãnh điện tử, pháp luật đã cho phép ngân hàng tự quyết định biện pháp, hình thức, công nghệ thực hiện hoạt động bảo lãnh điện tử đối với toàn bộ hoặc từng khâu trong quy trình bảo lãnh và tự chịu rủi ro phát sinh (nếu có) và phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau: Có giải pháp, công nghệ kĩ thuật đảm bảo tính chính xác, bảo mật, an toàn trong quá trình thu thập, sử dụng, kiểm tra thông tin, dữ liệu; có biện pháp kiểm tra, đối chiếu, cập nhật, xác minh thông tin, dữ liệu; có biện pháp ngăn chặn các hành vi giả mạo, can thiệp, chỉnh sửa làm sai lệch thông tin, dữ liệu; có biện pháp đánh giá, quản lí, kiểm soát rủi ro; phân công trách nhiệm cụ thể của từng bộ phận, cá nhân có liên quan trong hoạt động bảo lãnh điện tử và trong việc quản lí, giám sát rủi ro.

Trong trường hợp TCTD có thể nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng qua phương tiện điện tử khi khách hàng lần đầu thiết lập mối quan hệ với TCTD thì phải có giải pháp, công nghệ kĩ thuật để thu thập, kiểm tra và đối chiếu thông tin, đảm bảo tối thiểu một số nội dung sau:

Thứ nhất, đối với khách hàng là cá nhân phải bảo đảm sự khớp đúng giữa thông tin nhận biết khách hàng, dữ liệu sinh trắc học của khách hàng - đây là các yếu tố, đặc điểm sinh học gắn liền với khách hàng thực hiện định danh, khó làm giả, có tỉ lệ trùng nhau

[43] Luật Kinh doanh bất động sản (2014). Điều 57

thấp như vân tay, khuôn mặt, mống mắt, giọng nói và các yếu tố sinh trắc học khác với các thông tin, yếu tố sinh trắc học tương ứng trên giấy tờ cần thiết nhằm nhận biết khách hàng theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, theo yêu cầu của TCTD, hoặc với dữ liệu định danh cá nhân được xác thực bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bởi tổ chức cung cấp dịch vụ xác thực điện tử theo quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử.

Thứ hai, đối với khách hàng là tổ chức phải bảo đảm sự khớp đúng giữa thông tin nhận biết khách hàng tổ chức theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tình trạng pháp lí của tổ chức với thông tin, dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng kí doanh nghiệp hoặc với thông tin, dữ liệu được xác thực bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bởi tổ chức cung cấp dịch vụ xác thực điện tử theo quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử; thông tin về cá nhân đại diện hợp pháp của tổ chức thực hiện giao dịch: Thực hiện nhận biết và xác minh thông tin của cá nhân thực hiện giao dịch theo quy định về nhận biết và xác minh khách hàng cá nhân theo quy định pháp luật nhằm bảo đảm khớp đúng với thông tin người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của tổ chức căn cứ giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp và văn bản ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền).

Trường hợp TCTD nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng qua phương tiện điện tử thì giá trị của mỗi cam kết bảo lãnh phát hành cho khách hàng cá nhân không được vượt quá 4 tỉ đồng và cho khách hàng tổ chức không được vượt quá 45 tỉ đồng, trừ các trường hợp sau: Thông tin nhận biết khách hàng được xác thực bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc được xác thực điện tử thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ xác thực điện tử theo quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử; khách hàng gửi đề nghị cấp bảo lãnh bằng điện xác thực thông qua hệ thống SWIFT; thông tin khách hàng và nghĩa vụ được bảo lãnh được đối chiếu khớp đúng thông qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan hoặc hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; khách hàng sử dụng chữ kí số theo quy định của pháp luật khi đề nghị cấp bảo lãnh hoặc kí thỏa thuận cấp bảo lãnh với TCTD, khách hàng là TCTD.

Theo quy định, hệ thống thông tin thực hiện các hoạt động bảo lãnh điện tử phải tuân thủ theo quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên theo quy định của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và quy định của NHNN về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng. TCTD phải lưu trữ, bảo quản thông tin, dữ liệu bảo lãnh điện tử theo quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn, bảo mật và được sao lưu dự phòng đáp ứng tính đầy đủ, toàn vẹn của hồ sơ cho phép truy cập, sử dụng khi cần thiết hoặc để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu, giải quyết tra soát, khiếu nại, tranh chấp và cung cấp thông tin khi có yêu cầu từ cơ quan quản lí nhà nước có thẩm quyền.

Do là phương thức bảo lãnh còn mới, hạn chế về quy định và hướng dẫn triển khai áp dụng nên hệ thống các ngân hàng nói chung và thực tiễn tại Ngân hàng TMCP Quân

đội, Chi nhánh Cần Thơ nói riêng còn gặp nhiều khó khăn trong áp dụng phương thức này. Nhà nước cần tiếp tục ban hành hướng dẫn hoàn thiện và cần có những nghiên cứu để làm rõ nội dung liên quan, góp phần hoàn thiện hoạt động bảo lãnh điện tử trong thời gian tới.

1.3.2.3 Giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động bảo lãnh của ngân hàng

Cũng như pháp luật của nhiều quốc gia khác, pháp luật Việt Nam chưa có quy định riêng về giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động BLNH mà sử dụng các quy định chung về giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại để giải quyết. Tại Việt Nam về phương thức giải quyết tranh chấp, luật áp dụng để giải quyết tranh chấp và chủ thể giải quyết tranh chấp được thực hiện qua một số hình thức như sau:

a. Về phương thức giải quyết tranh chấp:

Để giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh thương mại, Luật Thương mại có quy định về các phương thức giải quyết tranh chấp như sau: thương lượng giữa các bên; hoà giải giữa các bên do một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân được các bên thoả thuận chọn làm trung gian hoà giải; giải quyết tại trọng tài hoặc tòa án[44].

Theo đó các bên có thể tự thỏa thuận một trong các phương án giải quyết tranh chấp đã được quy định trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích giữa các bên và tuân thủ theo quy định của pháp luật

b. Về luật áp dụng giải quyết tranh chấp

Các bên tham gia bảo lãnh ngân hàng, bảo lãnh đối ứng, xác nhận bảo lãnh, đồng bảo lãnh được thỏa thuận áp dụng tập quán thương mại theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật các tổ chức tín dụng. Việc xử lý tranh chấp phát sinh trong nghiệp vụ bảo lãnh thực hiện theo thỏa thuận của các bên phù hợp với quy định của pháp luật. Trường hợp bảo lãnh có yếu tố nước ngoài, các bên có thể thỏa thuận luật áp dụng, cơ quan giải quyết tranh chấp (bao gồm cả tòa án hoặc trọng tài thương mại nước ngoài) để giải quyết tranh chấp về giao dịch bảo lãnh[45].

Như vậy pháp luật Việt Nam công nhận quyền của các bên trong việc lựa chọn áp dụng giải quyết tranh chấp. Với quy định này các bên chủ thẻ có thể lựa chọn luật Việt Nam, luật nước ngoài, hoặc các Bộ luật quy tắc do ICC ban hành làm cơ sở pháp lý để giải quyết tranh chấp phát sinh.

Trường hợp các bên không có thoả thuận về luật áp dụng thì theo nguyên tắc được nêu tại Điều 683 BLDS năm 2015: quyền và nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng được xác định theo pháp luật của nước có mối liên hệ gắn bó nhất với hợp đồng đó.

c. Về chủ thể giải quyết tranh chấp

---

[44] Luật Thương mại (2005). Điều 317.

[45] Ngân hàng Nhà nước. (2022). *Thông tư số 11/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 của Ngân hàng Nhà nước quy định về bảo lãnh Ngân hàng*, Hà Nội. Điều 8

Như trên đã nêu, phương thức giải quyết tranh chấp sẽ quyết định chủ thể giải quyết tranh chấp. Trường hợp phương thức giải quyết tranh chấp tại tòa án hoặc trọng tài, thì chủ thể giải quyết tranh chấp chính là các cơ quan này.

Tuy nhiên, pháp luật hiện hành về giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động BLNH hiện nay vẫn còn một số bất cập như:

Một là, pháp luật chưa có cơ chế pháp lý riêng biệt để giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động BLNH. Hoạt động BLNH nói riêng và hoạt động ngân hàng nói chung là hoạt động mang tính đặc thù xuất phát từ vai trò chủ thể và tính chất của hoạt động này, do đó cần một cơ chế pháp lý riêng biệt nhằm giải quyết nhanh chóng các tranh chấp phát sinh. Do chưa có cơ chế pháp lý riêng để giải quyết nên các tranh chấp phát sinh thường mất nhiều thời gian. Thực tế, các vụ tranh chấp phải giải quyết tại toà án có thể kéo dài nhiều năm.

Hai là, ngân hàng chỉ phát sinh trách nhiệm bảo lãnh khi bên được bảo lãnh vi phạm nghĩa vụ, vấn đề vi phạm nghĩa vụ chỉ được chứng minh bởi cơ quan có thẩm quyền là Tòa án, để vụ việc được giải quyết tại Tòa án thì các bên trong quan hệ bảo lãnh phải trải qua quy trình tố tụng rất dài mới chứng minh được vi phạm của bên được bảo lãnh, khi đó ngân hàng mới phát sinh trách nhiệm bảo lãnh, do đó ảnh hưởng đến quyền lợi của bên nhận bảo lãnh.

Kết luận chương 1

Chương 1 của luận văn đã trình bày khái quát, đặc điểm, vai trò của pháp luật về bảo lãnh ngân hàng. Dưới góc độ lý luận cũng như pháp lý có thể có nhiều cách định nghĩa khác nhau về bảo lãnh ngân hàng, tuy nhiên tựu chung lại có thể thấy bảo lãnh ngân hàng là cam kết của ngân hàng đối với bên nhận bảo lãnh để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên được bảo lãnh. Tùy mục đích sử dụng, phương thức phát hành và bản chất chứng từ mà bảo lãnh ngân hàng có thể được phân thành nhiều loại khác nhau như căn cứ vào mục đích bảo lãnh, đối tượng bảo lãnh,.... Tuy nhiên đây cũng là một trong những hoạt động chứa nhiều rủi ro cho các bên tham gia.

Hệ thống pháp luật về bảo lãnh ngân hàng được hoàn thiện qua từng thời kỳ, đáp ứng nhu cầu thay đổi đa dạng của thị trường với các quy định cụ thể về chủ thể, hình thức, nội dung của bảo lãnh ngân hàng…. Tuy nhiên, các văn bản hiện hành còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn áp dụng nên việc sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế văn bản hiện hành về bảo lãnh ngân hàng là một thực trạng cấp thiết.

Trong chương này, tác giã cũng phân tích về thực trạng hoạt động bảo lãnh và một số thực trạng áp dụng pháp luật trong bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội, Chi nhánh Cần Thơ, điểm qua sơ lược về hoạt động bảo lãnh, quy trình, quy định nội bộ về bảo lãnh. Trên cơ sở đó, đi sâu vào làm rõ một số thực trạng đã phát sinh trong công tác áp dụng pháp luật về hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội, Chi nhánh Cần

Thơ thông qua việc việc phân tích một số vấn đề cụ thể trong áp dụng pháp luật, các bất cập của quy định pháp luật trong hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội, Chi nhánh Cần Thơ.

Những tìm hiểu, phân tích một số thực tế trong việc áp dụng pháp luật bảo lãnh trong chương này là cơ sở để tác giả đưa ra một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật cũng như hiệu quả của hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội, Chi nhánh Cần Thơ trong chương 2.

CHƯƠNG 2

THỰC TIỄN ÁP DỤNG, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG TỪ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI, CHI NHÁNH CẦN THƠ

Dựa trên việc nghiên cứu và phân tích ở chương 1, chương 2 sẽ phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật, chỉ ra một số nguyên nhân chính dẫn đến các bất cập trong việc áp dụng pháp luật về bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội, Chi nhánh Cần Thơ.

Đầu tiên, một số quy định pháp luật về bảo lãnh không phù hợp với hoạt động thực tế của ngân hàng, gây khó khăn trong việc tuân thủ và thực thi pháp luật. Thứ hai, quy định về bảo lãnh vẫn còn nhiều mâu thuẫn, chồng chéo, và hướng dẫn không rõ ràng, dẫn đến sự lúng túng trong việc áp dụng và thiếu khung pháp lý an toàn. Cuối cùng, việc giải quyết tranh chấp liên quan đến bảo lãnh vẫn còn nhiều khó khăn do thiếu cơ chế giải quyết triệt để từ các cơ quan có thẩm quyền.

Dựa vào những vấn đề này, tác giả sẽ đưa ra các đề xuất nhằm góp phần thiện pháp luật về bảo lãnh, giúp thúc đẩy hoạt động này phát triển và tăng cường hiệu quả trong việc áp dụng pháp luật về bảo lãnh. Các đề xuất này tập trung vào việc đánh giá lại các quy định hiện hành để áp dụng chúng một cách thống nhất và phù hợp với thực tế, cũng như kiểm tra hệ thống quy định để phát hiện và đề xuất sửa đổi kịp thời những quy định mâu thuẫn và chồng chéo.

2.1. Những kết quả đạt được và một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo lãnh của ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội, Chi nhánh Cần Thơ

2.1.1. Những kết quả đạt được

Từ việc phân tích hoạt động bảo lãnh qua những chỉ tiêu định tính và định lượng, có thể thấy hoạt động bảo lãnh của Ngân hàng TMCP Quân Đội, chi nhánh Cần Thơ từ năm 2020 đến nay đã đạt được một số kết quả nhất định.

Trong các năm qua hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân Đội, chi nhánh Cần Thơ luôn có sự tăng trưởng ổn định, đóng góp ngày càng nhiều vào doanh thu chung của Ngân hàng. Có thể thấy mức tăng trưởng qua các năm là khác nhau, có những biến động tăng nhanh/chậm, điều này tùy thuộc vào chính sách phát triển của Ngân hàng cũng như những biến động của chính sách tín dụng chung của Nhà nước trong từng thời kỳ.

Doanh số bảo lãnh ngày càng tăng và cùng với nó là chất lượng các khoản bảo lãnh ngày càng được nâng cao, số lượng khách hàng tham gia bảo lãnh ngày càng nhiều, phong phú về hình thức các thành phần kinh tế bảo lãnh. Các loại hình BLNH ngày càng được nâng cao, mở rộng và phát triển, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong nền kinh tế thị trường hiện nay.

Bảo lãnh ngân hàng cũng đem lại nguồn thu phí dịch vụ ổn định, giúp các ngân hàng nâng cao tỷ trọng thu từ hoạt động dịch vụ nhằm gia tăng lợi nhuận. Cùng với sự phát triển nghiệp vụ bảo lãnh là trình độ cán bộ về nghiệp vụ cũng được nâng cao để đưa ra quyết định đúng đắn lựa chọn các dự án bảo lãnh mang tính khả thi. Chính điều này đã nâng cao uy tín của Ngân hàng TMCP Quân, giúp Ngân hàng TMCP Quân Đội nói chung tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, tạo mối quan hệ với các khách hàng truyền thống và thu hút thêm lượng khách hàng mới.

Sản phẩm bảo lãnh của Ngân hàng TMCP Quân Đội khá phong phú, đáp ứng được nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Với kinh nghiệm phát triển hoạt động bảo lãnh trong nhiều năm, Ngân hàng TMCP Quân Đội đã có sự vận dụng các thông lệ quốc tế phù hợp với luật pháp Việt Nam trong việc phát hành cam kết bảo lãnh để tạo ra các cam kết bảo lãnh đảm bảo tính chặt chẽ, chuẩn xác, góp phần hạn chế rủi ro cho bên được bảo lãnh và làm giảm các tranh chấp không đáng có giữa các bên khi thực hiện. Bên cạnh đó, với uy tín tạo dựng được cả trong và ngoài nước, cam kết bảo lãnh do Ngân hàng TMCP Quân Đội phát hành đã tạo sự tin tưởng cao, đặc biệt là trong các hoạt động quốc tế.

Việc thiết lập mạng lưới ngân hàng đại lý rộng khắp cũng là một điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng TMCP Quân Đội trong các hoạt động giao dịch quốc tế. Việc mở rộng mạng lưới các ngân hàng đại lý, cũng là cơ hội để Ngân hàng TMCP Quân Đội mở rộng hợp tác quốc tế cũng như học hỏi kinh nghiệm, nâng cao năng lực quản trị trong

hoạt động bảo lãnh nói riêng và hoạt động kinh doanh nói chung. Hiện nay Ngân hàng TMCP Quân Đội đã có 2 chi nhánh nước ngoài ở Lào, Campuchia và thêm một phòng đại diện ở nước Nga. Ngoài ra Ngân hàng TMCP Quân Đội Ngân hàng TMCP Quân Đội, chi nhánh Cần Thơ cũng đã không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, quy trình nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng nghiệp vụ khác như thanh toán, chuyển tiền, quy trình, thủ tục nhanh gọn nhằm bổ trợ, bổ sung giúp nghiệp vụ bảo lãnh có điều kiện phát triển.

Thông qua hoạt động bảo lãnh ngân hàng, nhiều doanh nghiệp đã tìm kiếm được sự tin tưởng từ đối tác để từ đó tận dụng được cơ hội kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh doanh và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

2.1.2. Một số vướng mắc phát sinh trong thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo lãnh của ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội, Chi nhánh Cần Thơ

2.1.2.1 Pháp luật quy định về phạm vi bảo lãnh

Theo các quy tắc quốc tế về bảo lãnh như Công ước của Liên hợp quốc về bảo lãnh độc lập và tín dụng thư hay Bộ quy tắc bảo lãnh theo yêu cầu URDG của ICC, phạm vi bảo lãnh được xác định bằng số tiền bảo lãnh (guarantee amount) mà bên bảo lãnh cam kết trả thay khi phát sinh sự kiện bảo lãnh. Số tiền bảo lãnh phải được xác định trước giữa các bên hoặc có thể xác định được trên cơ sở yêu cầu đòi tiền của bên nhận bảo lãnh, kèm theo các chứng từ, theo đúng các điều khoản và các điều kiện về chứng từ được ghi nhận trên bề mặt của thư bảo lãnh. Do đó, theo các quy định quốc tế về bảo lãnh ngân hàng, phạm vi bảo lãnh không có giới hạn cụ thể và chỉ được xác định trên cơ sở thỏa thuận của các bên được ghi nhận trong thư bảo lãnh được ngân hàng bảo lãnh phát hành.

Tại Việt Nam, các quy định pháp luật hiện hành hiện nay quy định về phạm vi bảo lãnh là một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ được bảo lãnh. Như vậy, so với các quy định quốc tế về bảo lãnh ngân hàng, phạm vi bảo lãnh của các ngân hàng tại Việt Nam bị bó hẹp hơn, chỉ giới hạn trong phần giá trị nghĩa vụ được bảo lãnh.

Trong thực tế hoạt động, Ngân hàng TMCP Quân đội gặp không ít các tranh chấp phát sinh liên quan đến phạm vi bảo lãnh, chủ yếu là việc bên nhận bảo lãnh thường đòi tiền bảo lãnh vượt quá phạm vi bảo lãnh hoặc vượt quá phần nghĩa vụ bị vi phạm.

Ví dụ: Năm 2019, Doanh nghiệp A được Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội cấp bảo lãnh thanh toán trị giá 500.000.000 VNĐ. Trong thư bảo lãnh "vô điều kiện" phát hành cho bên thụ hưởng có nội dung: "số tiền bảo lãnh trong mọi trường hợp không vượt quá 500.000.000 VNĐ; MB sẽ thực hiện thanh toán thay phần nghĩa vụ thanh toán mà Doanh nghiệp A không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ theo Hợp đồng mua bán số...". Trong thời hạn bảo lãnh, Ngân hàng TMCP Quân Đội nhận được yêu cầu đòi tiền từ bên thụ hưởng, số tiền đòi bảo lãnh là 500.000.000 VNĐ kèm thông báo Doanh nghiệp A đã "vi phạm" nghĩa vụ thanh toán.

Do bảo lãnh thanh toán là vô điều kiện nên Ngân hàng TMCP Quân Đội thực hiện thanh toán ngay cho bên thụ hưởng số tiền 500.000.000 VNĐ, tuy nhiên khi quay lại đòi tiền bảo lãnh từ Doanh nghiệp A thì Doanh nghiệp này từ chối trả số tiền Ngân hàng TMCP Quân Đội đã bảo lãnh thay mà chỉ đồng ý nhận nợ với khoản tiền là 200.000.000 VNĐ với lý do là họ đã "vi phạm" nghĩa vụ thanh toán nhưng chỉ chậm thanh toán theo hợp đồng là 200.000.000 VNĐ.

Sau khi đàm phán thương lượng nhưng không thành, Ngân hàng TMCP Quân Đội làm đơn khởi kiện ra Tòa án, yêu cầu doanh nghiệp A hoàn trả lại toàn bộ số tiền Ngân hàng TMCP Quân Đội đã thực hiện bảo lãnh. Căn cứ trên Hợp đồng cấp bảo lãnh giữa Ngân hàng TMCP Quân Đội và doanh nghiệp A với nội dung " Ngân hàng TMCP Quân Đội thực hiện phát hành bảo lãnh vô điều kiện cho bên thụ hưởng, theo đó Doanh nghiệp A cam kết nhận nợ vô điều kiện đối với toàn bộ số tiền Ngân hàng TMCP Quân Đội đã thực hiện bảo lãnh trong phạm vi bảo lãnh..." và các văn bản chứng minh số tiền 500.000.000 VNĐ Ngân hàng TMCP Quân Đội đã chuyển cho bên thụ hưởng để thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, Tòa án quyết định Bên Thụ hưởng phải hoàn trả lại cho Ngân hàng TMCP Quân Đội số tiền yêu cầu bảo lãnh vượt quá so với nghĩa vụ thanh toán bị vi phạm, trị giá 300.000.000 VNĐ; Doanh nghiệp A nhận nợ số tiền Ngân hàng TMCP Quân Đội đã thực hiện bảo lãnh theo thư bảo lãnh đã phát hành, trị giá 200.000.000 VNĐ[46].

Việc xác định phạm vị bảo lãnh vô cùng quan trọng đối với các TCTD vì nó liên quan đến việc phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Như đã phân tích từ ví dụ nêu trên ta thấy việc Bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ của mình theo yêu cầu của bên nhận bảo lãnh đối với bảo lãnh vô điều kiện. Theo đó bên bảo lãnh phải thanh toàn vô điều kiện khi nhận được yêu cầu đòi tiền từ bên nhận bảo lãnh. Nhưng trong trường hợp này bên được bảo lãnh chỉ vi phạm một phần trong toàn bộ nghĩa vụ bảo lãnh. Do đó cần quy định rõ hơn về phạm vi bảo lãnh đối với các trường hợp mà bên được bảo lãnh đã thực hiện một phần nghĩa vụ của mình.

Theo đó nếu bên được bảo lãnh có thể chứng minh được mình đã thực hiện một phần nghĩa vụ của mình trong toàn bộ nghĩa vụ được bảo lãnh thì bên bảo lãnh chỉ thanh toán phần nghĩa vụ còn lại trong tổng nghĩa vụ bảo lãnh.

2.1.2.2. Vấn đề bảo lãnh vô điều kiện và tính độc lập của bảo lãnh

Hiện nay trên thế giới hình thức bảo lãnh vô điều kiện rất phát triển và được áp dụng rộng rãi trong hoạt động thương mại quốc tế vì những ưu điểm của hình thức này là thủ tục thanh toán tiền bảo lãnh đơn giản, nhanh gọn, chỉ khi bên nhận bảo lãnh có văn bản yêu cầu thanh toán trong phạm vi số tiền cam kết bảo lãnh thì ngân hàng phát hành sẽ thực hiện nghĩa vụ trả tiền bảo lãnh ngay mà không cần xem xét đến việc thực hiện nghĩa vụ gốc giữa hai bên. Pháp luật Việt Nam hiện hành chưa có một bộ quy chế

[46] Ngân hàng TMCP Quân đội, chi nhánh Cần Thơ. (2023). *Bản báo cáo tóm tắt nội dung các tranh chấp*.

cụ thể nào về vấn đề này. Theo các quy định pháp luật hiện hành thì căn cứ để ngân hàng phát hành bảo lãnh và việc bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán đã cam kết[47]. Các ngân hàng hiện nay thường cho rằng khi chưa có sự vi phạm nghĩa vụ của bên được bảo lãnh thì chưa phát sinh việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. Tương tự, quy định nội bộ của MB (Quyết định số 2821/QĐ-HS ban hành quy định hoạt động bảo lãnh tại MB) cũng quy định điều kiện để thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đó là:

- Nghĩa vụ phát sinh trong thời hạn hiệu lực của thư bảo lãnh ;

- Có văn bản của bên nhận bảo lãnh đề nghị thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đối với người nhận bảo lãnh (bản gốc);

- Các tài liệu chứng minh bên được bảo lãnh chưa thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh (nếu có). Trường hợp thư bảo lãnh nêu điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thì bắt buộc phải có tài liệu chứng minh điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

Trên thực tế hoạt động, Ngân hàng TMCP Quân Đội đã phát sinh rất nhiều trường hợp về việc phát hành chứng thư bảo lãnh vô điều kiện không hủy ngang nhưng lại kèm theo điều kiện là bên nhận bảo lãnh phải gửi hồ sơ chứng minh vi phạm kèm theo văn bản yêu cầu thanh toán nghĩa vụ bảo lãnh. Điều khoản như trên thường dẫn tới ràng buộc cho cả 3 bên: ngân hàng, bên nhận bảo lãnh và bên được bảo lãnh. Ngay cả khi bên nhận bảo lãnh cung cấp hồ sơ đầy đủ và yêu cầu thanh toán bảo lãnh, thì bên được bảo lãnh cũng có thể cho rằng, họ chưa vi phạm nghĩa vụ thanh toán. Trong khi đó, cơ quan có thể đưa ra phán quyết cuối cùng về việc họ có vi phạm hay không là cơ quan tài phán có thẩm quyền. Nếu chỉ dừng ở mức tranh chấp giữa hai bên, ngân hàng không thể biết được có vi phạm hay không. Nếu không được khách hàng chấp nhận là đã vi phạm, thì ngân hàng không thể thực hiện thanh toán bảo lãnh, bởi sau đó ngân hàng sẽ không thể buộc khách hàng nhận nợ được.

Ví dụ: Tháng 9/2020, một chi nhánh của ngân hàng TMCP Quân đội phát hành thư bảo lãnh thanh toán "vô điều kiện" cho khách hàng theo Hợp đồng mua bán nông sản và điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh là "Bên thụ hưởng gửi văn bản thông báo về việc Bên mua hàng đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán kèm theo tất các các văn bản, tài liệu, chứng cứ chứng minh vi phạm của Bên mua hàng".

Khi hàng đã giao, bên nhận bảo lãnh yêu cầu thanh toán tiền nhưng bên được bảo lãnh lại cho rằng nông sản giao có chất lượng thấp nên chỉ thanh toán khi bên nhận bảo lãnh đổi hàng, khiến xảy ra tranh chấp. Bên bán hàng gửi yêu cầu đòi tiền kèm thông báo về việc bên mua hàng đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán đến Ngân hàng TMCP Quân Đội, nhưng bên mua hàng lại cho rằng họ vẫn chưa vi phạm nghĩa vụ thanh toán do bên

[47] Ngân hàng Nhà nước. (2022). *Thông tư số 11/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 của Ngân hàng Nhà nước quy định về bảo lãnh Ngân hàng*, Hà Nội. Điều 3

bán hàng giao hàng không đúng chất lượng. Ngân hàng TMCP Quân đội rơi vào bế tắc vì không biết nên thanh toán hay không thanh toán nghĩa vụ bảo lãnh.

Tranh chấp kéo dài và các bên đã thống nhất đưa vụ việc ra giải quyết tại Tòa án và được giải quyết như sau: Bên giao hàng đã giao hàng đúng chất lượng theo quy định tại hợp đồng mua bán, bên mua hàng có trách nhiệm thanh toán số tiền hàng còn thiếu và các khoản lãi chậm trả và phí phạt theo các quy định của hợp đồng mua bán. Ngân hàng TMCP Quân Đội đã phát hành bảo lãnh vô điều kiện, theo đó Bên giao hàng đã gửi thư đòi tiền kèm thông báo về việc bên mua hàng đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán trong thời hạn có hiệu lực của thư bảo lãnh nên Ngân hàng TMCP Quân Đội phải thực hiện trách nhiệm bảo lãnh theo đúng cam kết đã phát hành[48].

Do đó, để hạn chế những rủi ro liên quan đến việc thanh toán khoản tiền bảo lãnh cho bên nhận bảo lãnh, khi phát sinh nhu cầu phát hành bảo lãnh vô điều kiện, tức là chỉ cần nhận được văn bản yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thanh toán thì ngân hàng lập tức thanh toán cho bên nhận bảo lãnh và nên quy định trong hợp đồng cấp bảo lãnh ký với khách hàng điều khoản yêu cầu khách hàng nhận nợ bắt buộc và vô điều kiện nếu Ngân hàng TMCP Quân Đội đã thanh toán tiền bảo lãnh thanh toán cho bên nhận bảo lãnh, nếu khách hàng không trả được nợ vay với MB thì MB có quyền xử lý tài sản bảo đảm của khách hàng. Cách làm này vừa bảo đảm việc thông suốt trong quan hệ bảo lãnh, vừa nâng cao uy tín ngân hàng, vì việc thanh toán đúng hạn.

2.1.2.3 Về ủy quyền thụ hưởng bảo lãnh

Ủy quyền thụ hưởng bảo lãnh là một hình thức chuyển quyền thụ hưởng của mình cho một chủ thể khác. Đây là một hình thức được quy định theo pháp luật Việt Nam.

Tại Thông tư 11 có nêu về quyền của bên bảo lãnh: "*Chuyển nhượng quyền, nghĩa vụ của mình cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác theo thỏa thuận của các bên liên quan và phù hợp với quy định của pháp luật"*[49].

Đối với bên được bảo lãnh: "*Chuyển nhượng quyền, nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận của các bên liên quan phù hợp với quy định của pháp luật. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật khi các bên liên quan thực hiện chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ bảo lãnh của các bên đối với khoản bảo lãnh*"[50].

Đối với bên nhận bảo lãnh được: "*chuyển nhượng quyền, nghĩa vụ của mình cho tổ chức, cá nhân khác theo thỏa thuận của các bên liên quan phù hợp với quy định của pháp luật*"[51].

---

[48] Ngân hàng TMCP Quân đội, chi nhánh Cần Thơ. (2023). *Bản báo cáo tóm tắt nội dung các tranh chấp*.

[49] Ngân hàng Nhà nước. (2022). *Thông tư số 11/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 của Ngân hàng Nhà nước quy định về bảo lãnh Ngân hàng*, Hà Nội. khoản 12 Điều 27

[50] Ngân hàng Nhà nước. (2022). *Thông tư số 11/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 của Ngân hàng Nhà nước quy định về bảo lãnh Ngân hàng*, Hà Nội. khoản 1 Điều 31

[51] Ngân hàng Nhà nước. (2022). *Thông tư số 11/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 của Ngân hàng Nhà nước quy định về bảo lãnh Ngân hàng*, Hà Nội. khoản 1 Điều 32

Như vậy pháp luật về cơ bản đều cho phép các bên thực hiện chuyển quyền của mình cho một chủ thể khác nếu có sự thỏa thuận và không trái với quy định của pháp luật.

Theo quyết định 2821/QĐ-HS ngày 07/8/2015 của Ngân hàng quân đội cho phép các bên thực hiện việc chuyển quyền của mình cho một chủ thể khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Đây là một hình thức thuận lợi mà pháp luật tạo điều kiện cho các bên có thể thực hiện việc chuyển nhượng quyền của mình cho một chủ thể khác thụ hưởng về bảo lãnh hoặc thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh.

Mặc dù pháp luật có quy định về việc chuyển nhượng quyền thụ hưởng và Ngân hàng TMCP Quân Đội cũng quy định việc chuyển nhượng. Tuy nhiên trong thực tế triển khai, các bên thường rất ngại khi tiến hành việc chuyển nhượng mặc dù pháp luật cho phép nhưng cách giải quyết lại khác nhau nếu có tranh chấp xảy ra.

Việc chuyển nhượng quyền thụ hưởng của mình cho một chủ thể khác sẽ là cơ hội kinh doanh cho bên nhận bảo lãnh. Trong khi bảo lãnh chưa đến hạn nhưng bên nhận bảo lãnh có nhu cầu vốn nên có thể chuyển nhượng cho một chủ thể khác để nhận trước dòng vốn tạo điều kiện kinh doanh nếu được bên bảo lãnh đồng ý.

Hay việc chuyển nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ của mình cho một chủ thể khác cũng là một ví dụ. Trong trường hợp nghĩa vụ thực hiện của bên được bảo lãnh chuyển nhượng cho một chủ thể khác thay mặt mình thực hiện nghĩa vụ mà bên bảo lãnh đã thực hiện. Trong nghiệp vụ ngân hàng bên nhận nghĩa vụ này thường là bên xác nhận bảo lãnh. Thông thường là một TCTD độc lập hoặc ngân hàng mẹ xác nhận bảo lãnh cho các chi nhánh.

Trong thực tế việc chuyển nhượng này cũng là một hình thức mua bán nợ. Việc chuyển nợ từ mình sang người khác cũng là một hình thức tín dụng tạo điều kiện cho các bên trong kinh doanh. Đối với trường hợp chuyển nhượng nếu bên bảo lãnh xét thấy năng lực cũng như khả năng thực hiện bên nhận chuyển nhượng nghĩa vụ của bên được bảo lãnh tốt hơn thì đồng ý cho bên được bảo lãnh được quyền chuyển nhượng. Điều này sẽ rất tốt cho bên bảo lãnh, vì nếu bên nhận nghĩa vụ chuyển nhượng từ bên được bảo lãnh nếu có khả năng tốt hơn bên được bảo lãnh như vậy bên bảo lãnh sẽ giảm thiểu được rủi ro của mình trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình trước bên nhận bảo lãnh.

Có thể nói việc chuyển quyền và nghĩa vụ của mình cho một chủ thể khác là một hình thức thuận lợi tạo điều kiện cho các chủ thể. Tuy nhiên pháp luật quy định còn khá chung chung chưa cụ thể và rõ ràng trong việc thực hiện. Vì vậy việc áp dụng vào thực tiễn gặp nhiều khó khăn, các bên còn lúng túng trong quá trình triển khai.

2.1.2.4 Quy định pháp luật về bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

So với Thông tư 07/2015/TT-NHNN và Thông tư 13/2017/TT-NHNN thì Thông tư 11/2022/TT-NHNN đã có sự rõ ràng và chi tiết hơn trong việc quy định về các đối tượng lẫn hình thức bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai.

Ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai khi trong giấy phép thành lập và hoạt động hoặc tại văn bản sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng thương mại có quy định nội dung hoạt động bảo lãnh ngân hàng và không bị cấm, hạn chế, đình chỉ, tạm đình chỉ thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai[52].

Ngân hàng thương mại xem xét, quyết định cấp bảo lãnh cho chủ đầu tư khi: Chủ đầu tư đáp ứng đủ các yêu cầu quy định (trừ trường hợp ngân hàng thương mại bảo lãnh cho chủ đầu tư trên cơ sở bảo lãnh đối ứng), dự án đáp ứng đủ các điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo quy định.

Trình tự thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai: Căn cứ đề nghị của chủ đầu tư hoặc bên bảo lãnh đối ứng, ngân hàng thương mại xem xét, thẩm định và quyết định cấp bảo lãnh cho chủ đầu tư. Ngân hàng thương mại và chủ đầu tư ký hợp đồng bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định. Sau khi ký hợp đồng mua, thuê mua nhà ở, trong đó có quy định nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư, chủ đầu tư gửi hợp đồng mua, thuê mua nhà ở cho ngân hàng thương mại để đề nghị ngân hàng thương mại phát hành thư bảo lãnh cho bên mua. Ngân hàng thương mại căn cứ hợp đồng mua, thuê mua nhà ở và hợp đồng bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai để phát hành thư bảo lãnh và gửi cho từng bên mua hoặc gửi chủ đầu tư để cung cấp thư bảo lãnh cho bên mua theo thỏa thuận.

Ngân hàng thương mại có nghĩa vụ phát hành thư bảo lãnh cho bên mua trước thời hạn giao, nhận nhà theo cam kết tại hợp đồng mua, thuê mua nhà ở. Ngân hàng và chủ đầu tư thỏa thuận cụ thể về việc gửi thư bảo lãnh cho bên mua sau khi phát hành thư bảo lãnh.

Hồ sơ bên mua gửi cho ngân hàng yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh phải kèm theo thư bảo lãnh. Thư bảo lãnh có hiệu lực kể từ thời điểm phát hành cho đến ít nhất sau 30 ngày kể từ thời hạn giao, nhận nhà theo cam kết tại hợp đồng mua, thuê mua nhà ở, trừ trường hợp nghĩa vụ bảo lãnh chấm dứt theo quy định.

Trường hợp ngân hàng thương mại và chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai trước thời hạn, các thư bảo lãnh đã phát hành cho các bên mua trước đó vẫn có hiệu lực cho đến khi nghĩa vụ bảo lãnh chấm dứt.

Số tiền bảo lãnh cho một dự án nhà ở hình thành trong tương lai tối đa bằng tổng số tiền chủ đầu tư được phép nhận ứng trước của bên mua theo quy định tại Điều 57

[52] Ngân hàng Nhà nước. (2022). *Thông tư số 11/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 của Ngân hàng Nhà nước quy định về bảo lãnh Ngân hàng*, Hà Nội. Điều 13

Luật Kinh doanh bất động sản và các khoản tiền khác (nếu có) theo hợp đồng mua, thuê mua nhà ở.

Đại diện Ngân hàng TMCP Quân đội, chi nhánh Cần Thơ cho biết, thực tế từ khi quy định bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai được ban hành, không có khách hàng nào mua bảo lãnh, theo phía đại diện ngân hàng cho biết cũng do nhiều nguyên nhân như quy định pháp luật còn bất cập, tâm lý khách hàng còn e dè bởi hiện nay, một số doanh nghiệp lớn có "sân sau" là ngân hàng. Nên nếu ngân hàng công minh thì không sao, nhưng nếu để xảy ra tình trạng lợi ích nhóm trong vấn đề bảo lãnh thì cực kỳ nguy hiểm và người mua nhà phải chịu thiệt.

Mặt khác, trong quá trình triển khai xây dựng, nhiều chủ đầu tư sẽ chia ra 2 giai đoạn (xây dựng phần thô và hoàn thiện) để giảm thiểu tối đa chi phí.

Cụ thể, đối với phần thô, chủ đầu tư được thu về 70% nhưng giá trị đổ vào dự án chỉ rơi vào khoảng 30%. Ngược lại, đối với phần hoàn thiện, chủ đầu tư chỉ được thu về 30% nhưng chi phí lại lên đến khoảng 70%. Điều này dẫn tới kịch bản xấu là chủ đầu tư khi xây thô xong sẽ không sử dụng dòng tiền đúng mục đích, đến khi "gãy" dòng tiền thì không thể triển khai được dự án. Lúc này, xét theo các điều khoản, nếu ngân hàng chỉ bảo lãnh đến giai đoạn xây dựng phần thô thì người mua nhà sẽ rơi vào cảnh như bị lừa vì họ vẫn nghĩ ngân hàng phát hành bảo lãnh đến tận khi bàn giao nhà. Trong khi đó về mặt giấy tờ thủ tục thì chủ đầu tư và ngân hàng cũng không hề sai[53]

Phía đại diện ngân hàng còn cho biết, việc khách hàng mua bảo lãnh xuất phát từ việc họ có tự nguyện mua hay không và nếu mua thì dù có thể giảm thiểu một phần rủi ro khi mua nhà nhưng họ phải tự trả thêm một khoản chi phí. Vì vậy, đến 99% khách hàng gần như không mặn mà với việc này.

2.1.2.5 Bảo lãnh bằng phương thức điện tử

Việc bổ sung phương thức thực hiện hoạt động bảo lãnh tại Thông Tư 11/2022 nhằm đảm bảo tương thích và phù hợp với Luật Giao dịch điện tử năm 2005, 2023, Bộ Luật dân sự 2015, Điều 97 Luật các Tổ chức tín dụng 2010, Điều 105 Luật các Tổ chức tín dụng 2024, Khoản 3 Điều 3 Nghị định 35/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007 về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng, Nghị định 130/2018/NĐ-CP ngày 27/09/2018 quy định chi tiết Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Đồng thời, tạo sự đa dạng, linh động cho các tổ chức tín dụng áp dụng trên thực tế, phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ hiện nay. Tại Ấn Độ đã và đang có khá nhiều ngân hàng cung ứng sản phẩm bảo lãnh ngân hàng điện tử, có thể kể đến như: Axis Bank, là Ngân hàng lớn thứ ba tại Ấn Độ với 4.759 chi nhánh trong nước[54].

---

[53] Nguyễn Hồng Nhung.(2022). *Một số vấn đề pháp lý về bảo lãnh ngân hàng trong mua, bán nhà ở hình thành trong tương lai và giải pháp hoàn thiện.* tr. 3. Truy cập ngày 20/11/2023 https://lsvn.vn/mot-so-van-de-phap-ly-ve-mua-ban-nha-o-hinh-thanh-trong-tuong-lai1657031860.html.

[54] Crmnext. (2022). *Axis Bank cùng đối tác CRMNEXT giành giải thưởng triển khai CRM tốt nhất từ Asian Banker Cision*, truy cập ngày 18/3/2024, tại. https://vn.prnasia.com/story/79482-11.shtml.

Bảo lãnh ngân hàng điện tử mang lại sự an toàn cao hơn vì tính xác thực của chữ kí điện tử, có thể được kiểm tra nếu tích hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan hoặc chức năng tra cứu trên ứng dụng ngân hàng điện tử. Thay vì ở phương thức phát hành truyền thống, khi một cam kết bảo lãnh được giao đến bên nhận bảo lãnh thường sẽ kèm theo chứng từ chứng minh người kí kết trên cam kết ấy có đủ thẩm quyền (chẳng hạn quyết định bổ nhiệm, giấy ủy quyền…) thì với bảo lãnh điện tử, ngân hàng có thể tích hợp công bố danh sách đại diện ngân hàng được ủy quyền kí bảo lãnh điện tử trên trang web hay ứng dụng ngân hàng điện tử của ngân hàng. Khi đó, để xác nhận xem những người kí bảo lãnh điện tử có phải là người được ủy quyền hay không và chứng chỉ của họ có hợp lệ hay không, bất kì ai cũng có thể nhanh chóng tìm thấy thông tin.

Tuy đã có quy định về bảo lãnh điện tử theo Thông tư số 11/2022/TT-NHNN (có hiệu lực triển khai từ ngày 01/4/2023), Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 nhưng việc áp dụng phương thức này vào thực tế tại các Ngân hàng TMCP Quân đội nói chung và tại MBCT nói riêng còn hạn chế do những vướng mắc, bất cập như:

Thứ nhất, quy định cho phép ngân hàng và khách hàng được lựa chọn thực hiện hoạt động bảo lãnh ngân hàng qua việc "sử dụng các phương tiện điện tử" (gọi chung là "hoạt động bảo lãnh điện tử"), tuy nhiên, quy định này chưa thực sự rõ ràng về cách xác định hoạt động bảo lãnh điện tử. Với quy định này có thể hiểu rằng, hoạt động bảo lãnh điện tử chỉ đơn thuần là tạo lập quy trình phát hành, giao nhận bảo lãnh ngân hàng bằng phương tiện điện tử (email, ứng dụng ngân hàng điện tử, SWIFT...), hay phải là bảo lãnh ngân hàng mà chữ kí của người đại diện có thẩm quyền thể hiện trên cam kết bảo lãnh phải là chữ kí điện tử, hay phải hiểu đồng thời cả hai hướng như trên mới được xem là bảo lãnh ngân hàng điện tử hợp pháp.

Thứ hai, việc xác định các nguyên tắc thiết lập và thực hiện việc bảo lãnh giữa ngân hàng và các chủ thể khác. Bản chất của nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng là giao dịch thương mại nên pháp luật quy định nguyên tắc: Ngân hàng bảo lãnh và các chủ thể liên quan phải xác lập và thực hiện giao dịch bảo lãnh thông qua việc kí kết và thực hiện các hợp đồng. Cụ thể, ngân hàng bảo lãnh phải kí hợp đồng dịch vụ bảo lãnh/hợp đồng cấp bảo lãnh với khách hàng được bảo lãnh. Trong hợp đồng phải xác định TCTD là bên cung cấp việc bảo lãnh, còn khách hàng thường là bên được bảo lãnh. TCTD phải cam kết bảo lãnh nếu chủ thể được bảo lãnh thực hiện được nghĩa vụ. Về hình thức, giao dịch bảo lãnh có thể được xác lập qua các phương tiện điện tử bằng chữ kí số, chứng từ số... Việc cần quy định rõ nội dung bảo lãnh trong các chứng thư số giữa TCTD và các bên là cần thiết, góp phần giảm rủi ro và tranh chấp.

Thứ ba, giới hạn hạn mức đối với hình thức bảo lãnh điện tử. Hiện nay theo quy định tại Thông tư số 11/2022/TT-NHNN giá trị của mỗi cam kết bảo lãnh phát hành cho khách hàng cá nhân không được vượt quá 4 tỉ đồng và cho khách hàng tổ chức không được vượt quá 45 tỉ đồng nếu không thuộc các trường hợp quy định tại điểm a, b, c, d, e khoản 4 Điều 9 Thông tư số 11/2022/TT-NHNN. Việc quy định về hạn mức của hoạt động bảo lãnh sẽ làm hạn chế công dụng của biện pháp bảo đảm này.

2.2. Định hướng hoàn thiện pháp luật về bảo lãnh của ngân hàng từ thực tiễn Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội, Chi nhánh Cần Thơ

Thứ nhất, hoàn thiện pháp luật về bảo lãnh của ngân hàng từ thực tiễn Ngân hàng TMCP Quân Đội, Chi nhánh Cần Thơ phải trên cơ sở quán triệt quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tổ chức và hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Tại Tại Đề án phát triển ngành ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020 ban hành theo Quyết định số 112/2006/QĐ-TTg ngày 24/5/2006, Đề án phát triển thanh toán ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2021-2025 ban hành theo Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 về phê duyệt Đề án phát triển thanh toán ngân hàng của Thủ tướng Chính phủ đã định hướng phát triển hệ thống ngành ngân hàng. Theo đó ngành ngân hàng cần phải cải cách căn bản, triệt để và phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, hoạt động đa năng để đạt trình độ phát triển trung bình tiên tiến trong khu vực ASEAN với cấu trúc đa dạng về sở hữu, tài chính lành mạnh, hoạt động an toàn và hiệu quả vững chắc dựa trên cơ sở công nghệ và trình độ quản lý tiên tiến, áp dụng thông lệ, chuẩn mực quốc tế về hoạt động ngân hàng thương mại. Hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế, chính sách. Nâng cấp, phát triển hạ tầng thanh toán hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả và có khả năng kết nối, tích hợp với các hệ thống khác. Nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia, hướng tới vận hành theo các nguyên tắc, tiêu chuẩn quốc tế, tăng cường quốc tế, tăng cường khả năng kết nối, tích hợp và thực hiện thanh, quyết toán cho các hệ thống khác; hoàn thiện, phát triển hạ tầng chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử, mở rộng hệ sinh thái thanh toán số, đảm bảo khả năng kết nối, tích hợp với các ngành, lĩnh vực khác để phục vụ thanh toán trực tuyến; mở rộng, kết nối với hệ thống chuyển mạch tài chính, bù trừ điện tử của các quốc gia khác…

Thứ hai, hoàn thiện pháp luật về bảo lãnh của ngân hàng từ thực tiễn Ngân hàng TMCP Quân Đội, Chi nhánh Cần Thơ phải trên cơ sở kế thừa, bổ sung, thống nhất và phù hợp với những quy định hiện hành và pháp luật khác có liên quan. Pháp luật phải đảm bảo tính toàn diện, đáp ứng được đầy đủ nhu cầu điều chỉnh pháp luật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội để các quan hệ xã hội mang tính điển hình phổ biến cần sự điều chỉnh của pháp luật thì đều có pháp luật điều chỉnh. Pháp luật về hoạt động BLNH phải đảm bảo sự thống nhất với Hiến pháp, BLDS, Luật các TCTD, Pháp lệnh ngoại hối và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Ngoài ra việc hoàn thiện pháp luật về hoạt động

BLNH phải đảm bảo phù hợp với thực tiễn xã hội, phù hợp với phong tục, tập quán và phản ánh đúng tiến độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thứ ba, hoàn thiện pháp luật về bảo lãnh ngân hàng từ thực tiễn Ngân hàng TMCP Quân Đội, Chi nhánh Cần Thơ phải tôn trọng nguyên tắc tự do ý chí của các bên tham gia. Mục đích cuối cùng của quá trình hoàn thiện pháp luật là để đưa pháp luật vào cuộc sống, phát huy vai trò điều chỉnh của pháp luật đối với quan hệ xã hội. Có thể nói, pháp luật không thể tự thân nó tác động vào các quan hệ xã hội, tạo ra trật tự xã hội theo ý chí của Nhà nước mà phải có một cơ chế áp dụng phù hợp. Những quy định của pháp luật cần bảo đảm sự cân bằng giữa sự phát triển kinh tế với việc đảm bảo các lợi ích khác trong xã hội. Mục tiêu quan trọng của pháp luật bảo lãnh là bảo đảm quyền và lợi ích của tất cả các bên tham gia giao dịch dựa trên tinh thần tự do, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Thứ tư, hoàn thiện pháp luật về bảo lãnh ngân hàng từ thực tiễn Ngân hàng TMCP Quân Đội, Chi nhánh Cần Thơ phải phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế về kinh tế nói chung và hoạt động của các tổ chức tín dụng nói riêng. Việc hoàn thiện pháp luật về hoạt động BLNH phải đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế nhằm tạo khuôn khổ pháp lý hữu ích để thúc đẩy sự phát triển của hoạt động BLNH, đảm bảo hoạt động BNH phát triển an toàn, hiệu quả và cạnh tranh được với các TCTD nước ngoài.

Trên cơ sở những quy định của pháp luật hiện hành về BLNH và những vấn đề được trình bày trong luận văn, tác giả rút ra được một số hạn chế liên quan đến thực tiễn áp dụng pháp luật, cũng như những bất cập, hạn chế của pháp luật về BLNH ở nước ta hiện nay. Từ đó đưa ra những đề xuất, giải pháp hoàn thiện pháp luật, đảm bảo tính hiệu quả của hoạt động áp dụng pháp luật về BLNH trong thực tiễn.

Tóm lại, pháp luật được hình thành do nhu cầu điều chỉnh các quan hệ xã hội. Việc hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo lãnh phải đảm bảo tính thích ứng với điều kiện kinh tế, xã hội của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

2.3. Các giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật và thực thi pháp luật về bảo lãnh của ngân hàng từ thực tiễn Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội, Chi nhánh Cần Thơ

2.3.1. Các giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về bảo lãnh của ngân hàng từ thực tiễn Ngân hàng TMCP Quân Đội, Chi nhánh Cần Thơ

Từ một số thực tiễn trong hoạt động áp dụng pháp luật bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội, Chi nhánh Cần Thơ đã nêu ở chương 1 của luận văn, có thể thấy nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc hạn chế hiệu quả áp dụng pháp luật trong bảo lãnh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội, Chi nhánh Cần Thơ đó là một số quy định pháp luật về bảo lãnh chưa phù hợp với thực tiễn hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội, Chi nhánh Cần Thơ, còn tồn tại nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, chưa tạo ra khung pháp lý rõ ràng, đầy đủ để thực thi, dẫn đến khó khăn cho Ngân hàng

thương mại cổ phần Quân đội, Chi nhánh Cần Thơ trong quá trình tuân thủ và thực thi pháp luật, các tranh chấp liên quan đến bảo lãnh phát sinh còn nhiều trong khi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa có cơ chế giải quyết triệt để, cụ thể như:

- *Phạm vi bảo lãnh:* Trường hợp bên được bảo lãnh chỉ vi phạm một phần trong toàn bộ nghĩa vụ bảo lãnh thì bên bảo lãnh thực hiện một phần hay toàn bộ nghĩa vụ của mình cho bên nhận bảo lãnh? Do đó cần quy định rõ hơn về phạm vi bảo lãnh đối với các trường hợp mà bên được bảo lãnh đã thực hiện một phần nghĩa vụ của mình.

- *Bảo lãnh vô điều kiện:* Hiện nay trên thế giới hình thức bảo lãnh vô điều kiện rất phát triển và được áp dụng rộng rãi trong hoạt động thương mại quốc tế vì những ưu điểm của hình thức này là thủ tục thanh toán tiền bảo lãnh đơn giản, nhanh gọn, chỉ khi bên nhận bảo lãnh có văn bản yêu cầu thanh toán trong phạm vi số tiền cam kết bảo lãnh thì ngân hàng phát hành sẽ thực hiện nghĩa vụ trả tiền bảo lãnh ngay mà không cần xem xét đến việc thực hiện nghĩa vụ gốc giữa hai bên. Pháp luật Việt Nam hiện hành chưa có văn bản nào quy định cụ thể nào về vấn đề này.

- *Quyền thụ hưởng bảo lãnh:* Pháp luật quy định còn khá chung chung chưa cụ thể và rõ ràng trong việc thực hiện. Vì vậy việc áp dụng vào thực tiễn gặp nhiều khó khăn, các bên còn lúng túng trong quá trình triển khai.

- *Bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai:* Bản chất quy định bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai cũng giống như việc khách hàng mua bảo hiểm nên phải có chi phí nên giá bán nhà sẽ cao hơn, chi phí này người mua nhà phải gánh chịu. Chủ đầu tư phải trả "phí bảo lãnh ngân hàng" thường bằng khoảng 2% tổng giá trị tài sản bảo lãnh là dự án nhà ở thương mại có giá trị rất lớn nên "phí bảo lãnh" cũng rất cao. Đồng thời, "Phí bảo lãnh ngân hàng" được chủ đầu tư trả trước cho ngân hàng nhưng được chủ đầu tư tính vào giá thành làm tăng giá bán nhà ở mà cuối cùng thì người mua nhà phải gánh chịu "phí bảo lãnh ngân hàng" này, bằng khoảng 2% giá bán nhà. Do đó, người dân cũng ít quan tâm và tham gia loại hình bảo lĩnh này.

- *Bảo lãnh bằng phương thức điện tử:* Pháp luật chưa quy định thực sự rõ ràng về cách xác định hoạt động bảo lãnh điện tử, chưa quy định rõ nội dung bảo lãnh trong các chứng thư số giữa TCTD và các bên tham gia, việc quy định về hạn mức của hoạt động bảo lãnh điện tử sẽ làm hạn chế công dụng của biện pháp bảo đảm này.

Từ những thực trạng và phân tích nguyên nhân nêu trên, tác giả xin đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về bảo lãnh của ngân hàng, cụ thể như sau:

2.3.1.1 Về phạm vi bảo lãnh

Theo quy định của pháp luật về bảo lãnh thì phạm vi bảo lãnh được hiểu là giới hạn của việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo thỏa thuận mà bên bảo lãnh cam kết sẽ thực hiện thay cho bên được bảo lãnh đối với bên nhận bảo lãnh, phạm vi bảo lãnh phải do các bên thỏa thuận thống nhất với nhau. Từ vụ việc tranh chấp về nghĩa vụ bảo lãnh ở chương 1 có thể thấy việc xác định phạm vi bảo lãnh là rất quan trọng đối với các bên

trong hợp đồng bảo lãnh, vì nó liên quan đến trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của các bên. Bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ của mình theo yêu cầu của bên nhận bảo lãnh đối với bảo lãnh vô điều kiện. Theo đó bên bảo lãnh phải thanh toàn vô điều kiện khi nhận được yêu cầu đòi tiền từ bên nhận bảo lãnh. Tuy nhiên trong trường hợp này bên được bảo lãnh chỉ vi phạm một phần trong toàn bộ nghĩa vụ bảo lãnh. Để xác định một cách chính xác về quyền và nghĩa vụ của bên bảo lãnh, bên được bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh trong hợp đồng, để phòng tránh các tranh chấp tương tự xảy ra trên thực tế, pháp luật cần quy định cụ thể hơn về phạm vi bảo lãnh đối với các trường hợp mà bên được bảo lãnh đã thực hiện một phần nghĩa vụ của mình thì bên bảo lãnh, bên được bảo lãnh được loại trừ trách nhiệm đối với phần nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh đã thực hiện.

2.3.1.2 Vấn đề bảo lãnh vô điều kiện và tính độc lập của bảo lãnh

Bảo lãnh theo yêu cầu hay còn gọi là bảo lãnh vô điều kiện là một dạng bảo lãnh tiên tiến, thể hiện triệt để tính độc lập và thanh toán theo chứng từ của bảo lãnh. Do sự ưu việt và tiện dụng nên bảo lãnh theo yêu cầu ngày càng được các doanh nghiệp ưa chuộng. Tuy nhiên hiện nay các quy định của pháp luật về bảo lãnh vô điều kiện tại Việt Nam còn chưa rõ ràng, quan điểm của các cơ quan áp dụng pháp luật như Tòa án vẫn còn cứng nhắc và không xác định được rõ tính độc lập của bảo lãnh ngân hàng khi yêu cầu bên nhận bảo lãnh phải xuất trình các tài liệu chứng minh bên được bảo lãnh chưa thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh để xác định sự kiện phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh của ngân hàng. Như vậy, theo quan điểm của một số Tòa án Việt Nam hiện nay, bảo lãnh ngân hàng chỉ là nghĩa vụ phái sinh từ giao dịch gốc, khi bên được bảo lãnh không tự thực hiện được nghĩa vụ của mình thì bên nhận bảo lãnh mới có quyền yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện thay theo cam kết bảo lãnh. Việc thực hiện theo quy định này đang dẫn đến hạn chế cho các ngân hàng cũng như Tòa án trong quá trình áp dụng pháp luật, đó là:

- Bên nhận bảo lãnh sẽ rất khó khăn trong việc yêu cầu ngân hàng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

- Quyền lợi cũng như uy tín của ngân hàng với tư cách là ngân hàng bảo lãnh có thể bị ảnh hưởng do bảo lãnh phát hành trở nên kém an toàn và không bảo vệ được quyền lợi của bên nhận bảo lãnh.

- Ngân hàng tự ràng buộc thêm trách nhiệm của mình, đó là phải xem xét tính đúng đắn của các tài liệu do bên thụ hưởng cung cấp và chứng minh lỗi của bên được bảo lãnh. Việc này sẽ dẫn đến việc ngân hàng liên đới chịu trách nhiệm nếu có tranh chấp xảy ra hoặc khó khăn khi thực hiện nghĩa vụ của mình.

Do đó, để thúc đẩy sự phát triển của hoạt động bảo lãnh, tạo niềm tin cho khách hàng khi sử dụng hình thức này và tạo khung pháp lý rõ ràng hơn cho các chủ thể trong hoạt động áp dụng pháp luật, tác giả đề xuất các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây

dựng quy chế riêng về bảo lãnh vô điều kiện (bảo lãnh theo yêu cầu), đảm bảo phù hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế.

Theo đó bảo lãnh vô điều kiện là trong trường hợp khi bên nhận bão lãnh xuất trình cho bên bảo lãnh cam kết bảo lãnh thì trong vòng tối đa 5 ngày bên bảo lãnh phải có nghĩa vụ thanh toán mà không yêu cầu hay đòi hỏi thêm bất kỳ một điều kiện gì từ phía bên nhận bảo lãnh. Ngoài bảo lãnh vô điều kiện cần ràng buộc thêm tính đảm bảo là không hủy ngang trong mọi trường hợp.

Đây cũng là xu hướng chung phù hợp với thông lệ quốc tế khi mà Việt Nam ngày càng gia nhập cũng như là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế.

2.3.1.3 Về trình tự, thủ tục bảo lãnh

Theo quy chế BLNH hiện hành, pháp luật cho phép các TCTD tự ban hành các quy trình, quy chế thực hiện nghiệp vụ BLNH, trên cơ sở không trái quy định của pháp luật. Thực tế, các TCTD cũng đã ban hành các tài liệu, sổ tay, quy trình hướng dẫn cấp tín dụng nói chung, thực hiện nghiệp vụ BLNH nói riêng.

Nhìn chung, các nội dung cần thiết và cơ bản trong quá trình thực hiện BLNH vẫn được các TCTD bảo lãnh tuân thủ, nhưng cũng có một vài sự khác nhau nhất định về các điều kiện bảo lãnh cũng như trình tự, thủ tục thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh giữa các TCTD bảo lãnh, hoặc giữa các quan hệ bảo lãnh do cùng một TCTD thực hiện bảo lãnh.

Chính sự khác nhau này dẫn đến tình trạng các tài liệu, chứng từ kèm theo hồ sơ bảo lãnh cũng không giống nhau. Có trường hợp TCTD bảo lãnh thực hiện việc đơn giản hóa các tài liệu kèm theo hồ sơ bảo lãnh, hoặc thẩm định khách hàng không chặt chẽ, hoặc cũng có trường hợp TCTD phát hành cam kết bảo lãnh trước khi hoàn tất thủ tục tiếp nhận tài sản đảm bảo,....nhằm đơn giản hóa thủ tục bảo lãnh và tăng tính cạnh tranh giữa các TCTD bảo lãnh với nhau.

Chính những điều này đã dẫn đến tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động cấp tín dụng nói chung và hoạt động bảo lãnh nói riêng giữa các TCTD. Những TCTD thực hiện thủ tục bảo lãnh không chặt chẽ có nhiều cơ hội trong việc thu hút khách hàng, nhưng cũng có nhiều khả năng gặp rủi ro trong quá trình bảo lãnh do gặp phải khách hàng "xấu".

Để hạn chế rủi ro trong hoạt động BLNH của các TCTD nói riêng, đối với sự phát triển của nền kinh tế nói chung, pháp luật về BLNH cần phải ban hành một cách chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện BLNH và buộc các TCTD phải nghiêm túc thực hiện. Đồng thời, pháp luật về cạnh tranh nên tăng mức phạt và bổ sung các hình thức xử lý cần thiết đối với những hành vi cạnh tranh không lành mạnh để tăng tính răn đe. Có như vậy, mới có thể đảm bảo hoạt động BLNH được thực hiện đúng pháp luật và mang lại hiệu quả cao nhất trong thực tiễn áp dụng.

Về thủ tục bảo lãnh mặc dù Thông tư 11/2022/TT-NHNN đã nêu chi tiết một số quy định về thủ tục. Tuy nhiên chưa cụ thể, trong một số trường hợp một số khách hàng mới thành lập thì thủ tục không thể đảm bảo, hoặc một số khách hàng muốn trục lợi có thể làm giả hồ sơ để yêu cầu bảo lãnh.

Về quy định này cần chi tiết và cụ thể hơn. Theo đó khách hàng cần phải đáp ứng tối thiểu về hồ sơ như có kiểm toán, hoặc phải có thâm niên trong nghành nghề hoạt động.

2.3.1.4 Về ủy quyền thụ hưởng bảo lãnh

Theo quy định tại Thông tư 11/2022/TT-NHNN cho phép các chủ thể được phép chuyển quyền thụ hưởng hoặc chuyển nghĩa vụ của mình cho một chủ thể khác.

Việc ủy quyền thụ hưởng là hoàn toàn hợp lý và logic theo quy định về ủy quyền của Bộ luật Dân sự 2015 và theo Thông tư 11/2022/TT-NHNN cũng cho phép việc chuyển quyền thụ hưởng bảo lãnh.

Do đó, thiết nghĩ pháp luật về bảo lãnh ngân hàng nên đưa ra trường hợp chuyển quyền thụ hưởng bảo lãnh một cách cụ thể hơn để các bên lưu ý và hiểu đúng trong quá trình thực hiện.

Ngoài ra như đã phân tích tại chương 1, việc chuyển quyền thụ hưởng bảo lãnh hoặc nghĩa vụ có thể sẽ làm tăng thêm tính chắc chắn trong việc thực hiện các cam kết và nghĩa vụ của mình. Vì vậy pháp luật cần quy định rõ hơn trong trường hợp chuyển quyền thụ hưởng cũng như nghĩa vụ thực hiện bảo lãnh. Theo đó bên nhận bảo lãnh có quyền chuyển quyền thụ hưởng bảo lãnh cho một chủ thể khác và chỉ cần gởi một thông báo cho bên bảo lãnh và bên được bảo lãnh có thể chuyển nghĩa vụ thực hiện của mình cho một chủ thể khác nếu có sự chấp thuận của bên bảo lãnh.

Trong thực tế hiện nay đối với bên bảo lãnh việc chuyển quyền ít xảy ra nhưng đây là chủ thể đặc biệt trong hoạt động bảo lãnh ngân hàng nên khi quyền hay nghĩa vụ được chuyển thì tính pháp lý vẫn được thực hiện. Đối với bên nhận bảo lãnh là người có quyền đối với cam kết bảo lãnh. Việc chuyển quyền thụ hưởng bảo lãnh sẽ tạo ra tính linh hoạt hơn trong nghiệp vụ bảo lãnh. Theo đó bên nhận bảo lãnh có thể chuyển quyền thụ hưởng bảo lãnh của mình cho một chủ thể khác để nhận lấy một tài sản. Khi bên nhận quyền có được thư bảo lãnh như là một hình thức thanh toán của bên nhận bảo lãnh sẽ yên tâm hơn khi chuyển giao tài sản cho bên nhận bảo lãnh khác. Tạo ra tính linh hoạt trong hoạt động kinh doanh.

Pháp luật nên xây dựng theo khuynh hướng bảo lãnh có thể chuyển nhượng được như công cụ thư tín dụng dự phòng trong hoạt động thanh toán quốc tế. Như vậy pháp luật sẽ tạo cơ chế thông thoáng hơn cho các chủ thể khi tham gia pháp luật về bảo lãnh, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế.

Để tạo cơ chế thông thoáng về ủy quyền thụ hưởng và chuyển nhượng bảo lãnh, pháp luật có thể quy định chặt chẽ hơn trong hoạt động cấp bảo lãnh nhưng lại tạo ra

một cơ chế thông thoáng trong hoạt động chuyển nhượng quyền thụ hưởng bảo lãnh. Để chuyển nhượng quyền thụ hưởng bảo lãnh, pháp luật cần quy định "đây là bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang và có giá trị pháp lý trong thời gian có hiệu lực đối với bất kỳ người nào đang sở hữu nó". Việc chuyển nhượng chỉ cần thông báo cho bên bảo lãnh được biết.

2.3.1.5 Quy định pháp luật về bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

Thông tư 11/2022/TT-NHNN quy định về bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai, nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người mua nhà trước những dự án "ảo". Tuy nhiên, như đã phân tích ở chương 1, quy định này còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Để nâng cao tính khả thi và hiệu quả áp dụng trên thực tế đối với loại hình bảo lãnh này, cho thấy để hoàn thiện khung pháp lý nhằm khắc phục các bất cập trong hoạt động bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai cần thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, quy định bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai hầu như chỉ "làm lợi" cho ngân hàng thương mại. Bởi hầu hết ngân hàng thương mại thực hiện "bảo lãnh" cũng chính là ngân hàng đã cho chủ đầu tư vay tín dụng để đầu tư xây dựng, phát triển dự án đó và đã nhận thế chấp chính dự án đó để bảo đảm khoản vay…Nếu ngân hàng minh bạch thì không sao, nếu tình trạng thông đồng, bắt tay nhau với chủ đầu tư trong vấn đề bảo lãnh thì người mua nhà phải chịu thiệt thòi. Do đó, để khắc phục tình trạng này thì việc bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai nên có thêm sự tham gia của một số cơ quan độc lập (các công ty bảo hiểm, đơn vị quản lý Nhà nước hay một số quỹ bất động sản) nhằm chứng kiến, giám sát việc bảo lãnh.

Thứ hai, không nên tách phát hành bảo lãnh ra từng giai đoạn khác nhau của dự án mà nên phát hành đến khi dự án đủ điều kiện bàn giao để tránh gây hiểu lầm cho khách hàng. Cần siết chặt thêm các quy định trách nhiệm của ngân hàng và chủ đầu tư để các bên phải thực hiện đúng nghĩa vụ bảo lãnh. Ngoài ra, cần có chế tài đối với chủ đầu tư chậm tiến độ, chậm bàn giao nhà hoặc quy định phải có trách nhiệm bồi thường các khoản tiền thuê nhà trong thời gian chậm bàn giao và bồi thường thiệt hại khác (nếu có). Bên cạnh đó, cần kéo dài thời gian bảo lãnh đến khi bàn giao nhà và giấy chứng nhận quyền sử dụng cho người dân.

Thứ ba, bản chất quy định bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai cũng giống như việc khách hàng mua bảo hiểm nên phải có chi phí nên giá bán nhà sẽ cao hơn. Quy định bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai làm tăng giá thành, làm tăng giá bán nhà ở mà người mua nhà phải gánh chịu khi mua nhà. Chủ đầu tư phải trả "phí bảo lãnh ngân hàng" thường bằng khoảng 2% tổng giá trị tài sản bảo lãnh là dự án nhà ở thương mại có giá trị rất lớn nên "phí bảo lãnh" cũng rất cao. Đồng thời, "Phí bảo lãnh ngân hàng" được chủ đầu tư trả trước cho ngân hàng nhưng được chủ đầu tư tính vào giá thành làm tăng giá bán nhà ở mà cuối cùng thì người mua nhà phải gánh chịu "phí bảo lãnh ngân hàng" này, bằng khoảng 2% giá bán nhà". Do đó, các

cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần có sự quan tâm, nỗ lực tìm kiếm các giải pháp để kéo giảm giá nhà ở, đảm bảo có lợi cho người dân.

2.3.1.6 Bảo lãnh bằng phương thức điện tử

Pháp luật về bảo lãnh ngân hàng điện tử tại Việt Nam hiện nay đang ở giai đoạn đầu hình thành và triển khai. Nắm bắt được tầm quan trọng của chuyển đổi số và lợi ích mà bảo lãnh ngân hàng điện tử mang lại, để việc áp dụng hoạt động này trong thời gian tới được rộng rãi và ưu việt hơn cần tiếp tục nghiên cứu thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, xem xét bổ sung quy định về khái niệm hoặc giải thích từ ngữ "bảo lãnh ngân hàng điện tử", các hình thức cam kết bảo lãnh kèm theo như thư bảo lãnh điện tử, hợp đồng bảo lãnh điện tử để các ngân hàng có cơ sở xây dựng quy trình về một sản phẩm mới cải tiến.

Thứ hai, việc phát hành bảo lãnh ngân hàng điện tử là một phần quan trọng nhưng chưa phải là toàn bộ hoạt động bảo lãnh điện tử. Bất kì nội dung tiếp theo nào của bảo lãnh ngân hàng điện tử như: Sửa đổi, yêu cầu, hủy/đóng... cũng cần được bổ sung hướng dẫn, quy định cụ thể về cách thức sử dụng các phương tiện điện tử sao cho đồng bộ, nhất quán trong việc triển khai hoạt động này.

Thứ ba, quy định về cách thức tra cứu, xác thực bảo lãnh ngân hàng điện tử cụ thể là chữ kí điện tử, tránh tình trạng các tội phạm công nghệ thực hiện giả mạo, tẩy xóa bảo lãnh ngân hàng điện tử một cách tinh vi, khó đối chiếu được. Cam kết bảo lãnh điện tử và chữ kí điện tử cần được tra cứu nhanh chóng qua website, cho kết quả tức thời để khách hàng và cơ quan có liên quan như hải quan, cục thuế, bên mời thầu trên hệ thống đấu thầu điện tử của Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia tra cứu nhanh chóng khi cần đối chiếu. Vì vậy, cần xem xét quy định hướng dẫn các cơ quan này thực hiện liên kết và đồng bộ dữ liệu với các ngân hàng để rút gọn thời gian tiếp nhận, đối chiếu, xử lí hồ sơ chứng từ liên quan đến sử dụng bảo lãnh ngân hàng.

Thứ tư, ban hành hướng dẫn bổ sung điều kiện cụ thể hơn trong "trường hợp thực hiện nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng qua phương tiện điện tử khi khách hàng lần đầu thiết lập mối quan hệ với TCTD theo khoản 3 Điều 9 Thông tư 11/2022/TT-NHNN. Vì trên thực tế, khi khách hàng thiết lập quan hệ tín dụng lần đầu với ngân hàng, quá trình cấp bảo lãnh sẽ rất mất thời gian vì ngân hàng sẽ thẩm định kĩ khách hàng tương tự như việc vay vốn vì bảo lãnh cũng là một hình thức cấp tín dụng. Các điều kiện kèm theo ngoài điểm a, b khoản 3 này, cần bổ sung thêm chẳng hạn như yêu cầu có cầm cố hợp đồng tiền gửi, kí quỹ... mức tỉ lệ tối thiểu hoặc 100% giá trị cam kết bảo lãnh để bỏ qua các điều kiện cần nhiều thời gian thẩm định khác, từ đó, tiết giảm thời gian xử lí hồ sơ phát sinh lần đầu cũng như bảo đảm rủi ro cho ngân hàng khi cung ứng hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng mới.

Bên cạnh các quy định của pháp luật, nội bộ các TCTD cũng cần nâng cao công nghệ, hệ thống quản lí dữ liệu của mình. Trường hợp tiếp nhận hồ sơ phát hành qua email hay ứng dụng ngân hàng điện tử cũng cần bố trí đường truyền tách biệt với các

luồng giao dịch khác, chẳng hạn như chuyển tiền, chi lương... và nối dẫn trực tiếp đến nhân viên nghiệp vụ để xử lí hồ sơ. Kết hợp những giải pháp trên cùng với quy định nội bộ của ngân hàng sẽ giúp hoạt động bảo lãnh điện tử được triển khai, ứng dụng rộng rãi.

2.3.2. Các giải pháp bảo đảm thực thi pháp luật về bảo lãnh của ngân hàng từ thực tiễn Ngân hàng TMCP Quân Đội, Chi nhánh Cần Thơ

Bất kỳ một nghiệp vụ nào trong hoạt động kinh doanh của một Ngân hàng thương mại thì đều chịu ảnh hưởng của yếu tố môi trường kinh tế –xã hội. Bảo lãnh cũng là một trong những hoạt động chịu ảnh hưởng lớn của yếu tố môi trường kinh tế –xã hội. Ta có thể xem xét sự tác động của của môi trường kinh tế- xã hội từ các yếu tố sau: môi trường kinh tế, môi trường pháp lý, môi trường chính trị xã hội, nhân tố chủ quan và khách quan

- Môi trường kinh tế.

Nếu môi trường kinh tế mà có lành mạnh thì các ngân hàng và các doanh nghiệp mới có điều kiện để phát triển. Ngân hàng mới thực hiện tốt chức năng của mình, còn các doanh nghiệp mới yên tâm kinh doanh và ký kết hợp đồng, thực hiện đúng các cam kết của mình trong hợp đồng.

Còn nếu môi trường kinh tế mà có những thay đổi bất ngờ: như sự thay đổi trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô như: thay đổi chương trình đầu tư, chính sách xuất nhập khẩu, phương thức quản lý tỷ giá, lãi suất…. làm ảnh hưởng tới người yêu cầu bảo lãnh, dẫn đến người yêu cầu bảo lãnh không thực hiện được nghĩa vụ cam kết của mình với người thụ hưởng bảo lãnh và với ngân hàng bảo lãnh.

- Môi trường pháp lý

Môi trường pháp lý đồng bộ, chặt chẽ sẽ đảm bảo an toàn cho hoạt động của hệ thống ngân hàng cũng như của các doanh nghiệp. Môi trường pháp lý không đồng bộ , thiếu chặt chẽ và hay thay đổi cũng là tác nhân quan trọng gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dẫn đến khả năng doanh nghiệp không thực hiện được các nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng bảo lãnh.

Các hoạt động pháp lý như : cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, sở hữu nhà cửa , thủ tục công chứng cũng tác động đến hoạt động bảo lãnh của ngân hàng.

- Môi trường chính trị – xã hội

Một đất nước mà có môi trường chính trị – xã hội ổn định thì luôn tạo điều kiện để đẩy mạnh phát triển. Trong hoạt động bảo lãnh đặc biệt là những hợp đồng bảo lãnh liên quan đến yếu tố nước ngoài thì sự ổn định trong môi trường kinh tế – xã hội lại càng trở nên quan trọng hơn.

- Nhân tố chủ quan

+ Chính sách tín dụng: Đây là một yếu tố quan trọng nó quyết định một phần rất lớn tới hoạt động ngân hàng. Chính sách tín dụng của ngân hàng thể hiện qua như hạn mức bảo lãnh, mức phí bảo lãnh, đối tượng khách hàng, phạm vi bảo lãnh … Ngân hàng có thể thực hiện chính sách tín dụng thắt chặt hay mở rộng.

+ Chất lượng công tác thẩm định

Công tác thẩm định dự án bảo lãnh là một quá trình dài. Nó xem xét tính khả thi của dự án để trên cơ sở đó để đi đến quyết định xem là có thực hiện bảo lãnh hay không. Chất lượng công tác thẩm định phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: thời gian, chi phí, cán bộ, phương tiện kỹ thuật…Nếu chất lượng công tác thẩm định tốt thì hoạt động bảo lãnh sẽ đạt kết quả cao và ngược lại.

+ Chất lượng đội ngũ cán bộ

Đội ngũ cán bộ của ngân hàng là những người trực tiếp tiếp nhận và xử lý yêu cầu bảo lãnh. Vì vậy nó đóng một vai trò rất quan trọng đối với chất lượng bảo lãnh .

- *Các nhân tố khách quan*

+ Người yêu cầu bảo lãnh

Các nhân tố thuộc về tình hình tài chính, khả năng quản lý doanh nghiệp, năng lực của người yêu cầu bảo lãnh trong việc thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng cơ sở ký kết với người thụ hưởng bảo lãnh có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng bảo lãnh.

Nếu các doanh nghiệp yêu cầu bảo lãnh hoạt động kinh doanh tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong hợp đồng đối với cả người thụ hưởng bảo lãnh và ngân hàng bảo lãnh thì sẽ đảm bảo chất lượng cao cho hợp đồng và ngược lại.

+ Người thụ hưởng bảo lãnh.

Sự trung thực của người thụ hưởng trong việc yêu cầu thanh toán bảo lãnh cũng gây ảnh hưởng tới chất lượng của bảo lãnh . Như việc người thụ hưởng có thể xuất trình giấy tờ giả mạo chứng từ đòi thanh toán cho ngân hàng để nhận khoản tiền thanh toán bảo lãnh. Trong trường hợp ngân hàng không phát hiện được sự giả mạo này thì ngân hàng có khả năng gặp phải rủi ro do thanh toán cho người thụ hưởng số tiền bảo lãnh mà không đòi được tiền bồi hoàn từ phía người yêu cầu bảo lãnh .

Mặc dù Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội, Chi nhánh Cần Thơ đã triển khai hoạt động bảo lãnh từ những năm đầu thành lập, tuy nhiên hiệu quả hoạt động bảo lãnh ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội, Chi nhánh Cần Thơ chưa đạt được như mong muốn do một số yếu tố cả về chủ quan và khách quan như đã phân tích ở trên. Để khắc phục những hạn chế này nhằm phát triển hơn nữa hoạt động bảo lãnh ngân hàng, theo tôi cần tập trung giải quyết một số vấn đề sau đây:

Thứ nhất, yếu tố con người

Kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng cũng giống như mọi hoạt động kinh doanh khác, con người luôn là yếu tố quan trọng quyết định đến sự phát triển của ngân hàng nói chung và nghiệp vụ bảo lãnh nói riêng, do đó cần quan tâm nhiều hơn nữa đến yếu tố này, nhất là đối với cán bộ quản lý. Cán bộ quản lý tốt sẽ giúp ngân hàng có chiến lược khách hàng đúng đắn, có chiến lược phát triển phù hợp, hình thành bộ máy tổ chức có cơ chế vận hành nhịp nhàng, giúp cho việc phân công chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng hợp lý, đảm bảo sự phối hợp ăn khớp và hiệu quả giữa các bộ phận nghiệp vụ,

giúp tuyển dụng và lựa chọn được đội ngũ có năng lực, trình độ phù hợp. Trình độ quản lý tốt sẽ giúp cho việc hình thành một hệ thống các văn bản, chế độ phù hợp với quy định của pháp luật, với thực tiễn hoạt động của ngân hàng, thuận tiện và dễ dàng cho các cán bộ, nhân viên trong thực hiện hoạt động về bảo lãnh… Tất cả những vấn đề này sẽ có tác động thúc đẩy sự phát triển của các hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động bảo lãnh nói riêng. Ngược lại, nếu cán bộ có trình độ quản lý yếu kém sẽ dẫn đến sự tác động tiêu cực đến toàn bộ các hoạt động của ngân hàng, trong đó có hoạt động bảo lãnh.

Đối với cán bộ nghiệp vụ, cần nắm rõ các thông lệ, các văn bản cũng như quy trình về bảo lãnh để tránh nguy cơ phát sinh tranh chấp, các rủi ro và là cơ hội cho các đối tác gian lận trong hoạt động bảo lãnh. Ngoài ra, ý thức của cán bộ trong công việc như nhiệt tình, chu đáo trong quan hệ với khách hàng, tác nghiệp nhanh, chính xác và nhạy bén sẽ góp phần thu hút khách hàng.

Trước mắt, cần mở rộng và nâng cao các khóa đào tạo chuyên sâu về hoạt động bảo lãnh ngân hàng, không chỉ thực hiện bằng hình thức cử cán bộ đi học tại các trung tâm đào tạo và các trường đại học mà cần phải quan tâm đến công tác đào tạo tại chỗ. Phương pháp đào tạo này không chỉ tiết kiệm chi phí và thời gian mà còn rất thực tế, phù hợp với đặc điểm riêng của ngân hàng. Thông qua việc những cán bộ có kinh nghiệm hướng dẫn cho những cán bộ trẻ sẽ giúp họ dễ hiểu và không bị bỡ ngỡ khi gặp những tình huống thực tế.

Ngân hàng nên tập trung nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên của mình để đáp ứng nhu cầu của thương mại quốc tế. Điều này giúp ngân hàng hạn chế rủi ro trong các giao dịch nói chung và bảo lãnh nói riêng có yếu tố nước ngoài. Cập nhật thường xuyên, đầy đủ các quy định mới, những thay đổi, điều chỉnh bổ sung trong các văn bản pháp luật có liên quan đến bảo lãnh ngân hàng để phổ biến, quán triệt cho cán bộ, nhân viên mình kịp thời áp dụng, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

Xây dựng hệ thống gồm nhiều chỉ tiêu để đánh giá đúng thực trạng trình độ năng lực của cán bộ nhân viên thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh trong ngân hàng để phân loại các cán bộ nhân viên theo từng trình độ để tiến hành việc đào tạo đúng đối tượng và đúng nhu cầu giúp cho việc đào tạo cán bộ nhân viên của ngân hàng đạt hiệu quả hơn.

Cần tổ chức các buổi giao lưu, hội thảo giữa cán bộ nhân viên thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh với các chuyên gia, các ngân hàng khác để học hỏi kinh nghiệm.

Ngân hàng cần có chính sách khen thưởng, đãi ngộ hợp lý, đúng người và đúng lúc để tạo khích lệ trong công việc. Những người có nhiều đóng góp phải được khen thưởng xứng đáng còn những người vi phạm kỷ luật gây thiệt hại cho ngân hàng phải có hình thức xử lý thích đáng. Chẳng hạn như thưởng thêm lương cho cán bộ nhân viên thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh an toàn, chặt chẽ, đúng quy định pháp luật và vượt kế hoạch đề ra…hay có thể dùng hình thức thưởng một tỷ lệ phần trăm nhất định trên giá trị hợp đồng bảo lãnh đã ký kết cho cán bộ nhân viên thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh. Với những

chính sách khuyến khích như vậy sẽ tạo thêm động lực tích cực cho cán bộ nhân viên thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh, từ đó góp phần thực thi pháp luật về bảo lãnh ngân hàng và phát triển nghiệp vụ bảo lãnh đạt hiệu quả cao.

Thứ hai, chuyên môn hóa trong hoạt động bảo lãnh ngân hàng

Với thực tế hiện nay, chuyên viên khách hàng sẽ là những người tiếp cận khách hàng để giới thiệu về hầu như tất cả các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng, có chăng chỉ phân khúc thành chuyên viên khách hàng doanh nghiệp và chuyên viên khách hàng tài chính cá nhân. Điều này đã dẫn đến hệ quả cán bộ thực hiện không hiểu rõ được hết bản chất của từng loại hình sản phẩm, dịch vụ trong hoạt động ngân hàng, từ đó đưa ra những cách tiếp cận và quyết định không chính xác.

Do đó, trước hết để đảm bảo chuyên môn hóa hoạt động bảo lãnh ngân hàng, theo tôi MBCT có thể thí điểm thành lập phòng chuyên trách được thiết lập, được đào tạo chuyên biệt sẽ giúp tập trung thời gian và nguồn lực cho hoạt động khai thác, chăm sóc khách hàng, nắm bắt sâu hơn về tình hình tài chính của khách hàng, cũng như nâng thế chủ động của ngân hàng, nâng cao chất lượng thẩm định, quyết định cung cấp dịch vụ bảo lãnh cho khách hàng, thay vì gộp chung nghiệp vụ bảo lãnh với nghiệp vụ tín dụng như hiện nay.

Thứ ba, uy tín và năng lực tài chính

Như chúng ta biết, bản chất của bảo lãnh là cam kết trả thay của ngân hàng đối với người được thụ hưởng trong trường hợp người được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ của mình trong hợp đồng đã ký kết. Do vậy, ngân hàng bảo lãnh phải tạo dựng cho mình một uy tín lớn, phải chứng minh được năng lực tài chính của mình để cho khách hàng thấy được khả năng thực hiện nghĩa vụ trả thay của mình. Thực tiễn cho thấy, một ngân hàng càng có nhiều uy tín thì càng có nhiều khách hàng đến tham gia giao dịch, trong đó có bảo lãnh. Như vậy, uy tín và năng lực tài chính của ngân hàng ảnh hưởng lớn đến quy mô và hiệu quả hoạt động bảo lãnh.

Thứ tư, nâng cao hệ thống công nghệ

Ngày nay, sự canh tranh của các ngân hàng ngày càng quyết liệt, trình độ khoa học có thể nói là chìa khóa để các ngân hàng có thể nắm bắt để nâng cao năng lực cạnh tranh, không chỉ trong hoạt động bảo lãnh ngân hàng mà còn ở các hoạt động khác, nếu có một trình độ khoa học công nghệ tiên tiến, có thể xử lý chính xác, nhanh chóng các giao dịch nói riêng và giao dịch bảo lãnh nói chung sẽ giúp cho khách hàng tin tưởng hơn, an tâm và hài lòng hơn. Chính vì thế, mà có thể thu hút được nhiều khách hàng hơn. Hơn nữa, nếu khoa học và công nghệ của ngân hàng hiện đại sẽ góp phần giúp cho ngân hàng quản lý dễ dàng hơn và giảm thiểu được các rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động bảo lãnh.

Mặc dù được đánh giá là một trong những NHTM đi đầu trong ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ ngân hàng, tuy nhiên trong quá trình hoạt động MBCT cũng đã gặp không ít những trục trặc công nghệ mà ít hay nhiều cũng đã ảnh hưởng đến hoạt

động hàng ngày của ngân hàng. Do đó, cần tăng cường trang bị thêm các trang thiết bị công nghệ hiện đại, tiếp tục nâng cao hệ thống phần mềm công nghệ theo hướng có thể chiết xuất được hệ thống thông tin bảo lãnh đầy đủ để đảm bảo cho khách hàng tiện theo dõi, nắm bắt là một việc làm tất yếu.

Tăng cường hợp tác với các Fintech (công nghệ tài chính) đề xuất các giải pháp hữu hiệu để nâng cấp, ứng dụng các công nghệ số hiện đại vào hoạt động bảo lãnh ngân hàng, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ số tiện lợi, an toàn cho người dùng.

Việc phân tích và đưa ra các giải pháp trong hoạt động bảo lãnh của ngân hàng từ thực tiễn hoạt động tại Ngân hàng TMCP Quân đội, Chi nhánh Cần Thơ không chỉ rút ra những bài học kinh nghiệm cho riêng Ngân hàng TMCP Quân đội, Chi nhánh Cần Thơ nói riêng mà còn có thể được đúc kết thành những bài học kinh nghiệm chung cho ngành ngân hàng.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát

Hoạt động bảo lãnh là một hoạt động có nhiều rủi ro như: rủi ro chứng từ giả, rủi ro về giá khách hàng không có khả năng thanh toán, rủi ro lãi suất, rủi ro ngoại hối,…

Vì vậy, ngân hàng cần phải thường xuyên kiểm tra lại các hoạt động bảo lãnh hiện có, hoàn chỉnh lại hồ sơ, đánh giá tiến độ thực hiện hợp đồng, quản lý chặt chẽ quá trình thực hiện hợp đồng, nắm bắt được tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Đặc biệt phải tiến hành quản lý chặt chẽ những loại hình bảo lãnh đang thực hiện để hạn chế tối đa những rủi ro dẫn đến ngân hàng phải thanh toán thay cho doanh nghiệp trong khi nợ của doanh nghiệp ngày một nhiều và khả năng hoàn trả lại khó khăn.

Bên cạnh việc kiểm tra, kiểm soát khách hàng thì còn cần phải kiểm tra, kiểm soát nội bộ về việc thực hiện đúng quy trình bảo lãnh và có trách nhiệm rõ ràng đối với từng bộ phận và cá nhân.

Kết luận chương 2

Trên cơ sở tìm hiểu, phân tích đánh giá, nghiên cứu thực trạng áp dụng pháp luật về bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội, Chi nhánh Cần Thơ ở chương 1, chương 2 của luận văn đã trình bày, phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật nêu ra một số nguyên nhân chủ yếu dẫn đến bất cập trong hoạt động áp dụng pháp luật về bảo lãnh, đó là:

- Một số quy định pháp luật về bảo lãnh chưa phù hợp với thực tiễn hoạt động của Ngân hàng TMCP Quân đội nói chung và chi nhánh Cần Thơ nói riêng, dẫn đến khó khăn cho Ngân hàng TMCP Quân đội trong quá trình tuân thủ và thực thi pháp luật.

- Quy định pháp luật về bảo lãnh còn tồn tại nhiều nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, có nội dung còn mới nhưng hướng dẫn lại không đầy đủ, cụ thể nên gặp lúng túng trong áp dụng từ đó chưa tạo ra khung pháp lý an toàn, rõ ràng để thực thi.

- Các tranh chấp liên quan đến phạm vi bảo lãnh phát sinh còn nhiều trong khi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa có cơ chế giải quyết triệt để.

Trên cơ sở đó, tác giả đã kiến nghị một số đề xuất nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo lãnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển của hoạt động này cũng như tăng cường hiệu quả của hoạt động áp dụng pháp luật. Các kiến nghị này tập trung chủ yếu vào việc nhìn nhận, đánh giá lại các quy định pháp luật hiện hành nhằm áp dụng pháp luật một cách thống nhất, phù hợp với thực tiễn trong hoạt động bảo lãnh hiện nay và rà soát hệ thống các quy định pháp luật nhằm phát hiện và kịp thời sửa đổi các quy phạm pháp luật có nội dung còn chồng chéo, mâu thuẫn.

KẾT LUẬN

Bảo lãnh ngân hàng là một loại hình nghiệp vụ của các ngân hàng hiện đại và nó dần trở nên không thể thiếu trong cơ cấu dịch vụ của các NHTM hiện nay. Nó đem lại lợi ích không những đối với sự phát triển của ngành ngân hàng mà còn tác động trực tiếp đến nền kinh tế đất nước.

Thông qua việc nghiên cứu đề tài "Pháp luật về bảo lãnh Ngân hàng – Thực trạng áp dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội, Chi nhánh Cần Thơ" có thể rút ra những kết luận sau đây:

Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực trạng pháp lý điều chỉnh hoạt động bảo lãnh ngân hàng, ứng dụng trong thực tiễn từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp lý cũng như hoàn thiện hoạt động này tại Ngân hàng TMCP Quân đội, Chi nhánh Cần Thơ là mục tiêu nghiên cứu của luận văn này.

Về mặt lý luận, luận văn đã tập trung làm rõ những vấn đề cơ bản về hoạt động bảo lãnh ngân hàng như khái niệm, đặc điểm, vai trò, phân loại bảo lãnh ngân hàng, các dạng rủi ro thường gặp, các quy định về: trình tự, thủ tục thực hiện hoạt động BLNH, chủ thể thực hiện hoạt động BLNH, hợp đồng cấp BLNH, hợp đồng BLNH và giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động BLNH. Tuy nhiên, việc phân chia cũng chỉ mang tính tương đối do có sự giao thoa của pháp luật, mặt khác lại được đánh giá trên các góc độ khác nhau. Bên cạnh đó, luận văn đã có những phân tích cụ thể thực trạng pháp luật về bảo lãnh ngân hàng nói chung và tại MBCT nói riêng.. Bên cạnh đó, việc xác định rõ các nguyên tắc cơ bản của pháp luật về hoạt động BLNH cũng góp phần đánh giá chính xác hơn thực trạng pháp luật về lĩnh vực này.

Về mặt thực tiễn, luận văn đã giới thiệu, phân tích và đánh giá về hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân Đội, Chi nhánh Cần Thơ đồng thời chỉ ra những vướng mắc pháp lý thường gặp trong hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng này. Trên cơ sở những phân tích trên, người viết đã đưa ra một số giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về bảo lãnh ngân hàng ở Việt Nam hiện nay cũng như đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bảo lãnh ngân hàng tại MBCT.

Nền kinh tế Việt Nam đang vận động phát triển theo xu hướng hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Việc hoàn thiện pháp luật về hoạt động BLNH không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt là thực hiện cam kết trong quá trình hội nhập và hạn chế các tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực này, mang lại nhiều lợi ích cho cả khách hàng và ngân hàng mà còn làm lành mạnh và phát triển hoạt động BLNH, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam.

DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT

1. Quốc hội (2005), Bộ luật Dân sự 2005
2. Quốc hội (2004), Bộ luật Tố tụng dân sự 2004
3. Quốc hội (2005), Luật Thương mại 2005
4. Quốc hội (2010), Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam 2010
5. Quốc hội (2010), Luật Các Tổ chức tín dụng 2010
6. Quốc hội (2010), Luật Trọng tài thương mại 2010
7. Quốc hội (2015), Bộ luật Dân sự 2015
8. Quốc hội (2010), Luật Các Tổ chức tín dụng 2024
9. Ngân hàng TMCP Quân Đội (2015), Quyết định số 2821/QĐ-HS Ban hành quy định hoạt động bảo lãnh tại MB.
10. Bộ Tư pháp (2018), *Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp,* Hà Nội.
11. Bộ Tư pháp (2019), *Thông tư liên tịch số 01/TT-BTP ngày 17/01/2019 của Bộ Tư pháp, hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển,* , Hà Nội.
12. Bộ Tư pháp – Bộ Giao thông Vận tải – Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an (2013), *Thông tư liên tịch số 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-*

BCA ngày 05/11/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an về hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản, Hà Nội.

13. Bộ Tư pháp, (2019), *Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp, về việc hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất*, Hà Nội.
14. Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2014), *Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/6/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm*, Hà Nội.
15. Chính phủ (2021), *Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ,* Hà Nội.
16. Chính phủ (2022), *Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm*, Hà Nội.
17. Chính phủ (2012), *Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật*, Hà Nội.
18. Chính phủ (2014), *Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 7/4/2014 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng*, Hà Nội.
19. Chính phủ (2015), *Nghị quyết 01/NQ -CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về Chương trình hành động của Bộ tư pháp về tập trung giải quyết các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng*, Hà Nội.
20. Ngân hàng Nhà nước, (2017), VBHN số 09/VBHN-NHNN ngày 06/10/2017 của Ngân hàng Nhà nước quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.
21. Ngân hàng Nhà nước, (2022), *Thông tư số 11/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 của Ngân hàng Nhà nước quy định về bảo lãnh Ngân hàng*, Hà Nội.
22. Bộ Tư pháp, (2019), *Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp, hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất*, Hà Nội.
23. Ngân hàng Nhà nước (2019), *Thông tư số 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài*, Hà Nội.
24. Ngân hàng Nhà nước (2016), *Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng*, Hà Nội.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. DANH MỤC SÁCH, BÁO, TẠP CHÍ

25. Từ điển Luật học (2006), Nxb. Tư pháp và Nxb. Từ điển Bách khoa.
26. Lê Nguyên (2017), *Bảo lãnh ngân hàng và tín dụng dự phòng,* Nxb Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh.
27. Lê Vũ Nam (2020), Pháp luật về bảo đảm nghĩa vụ, Nxb. ĐHQG-HCM.
28. Ngô Quốc Kỳ (2015), *Hoàn thiện pháp luật hoạt động của Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam,* Nxb Tư pháp, Hà Nội.
29. Đỗ Văn Đại (2016), Bình luận khoa học những điểm mới của Bộ luật dân sự năm 2015, Nxb. Hồng Đức- Hội luật gia Việt Nam.
30. Đỗ Văn Đại (2017), Luật nghĩa vụ và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ Việt Nam : Bản án và bình luận án, Nxb. Hồng Đức - Hội luật gia Việt Nam.
31. Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (2015), Giáo trình Luật Ngân hàng, Nxb. Hồng Đức.
32. Trường Đại học Luật, Đại học Huế (2015), Pháp luật về giao dịch bảo đảm trong hoạt động cấp tín dụng ở Việt Nam, Nxb. Chính trị Quốc gia.
33. Lương Khải Ân (2021), Hợp đồng cho vay trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng lý luận và thực tiễn áp dụng, Nxb. Chính trị Quốc gia.
34. Đoàn Thị Phương Diệp (2020), Giáo trình pháp luật về bảo đảm nghĩa vụ, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM, 2020 (Đồng tác giả),
35. Nguyễn Thị Mỹ Linh (2018), Giáo trình Bảo đảm nghĩa vụ, NXB Trường Đại học Cần Thơ, (Đồng tác giả).
36. Nguyễn Thị Mỹ Linh, Hoàn thiện pháp luật về giao kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam: Cơ chế minh bạch thông tin đối với khách hàng, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số 154 (215), 2024 (kì 2), (Đồng tác giả),
37. Duy Kiên, Bảo lãnh (2019), Một biện pháp bảo đảm quan trọng và một số lưu ý, Tạp chí Tòa án nhân dân, Số 6/2019.
38. Giáp Minh Tâm (2017), Quy định chung về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Tạp chí Kiểm sát Số 12/2017.
39. Võ Đình Toàn (2017), "*Một số vấn đề về quan hệ bảo lãnh ngân hàng ở nước ta hiện nay*", Tạp chí luật học, Số 3/2017.
40. Hồ Quang Huy (2017), Hoàn thiện các quy định pháp luật về biện pháp bảo lãnh, Tạp chí Dân chủ & pháp luật, Bộ tư pháp, 2017, Số chuyên đề tháng 5/2017;
41. Đoàn Thị Phương Diệp, Dương Kim Thế Nguyên (2018), So sánh chế định bảo lãnh trong Bộ luật Dân sự năm 2015 và pháp luật dân sự Pháp, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Số 7 (359).
42. Nguyễn Ngọc Điện (2020), Góp ý xây dựng nghị định chi tiết về biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Số 24(424).

43. Nguyễn Hải Ngân (2019), *Cơ sở lý thuyết của bảo lãnh và liên hệ với quy định về bảo lãnh trong Bộ luật Dân sự năm 2015,* Tạp chí Khoa học Kiểm sát, Số 02 (28).
44. Hồ Quang Huy (2017), *Hoàn thiện các quy định pháp luật về biện pháp bảo lãnh, Tạp chí Dân chủ & pháp luật*, Bộ tư pháp, 2017, Số chuyên đề tháng 5/2017.
45. Lại Hiệp Phong (2020), *Bảo lãnh thế chấp tài sản bảo đảm khoản vay tại các tổ chức tín dụng*, Tạp chí Dân chủ & pháp luật, Bộ tư pháp, 2020, Số chuyên đề tháng 5/2020.
46. Lê Quang Dũng (2017), *Hợp đồng cho vay tiền của các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam*, Tạp chí Dân chủ & pháp luật, Bộ tư pháp, 2017, Số chuyên đề tháng 5/2017.
47. Nguyễn Hồng Nhung (2022), "*Một số vấn đề pháp lý về bảo lãnh ngân hàng trong mua, bán nhà ở hình thành trong tương lai và giải pháp hoàn thiện*". Truy cập ngày 20/11/2023 https://lsvn.vn/mot-so-van-de-phap-ly-ve-mua-ban-nha-o-hinh-thanh-trong-tuong-lai1657031860.html.
48. Lê Văn Dũng (2021), *Bản chất quan hệ bảo lãnh thanh toán tại các tổ chức tín dụng*, Tạp chí công thương điện tử,
Truy cập 20/11/2023.[http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/ban-chat-quan-he-bao-lanh thanhtoan-tai-cac-to-chuc-tin-dung-81130.htm].

B. TÀI LIỆU TIẾNG ANH

49. ICC (1992), Uniform Rules for Demand Guarantees No.458 (URDG 458), ICC Publication, Paris.
50. ICC (2007), Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600), ICC Publication, Paris.
51. ICC (2010), Uniform Rules for Demand Guarantees No.758 (URDG 758), ICC Publication, Paris.
52. Nguyễn Thị Mỹ Linh, The Development of Matrimonial Property Law in Vietnam in the Mirror of the Foreign Impacts, Volume 4, Publishing house University of Pecs, Hungary, 2023, 61-120.
53. Jakimovski, Z. (2020, December). Bank guarantee as a mean of security in freight forwarding. In *Proceedings of the International Scientific Conference" Social Changes in the Global World"* (Vol. 1, No. 3, pp. 69-81).
54. Jakimovski, Z. (2020). Legal Regulation of the Bank Guarantee as a Mean of Security under the Macedonian and Comparative Law. *Iustinianus Primus L. Rev.*, *11*, 1.
55. Jus, M. (1989). Bank Guarantees: Their Legal Nature, Effects and Insurance Value. *Pravnik*, *44*, 283.

56. Kyomugisha, K. (2015). *The enforcement of bank guarantee as a form of security: an examination of the law and practice in Uganda* (Doctoral dissertation, Kampala International University, School of Law).
57. Lipartia, N. (2017). Analysis of Legal Nature of Bank Guarantees in the Light of the Principles of Autonomy and Strict Compliance. *J. Law*, 28.
58. Mirkovic, P., & Minic, S. (2017). Legal Characteristics of Bank Guarantee and Certain Distinctions in Regard to Contract of Assurance. *Kultura Polisa*, *14*, 531.
59. Nemeş, V. (2012). Bank Guarantees. *LESIJ-Lex ET Scientia International Journal*, *19*(2), 128-136.
60. Nielsen, J., & Nielsen, N. (2013). The German Bank Guarantee: Lesson to Be Drawn for China. *Geo. Mason J. Int'l Com. L.*, *5*, 171.
61. Putriyanti, E. D. (2017). Legal Status of Credit Bank Guarantee in Indonesia's Legal Guarantee. *Sriwijaya Law Review*, *1*(2), 128-141.
62. Efimova, L. G. (2018). Legal Nature of an Independent (Bank) Guarantee. *Legal Concept= Pravovaya Paradigma*, *17*(4).
63. Kocaman, A. B. (1989). On the Legal Nature of Bank Guarantee Letters. *Banka Huk. Dergisi*, *15*, 49.
64. Bertrams, R. F. (2013). *Bank guarantees in international trade: the law and practice of independent (first demand) guarantees and standby letters of credit in civil law and common law jurisdictions*. Kluwer Law International BV.
65. Knezević, M., & Lukić, A. (2012). Bank Guarantees and their Representation in Bank Business Activities (Parallel Legal Presentation). *Economic Insights-Trends & Challenges*, *64*(1).

C. TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ

66. Credit Contracts and Consumer Finance Act 2003, truy cập 10/3/2022 tạihttps://www.legislation.govt.nz/act/public/2003/0052/latest/DLM211512.html
67. Bùi Đức Giang (2021), *Khuôn khổ pháp lý chung về bảo lãnh nhìn từ thực tiễn cấp tín dụng có bảo đảm,* Tạp chí Ngân hàng điện tử,
Truy cập 20/11/2023 tại https://tapchinganhang.gov.vn/khuon-kho-phaply-chung-ve-bao-lanh-nhin-tu-thuc-tien-cap-tin-dung-co-bao-dam.htm.
68. Đỗ Hồng Thái: *"Tính lệ thuộc của nghĩa vụ bảo lãnh, một vấn đề ngân hàng cho vay cần quan tâm"*.
Truy cập 27/11/2023 tại http://thongtinphapluatdansu.edu.vn/
69. Hoàng Duy – "*Rủi ro nhận thế chấp tài sản của bên thứ ba"*.
Truy cập ngày 27/11/2023, http://tinnhanhchungkhoan.vn/phap-luat/rui ro-nhanthe-chap-tai-san-cua-ben-thu-ba-16526.html.

70. Law of the People's Republic of China on Commercial Banks, Truy cập 10/12/2023 tại http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/200712/12/content_1383716.htm;

71. Nguyễn Thùy Trang, "*Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại: Một số nhận định từ góc độ pháp lý đến thực tiễn*".Truy cập ngày 27/11/2023 tại http://thongtinphapluatdansu.edu.vn/.

72. *CRMNEXT (2022), "Axis Bank cùng đối tác CRMNEXT giành giải thưởng triển khai CRM tốt nhất từ Asian Banker"*. Cision, Truy cập ngày 24/8/2023. http://vn.prnasia.com/story/79482-11.shtml,*59*.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ

Họ và tên học viên: **Nguyễn Hồng Quân** Mã số học viên: M3422044
Ngành: Luật Kinh tế Mã ngành: 8380107
Khóa: 2022-2024
Tên đề tài luận văn Thạc sĩ: Pháp luật về bảo lãnh ngân hàng - thực trạng áp dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội, chi nhánh Cần Thơ

Người hướng dẫn: 1. TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh - Trường ĐH Cần Thơ
2. PGS.TS. Đoàn Thị Phương Diệp - Trường ĐH Kinh tế Luật- ĐHQG TP HCM

Địa điểm bảo vệ: Hội trường Khoa Luật – Trường ĐH Cần Thơ
Hình thức bảo vệ luận văn: Trực tuyến ☐ Trực tiếp ☑
Số lượng thành viên Hội đồng tham dự trực tuyến:
1. Ý nghĩa về lý luận, thực tiễn của luận văn:
2. Mức độ đáp ứng yêu cầu của luận văn (chọn 1 trong 3):
- Luận văn đạt: không cần chỉnh sửa ☐
- Luận văn đạt: cần chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng ☑
- Luận văn không đạt ☐

3. Kết luận của Hội đồng về việc công nhận trình độ và cấp bằng thạc sĩ cho Học viên cao học:
- Các nội dung chính cần chỉnh sửa *(theo Biên bản Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ)*.
- Hội đồng thống nhất Ủy quyền cho .....A..... kiểm tra và ký xác nhận vào Trang chấp thuận của Hội đồng và Bản giải trình chỉnh sửa của học viên *(nếu có)*.
- Đề nghị Nhà trường xem xét công nhận trình độ và cấp bằng thạc sĩ cho học viên Nguyễn Hồng Quân nếu học viên đã hoàn thành việc chỉnh sửa các nội dung mà Hội đồng thông qua theo Quyết nghị này.
- Thư ký đã đọc lại nội dung Quyết nghị này cho tất cả thành viên Hội đồng và nhất trí biểu quyết thông qua Quyết nghị với kết quả 5/5 thành viên đồng ý.
- Chủ tịch Hội đồng tuyên bố kết thúc buổi chấm bảo vệ luận văn thạc sĩ lúc 11... giờ 20 phút cùng ngày.

Cần Thơ, ngày 21 tháng 8 năm 2024

Chủ tịch Hội đồng	**Thư ký Hội đồng**
Phan Trung Hiền	**Dương Văn Học**

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA LUẬT

Phan Trung Hiền